Art. 122 - Conceder-se-á, a critério do Procurador-Geral de Justiça, licença em caráter especial, não remunerada, para tratamento de assuntos particulares, pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos consecutivos, observado o seguinte:

I - poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do interessado ou no interesse do serviço;

II - não será concedida nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior;

III - perderá o beneficiado sua posição na classificação da lista de antigüidade.

Art. 123 - O membro do Ministério Público licenciado não pode exercer quaisquer de suas funções ou outra função pública ou particular.

SUBSEÇÃO VII

DOS AFASTAMENTOS

Art. 124 - O membro do Ministério Público poderá afastar-se do cargo para:

I - exercício de cargo de presidente de entidade de classe de âmbito estadual ou nacional, bem como de cargo de direção na respectiva entidade com função que exija dedicação exclusiva, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público;

II - freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos no País ou no exterior, de duração máxima de 2 (dois) anos, observado o disposto no Art. 23, XIV desta lei.

III - participação em congressos, seminários ou encontros relacionados com o exercício da função, pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo de vencimentos e vantagens;

IV - elaboração de dissertações de mestrado e teses de doutorado de cursos promovidos por instituições oficiais ou reconhecidas, pelo prazo máximo de 03 (três) meses.

§ 1.º - Os afastamentos previstos neste artigo serão remunerados.

§ 2.º - Os afastamentos a que se referem os incisos II e III não serão concedidos ao membro do Ministério Público com menos de 03 (três) anos de carreira ou apenado em procedimento disciplinar.

§ 3.º - Os afastamentos previstos nos incisos II, III e IV obrigam à apresentação de relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e comprovação de frequência regular.

§ 4.º - O membro do Ministério Público perderá o tempo de serviço correspondente ao afastamento previsto nos inciso II e III se não comprovar o aproveitamento nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao término da atividade desempenhada.

§ 5.º - A exoneração do membro do Ministério Público que tenha se afastado das funções para o fim previsto no inciso II deste artigo obriga ao ressarcimento dos valores percebidos a título de vencimentos e vantagens no período correspondente.

§ 6.º - Não se aplicará o disposto no parágrafo anterior quando decorrido mais de 4 (quatro) anos do retorno às normais atribuições do cargo.

§ 7.º - No caso do afastamento previsto no inciso I, deve o membro do Ministério Público comunicar ao Procurador-Geral de Justiça sua permanência ou não em atividade durante o período de férias coletivas.

Art. 125 - Poderá o membro do Ministério Público afastar-se do cargo, ainda, para:

I - exercer cargo público eletivo ou a ele concorrer;

II - exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou funções em Ministérios ou Secretarias de Estado, desde que de alta relevância e relacionada à atuação do Ministério Público;

§ 1.º - Os afastamentos previstos neste artigo dependerão de aprovação, por maioria absoluta, do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2.º - Não será permitido o afastamento de membro do Ministério Público submetido a procedimento disciplinar, que esteja em estágio probatório ou que reuna as condições previstas no artigo 127.

§ 3.º - Os beneficiados pelos afastamentos previstos neste artigo poderão optar pela percepção exclusiva dos vencimentos e das vantagens da função pública a ser exercida, ficando o direito às férias vinculados aos respectivos cargos e vedado o gozo destas quando do retorno.

§ 4.º - O afastamento de membro do Ministério Público para concorrer a cargo público eletivo dar-se-á sem prejuízo da percepção de vencimentos e vantagens, salvo no caso de eleição a se realizar em outro Estado da Federação.

Art. 126 - O membro do Ministério Público afastado não pode exercer quaisquer de suas funções ou outra função pública ou particular, exceto nas hipóteses previstas no artigo anterior.

SUBSEÇÃO VIII

DA APOSENTADORIA

Art. 127 - O membro do Ministério Público será aposentado com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos 70 (setenta) anos de idade, e, facultativamente, aos 30 (trinta) anos de serviço, após 5 (cinco) anos de efetivo exercício na carreira.

Art. 128 - Os proventos de aposentadoria, que corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos a qualquer título no serviço ativo, serão revistos sempre que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, na mesma proporção e data, estendendo-se, ainda, aos inativos, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou de conversão de adicionais.

§ 1.º - Os proventos do membro do Ministério Público aposentado serão pagos na mesma ocasião em que o forem os vencimentos do membro em atividade.

§ 2.º - É assegurado ao membro do Ministério Público afastar-se da atividade, a partir do protocolo do pedido de aposentadoria, salvo na hipótese prevista no artigo 222 desta lei, ou quando estiver em tramitação pedido de instauração de processo disciplinar administrativo.

Art. 129 - A apuração do tempo de serviço para aposentadoria será feita em dias, convertidos em anos, estes considerados como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Art. 130 - O tempo de serviço público e privado será computado para os efeitos legais, salvo se concomitante.

§ 1.º - O tempo de serviço privado não será considerado para a concessão de licença-prêmio e adicionais.

§ 2.º - A contagem de tempo de serviço poderá ser realizada em procedimento administrativo interno, vedada a produção de prova exclusivamente testemunhal.

§ 3.º - Computar-se-á, para efeito de aposentadoria e dicionais, o tempo de advocacia, até o máximo de 15 (quinze) anos.

SUBSEÇÃO IX

DA PENSÃO POR MORTE

Art. 131 - A pensão por morte, igual à totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em atividade ou inatividade do Ministério Público, será reajustada na mesma data e proporção daqueles.

Parágrafo único - A pensão obrigatória não impedirá a percepção dos benefícios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência.

Art. 132 - A pensão por morte, prevista no artigo anterior, será devida ao cônjuge sobrevivente e filhos menores de 21(vinte e um) anos do membro do Ministério Público.

Parágrafo único - Na falta dos beneficiários designados o caput deste artigo, a pensão será concedida aos reconhecidos como dependentes perante a previdência do membro do Ministério Público.

Art. 133 - A pensão destinada ao cônjuge sobrevivente e filhos será devida àquele enquanto perdurar a sua viuvez e, no caso dos filhos matriculados em curso regular de nível superior, estendida até a conclusão do curso, observado o limite de 24 (vinte e quatro) anos de idade, extinguindo-se, também, pela convolação de núpcias.

§ 1.º - A parcela destinada ao cônjuge sobrevivente reverterá em benefício dos filhos, em caso de morte ou cessação da viuvez, observado o disposto no caput deste artigo.

§ 2.º - A parcela dos filhos, quando extinta a condição de beneficiários, reverterá em favor do cônjuge sobrevivente.

§ 3.º - O limite de idade previsto neste artigo não se aplica aos filhos permanentemente inválidos, de acordo com laudo médico, ou aos legalmente incapazes.

Art. 134 - Os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, para efeito da pensão por morte disciplinada nesta subseção, concorrerão em igualdade de condições com o cônjuge, garantindo-se aos beneficiários parcelas individuais isonômicas.

Parágrafo único - Aplica-se a isonomia disciplinada neste artigo em caso de concurso de beneficiários reconhecidos nesta lei.

Art. 135 - A pensão por morte será concedida por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 136 - Para os fins desta subseção, equipara-se, para concessão, alteração ou cassação da pensão por morte, o companheiro ao cônjuge.

TÍTULO III

DA CARREIRA

CAPÍTULO I

DO INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SEÇÃO I

DO CONCURSO

Art. 137 - O ingresso na carreira do Ministério Público, no cargo de Promotor de Justiça Substituto, dar-se-á mediante aprovação em concurso público de provas e títulos.

§ 1.º - O concurso será organizado e realizado pela Procuradoria Geral de Justiça, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2.º - O concurso terá validade de 2 (dois) anos, contados da homologação, prorrogável por igual período.

§ 3.º - É obrigatória a abertura do concurso de ingresso quando o número de vagas atingir 1/5 (um quinto) dos cargos iniciais da carreira.

§ 4.º - A abertura do concurso será determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, ressalvado o disposto no artigo 23, inciso IX, através de edital publicado no órgão oficial do Estado, contendo prazo de inscrição de no mínimo 30 (trinta) dias e outros requisitos previstos nesta Lei e no regulamento do concurso.

Art. 138 - São requisitos para o ingresso na carreira do Ministério Público, dentre outros constantes no regulamento do concurso:

I - ser brasileiro;

II - ter concluído curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida;

III - estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais;

IV - estar em gozo dos direitos políticos;

V - ser detentor de comprovada idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar;

VI - apresentar higidez física e mental, atestada por médicos oficiais;

VII - ter satisfeito os demais requisitos previstos no edital e no regulamento do concurso.

Art. 139 - Observados os requisitos previstos nesta Lei, o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público será, ainda, disciplinado em regulamento específico, aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que reservará às pessoas portadoras de deficiência 5% (cinco por cento) das vagas.

SEÇÃO II

DA NOMEAÇÃO, DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Art. 140 - O Procurador-Geral de Justiça nomeará, observando a ordem de classificação no concurso, tantos candidatos aprovados quantas forem as vagas existentes.

Parágrafo único - O candidato que antes do ato de nomeação manifestar desinteresse em ser nomeado passará para o final da lista, ficando sua nomeação posterior dependendo de vaga e ato específico do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 141 - O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira do Ministério Público será nomeado para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, com prerrogativas e vedações do Promotor de Justiça de entrância inicial.

Art. 142 - Os candidatos serão empossados pelo Procurador-Geral de Justiça, em sessão solene do Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 143 - Para tomar posse, deverá o membro do Ministério Público exibir ao Presidente do Conselho Superior o título de sua nomeação, o laudo de sanidade, comprovado em inspeção pela junta médica oficial do Estado, e a declaração de seus bens e valores.

Parágrafo único - O empossado proferirá, solenemente, como compromisso, as seguintes palavras: "Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com retidão, dignidade e escrúpulo os deveres inerentes às funções do cargo de Promotor de Justiça, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis."

Art. 144 - O membro do Ministério Público tomará posse dentro de 30 (trinta) dias da nomeação, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, a pedido do interessado.

§ 1.º - Caso a posse não ocorra dentro dos prazos previstos, por ausência do nomeado, será decretada automaticamente a perda do cargo em ato do Procurador-Geral de Justiça.

§ 2.º - O candidato remanescente que pretender nomeação deverá requerê-la até a data da homologação do concurso subseqüente, apresentando os documentos a que se refere o artigo 138, incisos IV, V e VI desta lei.

§ 3.º - Não requerida a nomeação no prazo estabelecido no parágrafo anterior, o candidato decairá do direito.

SEÇÃO III

DO ESTÁGIO DE ORIENTAÇÃO E PREPARAÇÃO

Art. 145 - Após entrar em exercício, o Promotor de Justiça Substituto ficará à disposição da Escola Superior do Ministério Público pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, para estágio de orientação e preparação.

Parágrafo único - Durante o estágio a que se refere este artigo, o Promotor de Justiça Substituto poderá ser designado para o exercício das atribuições do cargo.

Art. 146 - Em caso de aproveitamento insuficiente no estágio de orientação e preparação, o Promotor de Justiça Substituto permanecerá, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, à disposição da Escola Superior do Ministério Público para aprimoramento, podendo seu Diretor, a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação do corpo docente, impugnar a permanência na carreira à Corregedoria Geral do Ministério Público.

§ 1.º - A impugnação será fundamentada e instruída com documentos referentes ao desempenho insatisfatório.

§ 2.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público, motivadamente, submeterá a impugnação à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta lei.

§ 3.º - Rejeitada a impugnação, o membro do Ministério Público permanecerá em estágio probatório, na forma desta lei.

SEÇÃO IV

DO VITALICIAMENTO

Art. 147 - Os 2 (dois) primeiros anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio probatório, durante os quais, o membro do Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta avaliados para fins de vitaliciamento, observados os seguintes requisitos:

I - idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar;

II - conduta pública e particular compatível com a dignidade do cargo;

III - dedicação e exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo;

IV - eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas funções;

V - presteza e segurança nas manifestações processuais;

VI - referências em razão da atuação funcional;

VII - publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive premiação obtida;

VIII - contribuição à melhoria dos serviços da instituição e da Promotoria de Justiça;

IX - integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo;

X - freqüência a cursos de aperfeiçoamento realizados pela Escola Superior do Ministério Público.

§ 1.º - Durante o biênio a que se refere este artigo a atuação do membro do Ministério Público será, ainda, acompanhada e avaliada pela Corregedoria Geral do Ministério Público, por meio de inspeções, correições, análise de trabalhos remetidos e outros meios a seu alcance.

§ 2.º - A permanência na carreira e o vitaliciamento do membro do Ministério Público serão deliberados pelo Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta lei.

Art. 148 - O Corregedor-Geral do Ministério Público, 2 (dois) meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público, relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos membros do Ministério Público em estágio probatório, recomendando, fundamentadamente, o vitaliciamento ou não.

§ 1.º - Se o relatório concluir pelo não vitaliciamento, poderá membro do Ministério Público ser suspenso, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público, até definitivo julgamento, do seu exercício funcional.

§ 2.º - Os membros do Conselho Superior do Ministério Público poderão impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público, por escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento, caso em que se aplica o disposto no parágrafo anterior.

§ 3.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público, observado o disposto neste artigo, poderá propor, excepcionalmente, ao Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento de Promotor de Justiça antes do prazo nele previsto, aplicando-se, também neste caso, o disposto no seu § 1.º.

Art. 149 - Se a conclusão do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público for desfavorável ao vitaliciamento ou se for apresentada a impugnação de que cuida o § 2.º do artigo anterior, o Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de 10 (dez) dias, o Promotor de Justiça interessado, que poderá apresentar defesa prévia e requerer provas nos 5 (cinco) dias seguintes, pessoalmente ou por procurador.

§ 1.º - Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para alegações finais pelo prazo de 10 (dez) dias.

§ 2.º - Na primeira reunião ordinária subseqüente, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto da maioria absoluta dos seus membros.

§ 3.º - Da decisão contrária ao vitaliciamento caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias contados de sua intimação, que será processado na forma de seu regimento interno.

§ 4.º - A intimação do interessado e de seu procurador, quando houver, será pessoal ou, havendo motivo justificado, por publicação no Diário Oficial do Estado.

§ 5.º - Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária ao relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público, caberá recurso desté ao Colégio de Procuradores de Justiça nos termos do § 3.º deste artigo.

Art. 150 - O Conselho Superior do Ministério Público terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Colégio de Procuradores de Justiça 30 (trinta) dias para decidir eventual recurso.

§ 1.º - Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional.

§ 2.º - Transitada em julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça.

CAPÍTULO II

DA VACÂNCIA E DAS FORMAS DE PROVIMENTO DERIVADO

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 151 - São formas de provimento derivado dos cargos do Ministério Público:

a) promoção;

b) remoção;

c) reintegração;

d) reversão;

e) aproveitamento.

Art. 152 - Na existência de vaga a ser provida, o Conselho Superior do Ministério Público, por meio de seu Presidente, fará publicar, no órgão oficial, edital de inscrição dos candidatos.

§ 1.º - O regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público disciplinará os requisitos do edital de promoção ou remoção e os critérios de votação, observado o disposto nesta Lei.

§ 2.º - A data da abertura da vaga, para efeito de determinação do critério de provimento, será:

I - a do falecimento do membro do Ministério Público;

II - a da publicação do ato de aposentadoria ou de exoneração do membro do Ministério Público;

III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, a remoção compulsória ou a que decretar a disponibilidade;

IV - a da publicação do ato que decretar a disponibilidade compulsória;

V - aquela em que o membro do Ministério Público, promovido ou removido, assumir as funções do outro cargo.

Parágrafo único - Havendo simultaneidade na data da ocorrência da vaga, a precedência de abertura será determinada pela vaga deixada pelo mais antigo na respectiva entrância.

Art. 153 - O Conselho Superior do Ministério Público, tendo em vista as necessidades e o interesse do serviço, deliberará:

I - em se tratando de vaga única, se o provimento do cargo dar-se-á por promoção ou remoção, observada a alternância dos critérios de merecimento e antigüidade;

II - em se tratando de vagas simultâneas, as quais serão providas por promoção e por remoção, fixando, a seguir, os critérios de antigüidade e merecimento para cada caso.

§ 1.º - A deliberação de que trata este artigo deverá ser tomada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência da vaga.

§ 2.º - Ocorrendo situações especiais, em conseqüência do número de vagas existentes no quadro do Ministério Público, o prazo para deliberação previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado pelo Conselho Superior do Ministério Público, mediante decisão fundamentada.

Art. 154 - Cumprido o disposto no artigo anterior, o Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, nos 3 (três) dias subseqüentes, expedirá edital com prazo de 10 (dez) dias para inscrição dos candidatos.

Parágrafo único - O edital mencionará se a promoção ou a remoção se fará pelo critério de merecimento ou antigüidade e indicará o cargo correspondente à vaga a ser preenchida.

Art. 155 - Sob pena de indeferimento, a inscrição para promoção ou remoção, por antigüidade ou merecimento, será instruída com:

I - declaração de regularidade do serviço;

II - declaração de comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça;

III - prova de residência na comarca, se titular.

§ 1.º - Caso não preencha os requisitos deste artigo, o candidato poderá apresentar justificativa ao Conselho Superior do Ministério Público, que deliberará sobre a admissibilidade da inscrição.

§ 2.º - As declarações referidas nos incisos I e II não excluem a possibilidade de averiguação, pela Corregedoria Geral do Ministério Público, das informações prestadas, inclusive por recomendação do Conselho Superior do Ministério Público, sobrestando-se, neste caso, a respectiva lista.

§ 3.º - Constatada a irregularidade de serviço, será recusada a promoção do membro do Ministério Público ou revogado o ato que a concedeu, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 4.º - A renúncia à inscrição somente será admitida até os 3 (três) dias anteriores à elaboração das listas.

§ 5.º - No prazo correspondente à entrada em exercício, é facultada a renúncia à promoção, ficando o membro do Ministério Público impedido, neste caso, de concorrer a nova promoção pelo período de 1 (um) ano.

§ 6.º - A renúncia à promoção implica no preenchimento da vaga recusada pelo segundo ocupante da respectiva lista.

§ 7.º - Ao entrar em exercício na Procuradoria ou Promotoria de Justiça para a qual foi promovido ou removido, o membro do Ministério Público deverá encaminhar à Corregedoria Geral do Ministério Público declaração acerca da regularidade de serviço afeto ao cargo assumido.

Art. 156 - Encerrado o prazo de inscrições, a lista dos inscritos será afixada em local visível na sede da Procuradoria Geral de Justiça, concedendo-se prazo de 3 (três) dias para impugnações, reclamações e desistências.

Art. 157 - Findo o prazo para impugnações, reclamações e desistências, com o parecer prévio do Corregedor-Geral do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público terá 5 (cinco) dias para exame e, em sua primeira reunião, indicará 3 (três) nomes, quando se tratar de promoção ou remoção por merecimento.

§ 1.º - A lista de merecimento será formada com os nomes dos 3 (três) candidatos mais votados, desde que obtida maioria dos votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior.

§ 2.º - Somente poderão ser indicados os candidatos que:

a) não tenham sofrido pena disciplinar ou remoção compulsória no período de 1 (um) ano, anterior à elaboração da lista;

b) não tenham sido removidos voluntariamente ou por permuta no período de 1 (um) ano anterior à elaboração da lista;

c) tenham completado 2 (dois) anos de exercício no cargo anterior e estejam classificados no primeiro quinto da lista de antigüidade, salvo se não houver com tais requisitos outro candidato ou quando o número limitado de inscritos inviabilizar a formação de lista tríplice e o interesse do serviço exigir o imediato provimento do cargo, sendo permitida, nesta hipótese, inclusive promoção de entrância inicial para final.

Art. 158 - Na formação da lista tríplice será observado o número de votos de cada candidato, pela ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antigüidade na entrância, salvo se o Conselho Superior do Ministério Público delegar ao Procurador-Geral de Justiça voto de desempate.

§ 1.º - Será obrigatória a indicação do Promotor de Justiça que tenha figurado por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) alternadas em lista de merecimento, não se aplicando nesse caso o disposto no caput deste artigo.

§ 2.º - A consecutividade só se considerará interrompida se o candidato der causa, direta ou indiretamente, a sua não indicação.

§ 3.º - Consideram-se distintas as indicações procedidas na mesma reunião.

Art. 159 - O Conselho Superior do Ministério Público poderá recusar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, a promoção ou remoção por antigüidade, com fundamento no interesse do serviço, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após o julgamento de eventual recurso pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Parágrafo único - A recusa apenas impede o provimento imediato da vaga objeto do recurso ou da primeira das vagas para as quais eventualmente tenha inscrito o candidato recusado.

Art. 160 - A vaga decorrente de remoção será provida, obrigatoriamente, por promoção.

Art. 161 - No caso de promoção, remoção, reversão, permuta ou designação de membro do Ministério Público, este comunicará imediatamente ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público a interrupção de suas funções anteriores e a data do novo exercício.

Art. 162 - O membro do Ministério Público que for promovido, removido ou houver permutado, estando em gozo de férias ou de licença, terá o prazo para assumir o exercício contado da data em que terminar o seu afastamento, vedada a assunção nesse período.

Art. 163 - O membro do Ministério Público promovido ou removido entrará em exercício no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período.

§ 1.º - O Procurador-Geral de Justiça poderá designar o membro do Ministério Público promovido ou removido voluntariamente para, no período de trânsito, que ficará suspenso, exercer suas atribuições na Promotoria de Justiça em que encerrou o exercício, visando assegurar a continuidade do serviço.

§ 2.º - Finda a designação prevista no parágrafo anterior, será restituído ao membro do Ministério Público o período de trânsito remanescente.

SEÇÃO II

DA PROMOÇÃO

Art. 164 - A promoção será sempre voluntária e far-se-á, alternadamente, por antigüidade e merecimento, de uma para ra entrância e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça.

§ 1.º - O merecimento será apurado pela atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira e para sua aferição o Conselho Superior do Ministério Público levará em conta:

I - a conduta do membro do Ministério Público na sua vida pública e particular e o conceito de que goza na comarca;

II - a operosidade, assiduidade e dedicação no exercício do cargo;

III - conceito funcional constante em assentamentos da Instituição ou apurado em inspeções permanentes, através dos Procuradores de Justiça, dos elogios insertos em julgados dos Tribunais; da publicação de trabalhos forenses de sua autoria;

IV - sua presteza e segurança nas manifestações processuais;

V - o número de vezes que já tenha constado em listas de merecimento;

VI - sua contribuição à melhoria e à organização dos serviços da Promotoria;

VII - sua colaboração ao aperfeiçoamento do Ministério Público;

VIII - o aprimoramento de sua cultura jurídica, através da participação em cursos especializados e de aperfeiçoamento, publicação de livros, teses, estudos, artigos e obtenção de prêmios relacionados com sua atividade funcional;

IX - as informações constantes nos relatórios relativos a visitas de inspeção e correição;

X - o exercício de Coordenação de Promotorias de Justiça.

Art. 165 - A antigüidade será apurada na entrância ou no cargo quando se tratar de investidura inicial.

§ 1.º - Para os fins deste artigo, considerar-se-ão as alterações ocorridas no quadro geral de antigüidade até o encerramento do prazo das inscrições, decorrentes de promoção, remoção, aposentadoria e disponibilidade.

§ 2.º - Ocorrendo empate na classificação por antigüidade, terá preferência sucessivamente:

a) o mais antigo na carreira do Ministério Público;

b) o mais antigo na entrância anterior;

c) o de maior tempo de serviço público;

d) o que tiver maior número de filhos;

e) o mais idoso.

SEÇÃO III

DA REMOÇÃO

Art. 166 - A remoção far-se-á sempre para cargo de igual entrância e poderá ser voluntária, compulsória ou por permuta.

Art. 167 - A remoção voluntária dar-se-á alternadamente, por antigüidade e merecimento, aplicando-se-lhe no que couber as disposições anteriores deste Capítulo.

Art. 168 - A remoção compulsória somente poderá ser efetuada com fundamento no interesse público e será processada mediante representação do Procurador-Geral de Justiça ou do Corregedor-Geral do Ministério Público ao Conselho Superior do Ministério Público, que decidirá por 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa, na forma desta lei e do seu regimento interno.

§ 1.º - Sem prejuízo da verificação em outros casos, será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse público determinador da remoção compulsória nas seguintes hipóteses:

I - reincidência em infração punível com pena de censura;

II - exposição de membro do Ministério Público a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da Instituição;

III - recusa, por membro do Ministério Público, de atendimento ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-Geral do Ministério Público quando em visita, inspeção ou correição;

IV - infringência às vedações previstas descumprimento do disposto no Art. 91 III, VI e XV.

§ 2.º - Decretada a remoção compulsória, o membro do Ministério Público ficará em disponibilidade, com vedações, vencimentos e vantagens do cargo, até oportuna designação do Procurador-Geral de Justiça.

§ 3.º - A vaga decorrente de remoção compulsória será provida, obrigatoriamente, por promoção.

§ 4.º - A remoção compulsória impede a promoção, por antigüidade ou merecimento, e a remoção por permuta, pelo orazo de 1 (um) ano.

§ 5.º - A remoção compulsória não confere direito a ajuda de custo.

Art. 169 - A remoção por permuta entre membros do Ministério Público dependerá de pedido escrito e conjunto, formulado por ambos os pretendentes, observado no que couber o disposto nas subseções anteriores.

§ 1.º - A remoção por permuta poderá ser indeferida pelo Conselho Superior do Ministério Público por motivo de interesse público.

§ 2.º - A remoção por permuta impede, pelo período de 1 (um) ano, a promoção por antigüidade.

§ 3.º - A renovação de remoção por permuta só será admitida após o decurso de 2 (dois) anos;

§ 4.º - Não será permitida a remoção por permuta quando um dos interessados contar com mais de 69 anos de idade ou tiver os requisitos necessários para aposentadoria voluntária.

SEÇÃO IV

DA REINTEGRAÇÃO

Art. 170 - A reintegração, que decorrerá de sentença transitada em julgado, ou de decisão definitiva em processo administrativo, é o retorno do membro do Ministério Público ao cargo, com ressarcimento de vantagens e vencimentos deixados de perceber em razão do afastamento, estes atualizados monetariamente, inclusive a contagem do tempo de serviço.

§ 1.º - Achando-se provido o cargo no qual foi reintegrado o membro do Ministério Público, o seu ocupante passará à disponibilidade remunerada, até posterior aproveitamento.

§ 2.º - O membro do Ministério Público reintegrado será submetido a inspeção médica e, se considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração.

SEÇÃO V

DA REVERSÃO

Art. 171 - Reversão é o retorno à atividade do membro do Ministério Público aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1.º - A reversão dar-se-á na entrância em que se aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser provida pelo critério de merecimento.

§ 2.º - Encontrando-se provido o cargo, o membro do Ministério Público que houver revertido, exercerá suas atribuições em auxílio como excedente, até a ocorrência de vaga.

§ 3.º - O tempo de afastamento por motivo de aposentadoria será computado, exclusivamente, para efeito de nova aposentadoria.

Art. 172 - O pedido de reversão, devidamente instruído, será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, que encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público, para deliberação.

SEÇÃO VI

DO APROVEITAMENTO

Art. 173 - O aproveitamento é o retorno do membro do Ministério Público em disponibilidade ao exercício funcional.

§ 1.º - O membro do Ministério Público será aproveitado em cargo com funções de execução iguais ou assemelhadas às daquele que ocupava quando posto em disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entrância ou categoria; ou se for promovido.

§ 2.º - Ao retornar à atividade será o membro do Ministério Público submetido a inspeção médica e, se julgado incapaz, será aposentado compulsoriamente.

CAPÍTULO III

DA OPÇÃO

Art. 174 - A elevação de entrância da comarca não acarreta a promoção do respectivo Promotor de Justiça, ficando-lhe apenas assegurado o direito de perceber a diferença de vencimentos.

§ 1.º - Quando promovido, o Promotor de Justiça de comarca, cuja entrância tiver sido elevada, poderá requerer, no prazo de 10 (dez) dias, que sua promoção se efetive na comarca onde se encontre, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2.º - A opção será motivadamente indeferida se contrária aos interesses do serviço.

§ 3.º - O disposto neste artigo não se aplica em caso de reclassificação de todas as comarcas da mesma entrância, caso em que o Procurador-Geral de Justiça expedirá os atos necessários para as adequações legais.

Art. 175 - Deferida a opção, o Procurador-Geral de Justiça expedirá novo ato de promoção e tornará sem efeito o anterior, contando-se da publicação da promoção revogada a antigüidade na entrância, seguindo-se novo concurso para provimento do cargo que então se vagar.

CAPÍTULO IV

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 176 - Os membros do Ministério Público são substituídos:

I - uns pelos outros, automaticamente, conforme escala homologada pelo Procurador-Geral de Justiça;

II - por designação do Procurador-Geral de Justiça, conforme o caso;

III - por convocação regular.

§ 1.º - Na falta de estipulação de critérios de substituição pelas Promotorias ou Procuradorias de Justiça, caberá ao Procurador-Geral de Justiça a designação.

§ 2.º - Nas sedes das circunscrições judiciárias, os respectivos Promotores de Justiça Substitutos em auxílio, independentemente de designação, substituirão os titulares, nos casos de faltas e impedimentos ocasionais.

Art. 177 - Dar-se-á a substituição automática:

I - no caso de suspeição ou impedimento, declarado pelo membro do Ministério Público ou contra ele reconhecido;

II - no caso de falta ao serviço;

III - quando o membro do Ministério Público, em razão de férias individuais, licença ou qualquer afastamento, deixar o exercício do cargo antes da chegada do seu substituto.

§ 1.º - O membro do Ministério Público deverá providenciar sua substituição automática, comunicando a ocorrência ao substituto legal, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor Geral do Ministério Público.

§ 2.º - O membro do Ministério Público que passar a exercer a substituição automática deverá comunicar o fato, imediatamente, ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 178 - O membro do Ministério Público poderá ser substituído por convocação, em caso de licença do titular de cargo da carreira ou de afastamento de suas funções junto à Procuradoria ou Promotoria de Justiça, por período superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único - O membro do Ministério Público será dispensado da convocação, a pedido, ou quando o substituído reassumir o exercício do cargo ou ainda, por conveniência do serviço, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 179 - Ocorrendo motivo para convocação, o Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, expedirá o respectivo ato.

CAPÍTULO V

DA EXONERAÇÃO

Art. 180 - Dar-se-á a exoneração:

I- a pedido;

II- de ofício, quando o membro do Ministério Público:

a- for investido em cargo ou função pública de acumulação proibida;

b- não entrar em exercício dentro do prazo legal;

c- não satisfizer os requisitos do estágio probatório.

Parágrafo único- não será concedida a exoneração ao membro do Ministério Público que esteja sujeito a processo administrativo disciplinar ou judicial para perda do cargo.

CAPÍTULO VI

DA DISPONIBILIDADE

Art. 181 - Em caso de extinção do órgão de execução da comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao Promotor de Justiça remover-se para outra Promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se estivesse em exercício.

Parágrafo único- O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer.

Art. 182 - A disponibilidade compulsória de membro do Ministério Público, que perceberá vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço, será fundamentada em motivo de interesse público e determinada pelo Conselho Superior do Ministério Público por voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, em sessão secreta.

§ 1.º - A vaga decorrente de disponibilidade compulsória será, obrigatoriamente, provida por promoção.

Art. 183 - Sem prejuízo da verificação em outros casos, será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse público determinador da disponibilidade compulsória nas seguintes hipóteses:

I - grave omissão nos deveres do cargo;

II - ocorrência de fatos que, envolvendo o membro do Ministério Público, resultem em desprestígio da instituição;

III - reduzida capacidade de trabalho, produtividade escassa, atuação funcional comprometedora ou demonstração superveniente de insuficientes conhecimentos jurídicos;

IV - induzimento dos órgãos da administração superior do Ministério Público a erro, por meio reprovável;

V - inobservância da vedação prevista no Art. 92, I.

Art. 184 - Aplicam-se ao membro do Ministério Público em disponibilidade compulsória o disposto no Art. 123, e as vedações disciplinadas no Art. 92.

CAPÍTULO VII

DA PERDA DO CARGO

Art. 185 - O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria nos seguintes casos:

I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado;

II - exercício da advocacia, salvo se aposentado;

III - abandono do cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos.

Parágrafo único - Para os fins previstos no inciso I deste artigo, consideram-se incompatíveis com o exercício do cargo, dentre outros, os crimes contra a administração e a fé pública e os que importam lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados à sua guarda.

Art. 186 - A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado, após autorização do Colégio de Procuradores de Justiça, na forma prevista nesta Lei.

Parágrafo único - Por motivo de interesse público, o Conselho Superior do Ministério Público poderá determinar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, o afastamento cautelar do membro do Ministério Público, antes ou durante o curso da ação, sem prejuízo de seus vencimentos.

TÍTULO IV

DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 187 - Pelo exercício irregular da função pública, o membro do Ministério Público responde penal, civil e administrativamente.

Art. 188 - A atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a:

I - inspeções permanentes e extraordinárias;

II - correições ordinárias e extraordinárias.

Parágrafo único - Qualquer pessoa poderá reclamar junto aos órgãos da administração superior do Ministério Público contra membros do Ministério Público.

Art. 189 - As inspeções permanentes serão exercidas pelos Procuradores de Justiça, na forma prevista no artigo 57.

Art. 190 - As inspeções extraordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando houver fatos que as justifique, independentemente de prévia designação.

Art. 191 - As correições ordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, na forma do regimento interno, para verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade, o exercício das funções, o cumprimento dos deveres do cargo e a conduta pública e particular dos membros da Instituição.

§ 1.º - A Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará, anualmente, correições ordinárias em 50% (cinqüenta por cento) das Promotorias de Justiça, no mínimo.

§ 2.º - As inspeções ordinárias em Procuradorias de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, na forma do regimento interno.

Art. 192 - As correições extraordinárias serão realizadas, de ofício, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e por determinação dos órgãos da administração superior do Ministério Público.

Art. 193 - O processo administrativo disciplinar será instaurado nos termos desta lei.

CAPÍTULO II

DAS PENALIDADES

Art. 194 - Os membros do Ministério Público estão sujeitos às seguintes penas administrativas, que constarão de seus assentamentos :

I - advertência;

II - censura;

III - suspensão por até noventa dias;

IV - cassação de disponibilidade compulsória e da aposentadoria;

V - demissão;

Parágrafo único - As penas serão aplicadas cumulativamente em caso de concurso de infrações, salvo quando, em razão de reincidência, implicar sanção mais grave.

Art. 195 - O membro do Ministério Público que praticar infração punível com censura ou disponibilidade compulsória não poderá aposentar-se até o trânsito em julgado do procedimento administrativo disciplinar, salvo por implemento de idade.

Art. 196 - A pena de advertência será aplicada por escrito, reservadamente, no caso de descumprimento de dever funcional de pequena gravidade.

Art. 197 - A pena de censura será aplicada, por escrito e reservadamente, em caso de reincidência em infração punível com pena de advertência ou se a gravidade da infração justificar, desde logo, a aplicação da pena de censura.

Art. 198 - A pena de suspensão será aplicada no caso de:

I - infrator que, já punido com censura, vier a praticar outra infração disciplinar que o torne passível da mesma pena ou se a gravidade da infração justificar, desde logo, a aplicação da pena de suspensão;

II - violação de vedação prevista no artigo 91, desta lei, com exceção do exercício da advocacia, em face do disposto no inciso II, de seu artigo 185.

Parágrafo único - Enquanto perdurar, a suspensão acarretará a perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante as férias ou licenças do infrator.

Art. 199 - A pena de cassação da disponibilidade ou de aposentadoria será aplicada se o inativo praticou, quando em atividade, falta passível da perda do cargo ou demissão.

Art. 200 - O membro não vitalício do Ministério Público estará sujeito à pena de demissão, imposta em processo administrativo no qual lhe será assegurada ampla defesa; nos mesmos casos previstos no artigo 185, desta lei, sem prejuízo do não vitaliciamento, quando for o caso.

§ 1.º - Instaurado o processo administrativo disciplinar, o membro do Ministério Público não vitalício ficará automaticamente suspenso do exercício funcional, até definitivo julgamento, sem prejuízo dos vencimentos.

§ 2.º - A demissão dar-se-á por ato do Procurador-Geral de Justiça após decisão da maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público;

§ 3.º - No caso de vitaliciamento do membro do Ministério Público sem conclusão do procedimento administrativo disciplinar, aplicar-se-á a penalidade prevista nesta lei para a infração cometida.

CAPÍTULO III

DA REINCIDÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO

SEÇÃO I

DA REINCIDÊNCIA

Art. 201 - Considera-se reincidente o membro do Ministério Público que praticar nova infração antes de obtida a reabilitação ou verificada a prescrição de falta funcional anterior.

Art. 202 - Em caso de reincidência, contar-se-ão em dobro os prazos prescricionais.

SEÇÃO II

DA PRESCRIÇÃO

Art. 203 - Prescreverá:

I - em 1 (um) ano, a infração punível com advertência;

II - em 2 (dois) anos, a infração punível com censura;

III - em 4 (quatro) anos, a infração punível com disponibilidade ou remoção compulsória.

§ 1.º - A infração disciplinar punida em lei como crime terá o prazo da prescrição deste.

§ 2.º - A instauração do respectivo procedimento administrativo disciplinar interrompe a prescrição.

§ 3.º - A verificação de incapacidade mental, no curso de procedimento disciplinar, suspende a prescrição.

§ 4.º - A prescrição não terá curso durante o período de estágio probatório.

CAPÍTULO IV

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 204 - Para efeito de aplicação das penalidades previstas nesta lei, o procedimento administrativo disciplinar será dividido em sindicância e processo disciplinar administrativo, da seguinte forma:

I - Sindicância, quando cabíveis as penas de advertência, censura e suspensão por até 90 (noventa) dias;

II - processo administrativo disciplinar, quando cabíveis as penas de cassação da disponibilidade ou da aposentadoria e de demissão.

Art. 205 - O disposto neste capítulo aplica-se, no que couber, aos servidores do Ministério Público.

Art. 206 - Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração da sindicância ou processo administrativo disciplinar:

I - de ofício;

II - por provocação do Procurador-Geral de Justiça, do Colégio de Procuradores de Justiça ou do Conselho Superior do Ministério Público;

§ 1.º - Quando o infrator for Procurador de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público instaurará e presidirá o respectivo procedimento, sempre acompanhado por três Procuradores de Justiça indicados pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 2.º - Encerrada a instrução, em caso de sindicância ou processo disciplinar administrativo, o Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório circunstanciado e conclusivo, encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 207 - Ressalvada a hipótese do parágrafo único do artigo 200 desta lei, durante a sindicância ou o processo administrativo disciplinar, o Procurador-Geral de Justiça, por solicitação do Corregedor-Geral do Ministério Público e ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, poderá afastar o sindicado ou o indiciado do exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens.

Parágrafo único - O afastamento dar-se-á por decisão fundamentada na conveniência do serviço, para apuração dos fatos, para assegurar a normalidade dos serviços ou a tranqüilidade pública, e não excederá a 60 (sessenta) dias, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado por igual período.

Art. 208 - No procedimento administrativo disciplinar fica assegurada aos membros do Ministério Público ampla defesa, na forma desta lei, exercida pessoalmente, por procurador ou defensor, que será intimado dos atos e termos do procedimento por meio de publicação no Diário Oficial.

Art. 209 - Dos atos, termos e documentos principais da sindicância e do processo administrativo disciplinar ficarão cópias, que formarão autos suplementares.

Art. 210 - Os autos de sindicância e de processos administrativos disciplinares findos serão arquivados na Corregedoria-Geral do Ministério Público.

Art. 211 - Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo disciplinar, as normas do Código de Processo Penal.

SEÇÃO II

DA SINDICÂNCIA

Art. 212 - A sindicância, para apuração das faltas disciplinares punidas na forma do artigo 194, incisos I, II e III, desta lei, será instaurado e conduzido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público de ofício, por provocação dos órgãos da administração superior do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça, bem como por representação escrita ou reduzida a termo de qualquer pessoa, atendidos os seguintes requisitos:

I - qualificação do representante;

II - exposição dos fatos e indicação das provas.

§ 1.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá delegar os atos instrutórios a um ou mais membros do Ministério Público, se de categoria funcional superior á do indiciado.

§ 2.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público designará funcionários para secretariar os trabalhos.

§ 3.º - A representação poderá ser arquivada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público se desatendidos os requisitos deste artigo ou se ela for manifestamente improcedente, dando-se ciência ao membro do Ministério Público, ao representante e ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 213 - A portaria de instauração deve conter a qualificação do sindicado, a exposição dos fatos imputados e a previsão legal sancionadora, e será instruída com os elementos de prova existentes.

Art. 214 - Compromissado o secretário e autuados a portaria e os documentos que a acompanham, o Corregedor-Geral do Ministério Público deliberará sobre a realização de provas e diligências necessárias à comprovação dos fatos e da sua autoria, bem como designará a data para a audiência de instrução em que serão ouvidos o sindicado e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, até o máximo de 3 (três) para cada uma.

§ 1.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público, na audiência referida neste artigo, poderá ouvir o denunciante se entender que a sua representação não contém suficiente exposição dos fatos.

§ 2.º - O sindicado será desde logo notificado da acusação, recebendo cópia da portaria e do despacho referido neste artigo.

§ 3.º - No prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação, o sindicado, pessoalmente ou por procurador, poderá apresentar defesa prévia, com o rol de testemunhas, oferecendo e especificando as provas que pretenda produzir.

§ 4.º - Se o sindicado não for encontrado ou furtar-se à notificação, será notificado por aviso publicado no Diário Oficial, com prazo de 3 (três) dias.

§ 5.º - Se o sindicado não atender á notificação e não se fizer representar por procurador, será declarado revel, designando-se defensor dentre os membros do Ministério Público, de categoria igual ou superior, o qual não poderá escusar-se da incumbência, sem justo motivo, sob pena de advertência.

§ 6.º - O procurador ou defensor terá vista dos autos na Corregedoria-Geral do Ministério Público, podendo retirá-los, mediante carga, durante o prazo de defesa prévia.

§ 7.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público determinará a intimação das testemunhas de acusação e de defesa, salvo se, quanto as últimas, houver expressa dispensa na defesa prévia.

§ 8.º - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá indeferir fundamentadamente provas impertinentes ou que tenham intuito meramente protelatório.

§ 9.º - O sindicado, depois de notificado, não poderá, sob pena de prosseguir o processo à sua revelia, deixar de comparecer, sem justo motivo, aos atos processuais para os quais tenha sido regularmente intimado.

§ 10 - A todo tempo o sindicado revel poderá, pessoalmente ou através de procurador constituído, substituir o membro do Ministério Público designado como defensor.

Art. 215 - Se o Corregedor Geral do Ministério Público verificar que a presença do sindicado poderá influir no ânimo do denunciante ou da testemunha, de modo que prejudique a tomada do depoimento, solicitará a sua retirada, prosseguindo na inquirição com a presença de seu procurador ou defensor.

Parágrafo único - Neste caso deverão constar do termo a ocorrência e os motivos que a determinaram.

Art. 216 - Concluída a instrução o sindicado terá 10 (dez) dias para apresentar alegações finais por escrito.

Art. 217 - A instrução deverá ser concluída no mesmo dia; não sendo possível, será designada audiência em continuação, ficando intimados todos os presentes.

Art. 218 - Finda a instrução, o Corregedor-Geral do Ministério Público terá prazo de 15 (quinze) dias para elaborar relatório conclusivo, encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 219 - O processo deverá ser concluído em 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual prazo.

Art. 220 - O sindicado será intimado pessoalmente da decisão, salvo se for revel ou furtar-se à intimação, casos em que será feita por publicação no Diário Oficial.

Art. 221 - A Corregedoria Geral do Ministério Público somente fornecerá certidões relativas à sindicância ao membro do Ministério Público, ao seu defensor, ao Procurador-Geral de Justiça, aos órgãos da administração superior do Ministério Público ou, se for o caso, àquele que tenha representado sobre o fato.

SEÇÃO III

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 222 - O processo administrativo disciplinar para apuração de infrações punidas com as penas de cassação da disponibilidade ou da aposentadoria e demissão, ou, ainda, para instruir a ação de decretação da perda do cargo de membro do Ministério Público, será instaurado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público de ofício, por provocação dos órgãos da administração superior do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça, bem como por representação escrita ou reduzida a termo de qualquer pessoa, atendidos os seguintes quisitos:

I - qualificação do representante;

II - exposição dos fatos e indicação das provas.

Parágrafo único - O processo disciplinar administrativo, presidido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, deverá estar concluído dentro de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por igual prazo.

Art. 223 - A portaria de instauração de processo administrativo disciplinar será expedida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e conterá a qualificação do indiciado, a exposição circunstanciada dos fatos imputados, a previsão legal sancionadora, indicará as provas e diligências necessárias à comprovação dos fatos e da sua autoria, designará a data para realização do interrogatório e determinará a citação do indiciado.

Parágrafo único - Na portaria poderão ser arroladas até 8 (oito) testemunhas.

Art. 224 - A citação do indiciado será pessoal, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data do interrogatório, sendo-lhe entregue cópia da portaria de instauração do processo.

§ 1.º - Se o indiciado não for encontrado ou furtar-se à citação, será citado por aviso publicado no Diário Oficial, com prazo de 10 (dez) dias.

§ 2.º - Se o indiciado não atender à citação e não se fizer representar por procurador, será declarado revel, designando-lhe defensor dentre os membros do Ministério Público, de categoria igual ou superior, o qual não poderá escusar-se da incumbência, sem justo motivo, sob pena de advertência.

§ 3.º - O indiciado, depois de citado, não poderá, sob pena de prosseguir o processo à sua revelia, deixar de comparecer, sem justo motivo, aos atos processuais para os quais tenha sido regularmente intimado.

§ 4.º - A todo tempo o indiciado revel poderá, pessoalmente ou através de procurador constituído, substituir o membro do Ministério Público designado como defensor.

Art. 225 - O indiciado será interrogado sobre os fatos constantes da portaria, lavrando-se o respectivo termo.

Art. 226 - O indiciado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados do interrogatório, para apresentar defesa prévia, oferecer e especificar provas, podendo arrolar até 8 (oito) testemunhas.

Parágrafo único - No prazo da defesa prévia, os autos poderão ser retirados mediante carga.

Art. 227 - Findo o prazo para defesa prévia, o Corregedor-Geral do Ministério Público designará data para audiência de instrução, podendo indeferir fundamentadamente as provas desnecessárias, impertinentes ou que tiverem intuito protelatório.

Art. 228 - O indiciado e seu procurador ou defensor deverão ser intimados pessoalmente de todos os atos e termos do processo, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando não o forem em audiência.

Art. 229 - Serão intimados para comparecer à audiência as testemunhas de acusação e da defesa, bem assim o indiciado e seu procurador ou defensor.

§ 1.º - As testemunhas são obrigadas a comparecer às audiências quando regularmente intimadas e, se injustificadamente não o fizerem, poderão ser conduzidas pela autoridade policial, mediante requisição do Corregedor-Geral do Ministério Público.

§ 2.º - As testemunhas serão inquiridas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e pelo indiciado ou seu defensor.

§ 3.º - Na impossibilidade de inquirir todas as testemunhas na mesma audiência, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá, desde logo, designar tantas datas quantas forem necessárias para tal fim.

Art. 230 - Encerrada a produção de provas, será concedido o prazo de 3 (três) dias para requerimento de diligências.

Parágrafo único – Transcorrido esse prazo, o Corregedor-Geral do Ministério Público decidirá sobre as diligências requeridas e poderá determinar outras que julgar necessárias.

Art. 231 – Concluídas as diligências, o indiciado terá vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias para oferecer alegações finais por escrito.

Art. 232 – Esgotado o prazo de que trata o artigo anterior, o Corregedor-Geral do Ministério Público, em 15 (quinze) dias, apreciará os elementos do processo, elaborando relatório no qual proporá justificadamente a absolvição ou a punição do indiciado, indicando a pena cabível e o seu fundamento legal, remetendo os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que proferirá decisão no prazo de 20 (vinte) dias.

§ 1.º - Se o Procurador-Geral de Justiça não se considerar habilitado a decidir poderá converter o julgamento em diligência, devolvendo os autos à Corregedoria para os fins que indicar, com prazo não superior a 15 (quinze) dias.

§ 2.º - Retornando os autos, o Procurador-Geral de Justiça decidirá em 20 (vinte) dias.

Art. 233 - O indiciado, em qualquer caso, será intimado da decisão na forma prevista no artigo 220 desta lei.

Art. 234 - Os atos e termos, para os quais não foram fixados prazos, serão realizados dentro daqueles que o Corregedor Geral do Ministério Público determinar.

SEÇÃO IV

DA REVISÃO E DA REABILITAÇÃO

SUBSEÇÃO I

DA REVISÃO

Art. 235 - A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo disciplinar, na forma determinada pelo artigo 18, XIV, alínea "b", desta lei, quando se aduzirem fatos novos ou circunstancias suscetíveis de provar a inocência do infrator ou de justificar a imposição de pena disciplinar mais benéfica.

§ 1.º - A revisão será requerida pelo próprio interessado ou, se falecido ou interdito, por cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão

§ 2.º - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito o ato punitivo ou será, se for o caso, aplicada a pena disciplinar adequada, restabelecendo-se os direitos atingidos pela punição.

SUBSEÇÃO II

DA REABILITAÇÃO

Art. 236 - O membro do Ministério Público que houver sido punido disciplinarmente com advertência ou censura poderá obter do Conselho Superior do Ministério Público o cancelamento das respectivas notas nos assentos funcionais, decorridos 2 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão condenatória, salvo se reincidente.

LIVRO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 237 - Ao membro ou servidor do Ministério Público é vedado manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau civil.

Parágrafo único - Considera-se chefia imediata, para os fins do disposto neste artigo, a subordinação administrativa direta ao membro do Ministério Público.

Art. 238 - Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral, por solicitação do Procurador-Regional Eleitoral, os membros do Ministério Público do Estado serão designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 1.º - Não ocorrendo designação exclusivamente para os serviços eleitorais, na forma prevista no caput deste artigo, o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público que oficie perante o juízo incumbido daqueles serviços.

§ 2.º - Havendo impedimento ou recusa justificável, o Procurador-Geral de Justiça designará o substituto dentro da escala de substituição automática e eventual.

Art. 239 - No âmbito do Ministério Público, para os fins do disposto no Art. 37, XI, da Constituição Federal, ficam estabelecidos como limite de remuneração os valores percebidos em espécie, a qualquer título, pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 240 - Fica autorizado o Poder Executivo a dotar a Procuradoria Geral de Justiça de sede própria, com instalações compatíveis com as suas necessidades e com a relevância da instituição.

Art. 241 - A Associação Goiana do Ministério Público, fundada em 25 de agosto de 1967, é reconhecida como entidade de representação da classe.

Parágrafo único - O Ministério Público poderá firmar convênios com a associação de classe ou entidades congêneres e assemelhadas, objetivando a manutenção de serviços assistenciais e culturais a seus membros e servidores.

Art. 242 - O Ministério Público, sem prejuízo de outras dependências, instalará as Promotorias de Justiça em salas sob sua administração, integrantes do conjunto arquitetônico dos Fóruns.

Art. 243 - No conjunto arquitetônico dos Fóruns e dos Tribunais é obrigatória a inclusão de dependências exclusivas do Ministério Público, em condições adequadas ao exercício das funções da Instituição, assegurando-se à Procuradoria Geral de Justiça vista prévia dos projetos de construção e reforma dos prédios.

Parágrafo único - A modificação de destinação das dependências, salas, gabinetes e locais de trabalho do Ministério Público, em qualquer edifício pertencente ao Estado, deve ser previamente autorizada pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 244 - A Escola Superior do Ministério Público poderá celebrar convênios ou manter outras formas de cooperação técnica com entidades afins, visando ao aprimoramento cultural e profissional dos membros e servidores do Ministério Público.

Art. 245 - Os responsáveis pelo controle interno e externo dos atos dos Poderes do Estado e de entidades da administração direta, indireta e fundacional, tomando conhecimento de qualquer infração penal ou ilícito civil público, dela darão ciência ao Ministério Público.

Art. 246 - Fica criada a Medalha do Mérito do Ministério Público, cuja concessão será regulamentada em Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 247 - O Ministério Público publicará a Revista do Ministério Público do Estado de Goiás, com a finalidade de divulgar os trabalhos jurídicos de interesse da Instituição.

Art. 248 - Salvo disposição em contrário, os prazos previstos nesta lei serão computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair em sábado, domingo, feriado, ou em dia em que não haja expediente na Procuradoria Geral de Justiça.

Art. 249 - Em todo o Estado, servirão 60 (sessenta) Promotores de Justiça Substitutos, com sede na Capital e lotados na Procuradoria Geral de Justiça, os quais exercerão as suas funções em qualquer Promotoria de Justiça do Estado.

Art. 250 - O quadro da carreira do Ministério Público é integrado pelos cargos e funções gratificadas relacionados nos Anexos desta lei, ficando acrescidos ao anexo IV da Lei n.º

13.162/97 10(dez) cargos de assessor administrativo e 10 (dez) de assessor de Procurador de Justiça, além daqueles que integram o anexo II.

Art. 251 - Ficam acrescidos em 10 (dez) e 02 (dois), respectivamente, o quantitativo dos cargos de Secretário Assistente e Assistente Programador constantes do anexos II da Lei n.º 13.162/97.

Art. 252 - A Procuradoria Geral de Justiça e os órgãos da administração superior da instituição adaptarão seus atos normativos aos preceitos desta lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contado de sua publicação.

Art. 253 - Equipara-se à residência oficial o imóvel locado para este fim pelo poder público, em decorrência de lei municipal e destinado ao membro do Ministério Público.

Art. 254 - A instalação de foros ou tribunais distritais ou regionais e de novas comarcas importará na criação dos correspondentes cargos do Ministério Público e serviços auxiliares.

§ 1.º - A proposta de criação de cargos e serviços auxiliares encaminhada à Assembléia Legislativa no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

§ 2.º - A fim de dotar as Promotorias de Justiça criadas por esta lei de serviços auxiliares, ficam acrescidos em 98 (noventa e oito) e 20 (vinte), respectivamente, o quantitativo dos cargos de Secretário Auxiliar e Oficial de Promotoria, constantes do anexo III da Lei n.º 13.162/97.

§ 3.º - Ficam criados 93 (noventa e três) cargos comissionados de Assessor de Promotoria de Justiça, com Símbolo MP1, com vencimento e representação correspondentes a R$ 223,60 (duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos) e R$ 496,39 (quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), respectivamente.

Art. 255 - O anexo VI da Lei n.º 13.162/97 passa a vigorar com as alterações estabelecidas no anexo III desta lei.

Art. 256 - Fica criada a Promotoria de Justiça Ecológica Móvel, de 3ª entrância, com atribuições a serem definidas em Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 257 - Ficam criadas na Comarca de Goiânia as Promotorias de Justiça de Atendimento Noturno, da Praça, da Saúde e a Ouvidoria do Ministério Público com atribuições a serem definidas em resolução do Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 258 - O Departamento de Recursos Humanos integrará a Superintendência de Administração, e será subdividido em Divisão de Administração de Pessoal e Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que contarão com a Seção de Cadastro e Seção de Treinamento, respectivamente.

Art. 259 - Aplica-se o disposto nesta lei ao processo administrativo disciplinar em curso.

Art. 260 - Aplicam-se ao Ministério Público do Estado, subsidiariamente, a Lei Orgânica do Ministério Público da União e o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Goiás.

Art. 261 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 262 - O vencimento do Subpromotor de Justiça em disponibilidade remunerada é fixado em R$2.000,00 (dois mil reais).

Art. 263 - São feriados no âmbito institucional, o dia nacional do Ministério Público, os domingos e os dias feriados assim considerados em leis federais, estaduais, inclusive os previstos no Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás.

Parágrafo Único – os feriados nos municípios sede de Promotoria de Justiça serão observados pelos respectivos órgãos do Ministério Público.

Art. 264 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 265 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n.º 05, de 21 de outubro de 1991 e a Lei 9.991, de 31 de janeiro de 1986 e suas posteriores alterações.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 06 de julho de 1998, 110º da República.

NAPHTALI ALVES DE SOUZA

ANEXO I

Quadro da Carreira do Ministério Público

CARGO	QUANTITATIVO
Procuradores de Justiça	36
Promotores de Justiça de 3ª entrância	198
Promotores de Justiça de 2ª entrância	47
Promotores de Justiça de 1ª entrância	76
Promotores de Justiça Substitutos	60

Promotorias de Justiça de 3ª entrância

COMARCA	QUANTITATIVO
Goiânia	93
Aparecida de Goiânia	10
Anápolis	17
Catalão	05
Ceres	03
Formosa	06
Goianésia	03
Goiás	03
Goiatuba	03
Inhumas	03
Iporá	02
Itaberaí	02
Itumbiara	07
Jaraguá	02
Jataí	06
Luziânia	07
Morrinhos	03
Porangatu	03
Quirinópolis	03
Rio Verde	08
Santa Helena	03
São Miguel do Araguaia	01
Uruaçu	03
Promotoria Ecológica Móvel	01

Promotorias de Justiça de 2ª entrância

COMARCA	QUANTITATIVO
Alexânia	01
Anicuns	01
Bom Jesus	02
Calapônia	01
Caldas Novas	03
Cristalina	03
Corumbá de Goiás	01
Crixás	01
Ipameri	02
Itapaci	01
Itapuranga	02
Jussara	02
Mara Rosa	01
Mineiros	03
Niquelândia	02
Padre Bernardo	01
Palmeiras	01
Paraúna	01
Piracanjuba	02
Pirenópolis	02
Pires do Rio	02
Pontalina	01
P	02
Planaltina	02
Rubiataba	01
São Luiz Montes Belos	02
Silvânia	01
Trindade	03

Promotorias de Justiça de 1ª entrância

COMARCA	QUANTITATIVO
Abadiânia	01
Acreuna	01
Águas Lindas de Goiás	02
Alto Paraíso	01
Alvorada do Norte	01
Araçu	01
Aragarças	01
Aurilândia	01
Barro Alto	01
Bela Vista	01
Buriti Alegre	01
Cachoeira Alta	01
Caçu	01
C Inorte	01
Campos Belos	02
Carmo do Rio Verde	01
Cavalcante	01
Cidade Ocidental	02
Corumbaíba	01
Crominia	01
Cumari	01
Edéia	01
Estrela do Norte	01
Fazenda Nova	01
Firminópolis	01
Formoso	01
Goiandira	01
Goianira	01
Goianápolis	01
Guapó	01
Hidrolândia	01
Iaciara	01
Israelândia	01
Itaguaru	01
Itajá	01
Itapirapuã	01
Itauçu	01
Ivolândia	01
Jandaia	01
Joviânia	01
Leopoldo de Bulhões	01
Minaçu	02
Montes Claros de Goiás	01
Mossâmedes	01
Mozarlândia	01
Nazário	01
Nerópolis	01
Novo Gama	02
Orizona	01
Panamá	01
Paranaiguara	01
Petrolina de Goiás	01
Piranhas	01
Rialma	01
Sanclerlândia	01
Santa Cruz de Goiás	01
Santa Terezinha de Goiás	01
Santo Antônio do Descoberto	02
São Simão	01
Senador Canedo	02
Taquaral de Goiás	01
Turvânia	01
Uruana	01
Urutaí	01
Valparaíso	02
Varjão	01
Vianópolis	01

ANEXO II

Cargos de Provimento em Comissão

Grupo Ocupacional	Categoria Funcional	Símbolo	Quantitativo
Comissionados	Coordenador de Centro de Apoio Operacional	DAS-1	10
	Coordenador de Procuradoria de Justiça Especializada	DAI-1	03
	Diretor da Escola Superior do Ministério Público	DAS-1	01
	Promotor de Justiça Corregedor	CDS-1	06
	Coordenador de Promotoria de Justiça	DAI-1	22

ANEXO III

Tabela de Vencimentos dos Cargos Efetivos

Referência	Vencimento
I	R$ 1.120,00
II	R$ 560,00
III	R$ 280,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico e dou fé que, nesta data, fica encerrado às fls. 217 o 1º volume dos autos do(a) ADI nº 3494 procedendo-se a abertura do 2º volume. Coordenadoria de Autuação, em 11 de MAIO de 2005. Eu, _____, Analista Judiciário, lavrei a presente.

TERMO DE ABERTURA

Certifico e dou fé que, nesta data, procedi a abertura do 2º volume dos autos do (a) ADI nº 3494, com início às fls. 218. Coordenadoria de Autuação, em 11 de MAIO de 2005. Eu, _____, Analista Judiciário, lavrei a presente.

Diário Oficial

Resolução

ESTADO DE GOIÁS
MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO N. 04/2005

Regulamenta os arts. 47, inciso I e 58, inciso VII da Lei Complementar Estadual nº 25, de 06 de julho de 1.998, disciplinando, no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás, as investigações criminais conduzidas diretamente por promotores ou procurador-geral de justiça

O Colégio de Procuradores de Justiça, com base no art. 18, incisos XVII e XVIII, combinado com o art.15, incisos XXXVI e XXXIX, da Lei Complementar Estadual n. 25, de 06 de julho de 1.998, regulamenta, no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás,os arts. 47, inciso I e 58, inciso VII da Lei Complementar 25/98, disciplinando as investigeções criminais conduzidas diretamente por promotores e procuradores de justiça.

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E FINALIDADE

Art. 1º. O Promotor ou Procurador-Geral de Justiça conduzirá as investigações de infrações penais de ação pública nas seguintes hipóteses:
I - Julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção não constantes das peças de informação ou do inquérito policial (art. 47 do CPP);
II - Nos casos em que a gravidade da infração e as circunstâncias assim indicarem.
Parágrafo único. A investigação conduzida por promotor ou procurador-geral de justiça não exclui a possibilidade de formalização por outros órgãos da administração Pública e não constitui pressuposto para o ajuizamento da ação penal.

CAPÍTULO II
DA INSTAURAÇÃO

Art. 2º. A portaria somente poderá ser expedida por membro do Ministério Público que tenha atribuições na área criminal correspondente ao crime investigado.
§ 1º. Havendo mais de um promotor de justiça apto à expedir a portaria, a atribuição recairá naquele em que primeiro tomar conhecimento de infração penal a ser investigada.
§ 2º. Na comarca de Goiânia, terão atribuição para expedir a portaria os promotores de justiça que atuem no Controle Externo da Atividade Policial.

Art. 3º. A decisão que indefere o requerimento de investigação criminal conduzida por promotor de justiça será apresentada ao juízo competente na forma do art. 28 do CPP.

Art. 4º. A portaria poderá ser expedida:
I - de ofício;
II - mediante requerimento, por escrito, de qualquer pessoa;
III - por comunicação de ocorrência de infração penal pública originada de autoridade.

Art. 5°. A investigação que não se alicerce em inquérito policial deverá ser iniciada mediante portaria devidamente registrada e autuada, com indicação do objeto a ser investigado e conterá, obrigatoriamente:
I - o nome e qualificação do investigado se conhecido, e o tipo penal a que esteja incurso;
II - a descrição do fato objeto de investigação ou esclarecimentos e o meio ou a forma pelo qual dele se tomou conhecimento;
III - o nome e a qualificação do autor da "notícia-crime" ou representação, se for o caso;
IV - a determinação das diligências iniciais.
Parágrafo primeiro. Se, durante a investigação for constatada a necessidade de se investigar outros fatos delituosos, o membro do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou expedir nova portaria, se afetos a sua área de atuação; ou determinar a extração de peças e remete-las ao promotor de justiça com atribuição para investigar.

CAPÍTULO III
DA INSTRUÇÃO

Art. 6°. Sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional e legalmente previstas, o membro do Ministério Público, na condução das investigações, poderá:
I - fazer ou determinar a execução de vistorias e inspeções;
II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, da União, do Estado e dos Municípios;
III - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
IV - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais;
§ 1°. O prazo fixado para resposta às requisições do Ministério Público será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento, salvo em caso de relevância e urgência ou em casos de complementação de informações.
§ 2°. Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes.
§ 3°. A notificação deverá conter a data e o número da portaria, e mencionará o fato investigado e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por advogado.
§ 4°. No exercício de suas funções, ou para assegurar o cumprimento de suas determinações, o membro do Ministério Público poderá requisitar o auxílio de força policial.

Art. 7°. O Ministério Público, na condução das investigações ouvirá o(s) investigado(s), salvo:
I - quando haja dificuldade justificada em fazê-lo;
II - em situações justificadas de urgência;
III - quando, de qualquer modo, possa acarretar prejuízo à eficácia dos provimentos jurisdicionais cautelares.
§ 1°. A oitiva do(s) investigado(s) será realizada preferencialmente ao final das investigações.
§ 2°. Na notificação, o investigado será cientificado desta condição e da faculdade de se fazer acompanhar por advogado.
§ 3.° O investigado poderá, no curso das investigações, requerer a juntada de documentos e outras diligências.

Art. 8°. As diligências serão documentadas em auto circunstanciado.

Art. 9°. As declarações e depoimentos serão tomados por termo.

Art. 10. Quando necessária, a diligência poderá ser deprecada, assinalando-se prazo razoável para cumprimento, sendo facultado ao membro do Ministério Público deprecante o acompanhamento da(s) diligência(s), com a anuência do deprecado.

Art. 11. Para fins de investigação Criminal ou ajuizamento de ação penal dela decorrente, as cópias de documentos originais poderão ser autenticadas pelo membro do Ministério Público ou servidor designado.

Art. 12. A pedido da pessoa interessada será fornecida comprovação escrita de comparecimento.

Art. 13. As investigações deverão ser concluídas no prazo de 30 (trinta) dias, permitidas, se necessário, prorrogações por iguais períodos, mediante motivação nos autos, com comunicação à Corregedoria Geral do Ministério Público.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE

Art. 14. Os atos e peças dos autos de investigação são públicos, nos termos desta Resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público.

Parágrafo Único. A publicidade consistirá:

I - na expedição de certidão, mediante requerimento da parte diretamente interessada, do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos públicos;

II - na concessão de vista dos autos, nos termos do inciso I deste artigo;

III - na extração de cópias, nos termos do inciso I deste artigo;

IV - na prestação de informações ao público em geral, a critério do promotor de justiça condutor das investigações, observados o princípio da não culpabilidade e as hipóteses legais de sigilo;

Art. 15. O sigilo das investigações poderá ser decretado pelo promotor de justiça condutor das investigações, mediante decisão fundamentada, quando a elucidação do fato exigir, observadas as garantias legais do investigado e de seu advogado.

Parágrafo Único. O sigilo em relação ao investigado ou seu advogado deverá ser decretado judicialmente.

CAPÍTULO V
DA CONCLUSÃO E DO ARQUIVAMENTO

Art. 16. A conclusão da investigação será comunicada à Corregedoria Geral do Ministério Público e o prazo para o oferecimento da denúncia será contado a partir desta data.

Art. 17. Se o promotor de justiça condutor das investigações se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação penal pública, deverá promover, fundamentadamente, o arquivamento dos autos, perante o juízo competente na forma do art. 28 do Código de Processo Penal.

Art. 18. Se houver notícia de outras provas relevantes, poderá o membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 19. O conflito de atribuições será dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos da Lei Orgânica respectiva.

§ 1°. O promotor de justiça natural poderá contar, nas investigações que conduza, com o auxílio de um ou mais promotor de justiça.

§ 2°. O auxílio deverá ser solicitado diretamente ao substituto automático ou ao procurador-geral, na hipótese de o auxílio for do Grupo de Repressão ao Crime Organizado.

§ 3° - entre membro do Ministério Público do Estado e da União.

Art. 20. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça:

I - instaurar e conduzir as investigações, podendo delega-las, quando a autoridade noticiada ou investigada gozar de prerrogativa de foro em razão da função, conforme disciplinado na Constituição da República e na Constituição do Estado de Goiás;

II - expedir e encaminhar as requisições e notificações, quando tiverem como destinatários:

a) chefe do Poder Executivo da União ou dos Estados;

b) Ministros de Estado ou Secretários Estaduais;

c) *membros do Congresso Nacional ou das Assembléias* Legislativas;

d) membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados;

e) membros do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Superiores, ou ainda dos órgãos do Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição;

f) membros do Ministério Público no último grau da carreira ou que atuem perante o Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21. Cada Promotoria de Justiça e a Procuradoria Geral de Justiça manterá controle atualizado das investigações criminais, informando os dados no relatório estatístico destinado à Corregedoria Geral do Ministério Público.

Art. 22. Os membros do Ministério Público deverão promover, no prazo de 30 (trinta), prorrogáveis por igual período se necessário, a adaptação a esta Resolução das investigações criminas em curso na respectiva Promotoria de Justiça.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA em Goiânia, 28 de março de 2005.

SAULO DE CASTRO BEZERRA
Procurador-Geral de Justiça

JOSÉ AFONSO DA SILVA
Advogado
Professor Titular Aposentado da Faculdade de Direito da USP

222

Doc nº 10

PARECER

A CONSULTA

IBCCRIM-Instituto Brasileiro de Ciências Criminais me honra formulando-me a seguinte consulta:

- **Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir investigação criminal, diretamente?**

A questão posta pela consulta não é complicada nem demanda grandes pesquisas doutrinárias, porque a Constituição Federal dá resposta precisa e definitiva no sentido de que o Ministério Público não tem competência para realizar investigação criminal direta.

1. Preliminares

1. Antes de discutir o mérito do consulta cumpre fazer alguns esclarecimentos preliminares. A primeira delas é que, aqui, não se levará em conta as questões de conveniência ou de oportunidade de se conferir ao Ministério Público poderes investigatórios na esfera penal. Isso pode ser uma discussão de *lege ferenda*, não de *lege lata*, porque a Constituição já dá a solução. Por isso, também não é pertinente discutir aqui o bom ou o mau funcionamento do sistema adotado. Sem as generalizações indevidas, injustas e injustificadas, pode-se reconhecer procedência às críticas relativas à ineficiência e a morosidade das investigações, assim como não é destituído de verdade o argumento do Ministério Público de que "Não é raro ver-se policiais que são responsáveis pela prevenção e repressão da criminalidade envolvendo-se com o crime organizado e na prática de atos de corrupção com o objetivo de impedir a

223

investigação de delitos, bem como cometendo atos de violência (p. ex.: tortura) ou abuso de poder". Esse envolvimento não é apenas da polícia. Uma das características do crime organizado está no envolvimento de autoridades públicas como um dos modos de sua ação e de sua impunidade. Não falta quem diga que o fato de a polícia estar na linha de frente da investigação criminal contribui para a contaminação de alguns de seus elementos, e não é garantido que, se o Ministério Público assumisse tal condição, ficaria imune aos mesmos riscos. Sobre esses aspectos, vale a pena transcrever a seguinte passagem de parecer que o ilustre constitucionalista Luís Roberto Barroso ofereceu ao Secretário Especial dos Direitos Humanos, Ministro Nilmário Miranda:

> "Sem a pretensão de uma elaboração sociológica mais sofisticada, e muito menos de empreender qualquer juízo moral, impõe-se aqui uma reflexão relevante. No sistema brasileiro, é a Polícia que atua na linha de fronteira entre a sociedade organizada e a criminalidade, precisamente em razão de sua função de investigar e instaurar inquéritos criminais. Por estar à frente das operações dessa natureza, são os seus agentes os mais sujeitos a protagonizarem situações de violência e a sofrerem o contágio do crime, pela cooptação ou pela corrupção. O registro é feito aqui, porque necessário, sem incidir, todavia, no equívoco grave da generalização ou da atribuição abstrata de culpas coletivas.
>
> "Pois bem: não se deve ter a ilusão de que o desempenho, pelo Ministério Público, do papel que hoje cabe à Polícia, manteria o *Parquet* imune aos mesmos riscos de arbitrariedade, abusos, violência e contágio".

2. A esse propósito, não é demais recordar o exemplo italiano. O Ministério Público brasileiro ficou muito entusiasmado com a atuação dos Procuradores italianos na chamada operação "mãos limpas", que teve inequívoco sucesso no combate aos crimes mafiosos. Como se sabe, na Itália vigorava até 1989 o juizado de instrução, quando foi suprimido, e os poderes de inquérito e de investigação concentraram-se nas mãos do Ministério Público.[1] Essa transformação proveio da legislação anti-máfia e teve impacto imediato, mas não tardou a surgirem os abusos de poder. O Procurador Di Pietro, o mais destacado membro do Ministério Público de então, teve que renunciar ao cargo em conseqüências das denúncias de desvio de poder; assim também se deu com Procuradores na Sicília. Então, a suposição do parecer do Prof. Luis Roberto Barroso é algo que a experiência já provou.

O Ministério Público no Brasil é hoje uma Instituição da mais alta consideração pública por sua atuação ética e sua eficiência que é preciso conservar e defender. E um dos modos eficazes dessa defesa consiste em mantê-lo dentro dos estritos contornos de suas funções institucionais que não inclui a função investigatória direta.

---

[1] Cf. Renaud van Ruymbeke. *Le juge d'instruction*, 3ª ed., Paris, Presses Universitaires de France (que sais-je?), 1996, p. 7.

224

3. Enfim, seja como for, o certo é que o eventual mau funcionamento do sistema de investigação criminal pela polícia judiciária, como qualquer outro defeito ou deficiência que se possa verificar, não tem a força de transferir para outra instituição sua competência constitucionalmente estabelecida, nem autoriza que outra instituição o assuma, mesmo subsidiariamente.

2. A competência para a investigação criminal

4. O signatário deste parecer, enquanto assessor na Constituinte, apoiou e, nos limites de suas possibilidades, ajudou na formulação das normas que deram ao Ministério Público a posição de destaque como instituição constitucional permanente e autônoma. Conheci do assunto desde o primeiro Anteprojeto da Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e Ministério Público, cujo relator foi o Deputado Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, oriundo da instituição, que se inspirou na organização da instituição no Anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais (Afonso Arinos), de que foi relator o então Procurador-Geral da República e hoje Ministro Sepúlveda Pertence, que mereceu o meu apoio no plenário daquela Comissão. Na elaboração desse Anteprojeto, na Constituinte, não estiveram ausentes as Associações de Ministério Público, especialmente a Associação do Ministério Público de São Paulo, que se manteve sempre presente na defesa da instituição durante a elaboração constitucional. Pois bem, o texto desse Anteprojeto (arts. 43 a 46), aprovado pela Subcomissão em 25 de maio de 1987, já continha, em essência, tudo que veio a ser contemplado na Constituição, no qual não há uma palavra que atribua ao Ministério Público a função investigatória direta. Lá estava, como função privativa, "promover a ação penal pública" e "promover inquérito para instruir ação civil pública", como estava também, sem exclusividade (art. I, "a" e "b"), "o poder de requisitar atos investigatórios criminais, podendo efetuar correição na Polícia Judiciária, sem prejuízo da permanente correção judicial" (art. 45, II, "e"); essa correição foi convertida, depois, em controle externo da atividade policial. Ora, se o Ministério Público estava interessado na investigação criminal direta seria de esperar que constasse desse Anteprojeto algo nesse sentido, já que o relator era um Constituinte afinado com a instituição. As únicas disposições aproximadas a isso vieram no *Anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo* (junho de 1987), de que foi relator o Constituinte Egídio Ferreira Lima. O art. 137, inc. V, incluía entre as funções institucionais do Ministério Público, além da competência para "requisitar atos investigatórios", também "exercer a supervisão da investigação criminal", assim como a

faculdade de "promover ou requisitar a autoridade competente a instauração de inquéritos necessários às ações públicas que lhe incumbem, podendo avocá-los para suprir omissões..". Isso se manteve no Projeto de Constituição (Comissão de Sistematização, julho de 1987, art. 233, § 3º). Já no *Primeiro Substitutivo do Relator Bernardo Cabral* (Comissão de Sistematização, agosto de 1987) , essas normas sofreram alguma transformação importante, excluindo-se a possibilidade de "promover ... a instauração de inquérito necessários às ações públicas", bem como se eliminou a possibilidade de "avocá-los para suprir omissões". Ou seja, suprimiu aquilo que o Ministério Pública hoje ainda pretende: o poder de investigação subsidiário. O texto ficou com o seguinte teor:

> "Art. 180. São funções institucionais do Ministério Público, na área de atuação de cada um dos seus órgãos:
> "VI - requisitar a instauração de inquérito policial, determinar diligências investigatórias, podendo supervisionar a investigação criminal e promover inquérito civil".

Note-se que, no *Segundo Substitutivo do Relator Bernardo Cabral* (Comissão de Sistematização, setembro de 1987), nova transformação sofreu essa competência. Nele, já não consta a faculdade de "supervisionar a investigação criminal", e "promover inquérito civil" foi para outro dispositivo, conectado com "ação civil pública" (art. 151, III: "promover inquérito civil e a ação civil... "), o que tem relevo para a interpretação da norma. Demais, a função de "requisitar a instauração de inquérito policial" e "determinar diligências investigatórias" já não é direta, mas indireta e não imperativa, como se vê da leitura do § 4º do art. 151:

> "Serão sempre fundamentadas as promoções e as cotas dos membros do Ministério Público, inclusive para requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial".

E assim foi aprovado na Comissão de Sistematização, integrando o *Projeto de Constituição "A"* (novembro de 1987), a ser submetido ao Plenário, em primeiro turno. Surgiu, então, o *Projeto Substitutivo do Centrão*, que sugeriu diversas reduções nas funções institucionais do Ministério Público, mas não foram aceitas. O texto aprovado decorreu de um acordo das lideranças, conseqüente da fusão de diversas emendas, a de n. ZP0012-0 do Constituinte Alexandre Costa, dando nova redação àquele §4º do art. 151 (supra), restabeleceu a competência direta para requisitar diligência investigatória e a instauração de inquérito policial, mas nenhuma proposta no sentido de dar ao Ministério Público função investigatória direta. O Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, defensor intransigente das prerrogativas da instituição, sustentou, na tribuna, o acordo, mostrando que "a instituição do Ministério Público foi delineada na Subcomissão do Poder Judiciário [*de que ele foi relator, diga-se, de*

sagem] com o objetivo claro de criá-la forte, autônoma, independente do Executivo. O que quer é um fiscal da lei com plenos poderes para exercer a ação penal, inclusive contra ele que o nomeia, contra o Presidente da República (...) Além dessa autonomia, um ndo aspecto básico da construção do Ministério Público foi aprovado na Subcomissão. siste em conferir à instituição atribuições maiores do que simplesmente a de perseguir os inosos: estamos dando-lhe também atribuição de defender a sociedade como um todo. nder quem não tem quem o defenda". Quem é hoje que não tem quem o defenda: O indio, tureza, o consumidor. "Por isso, todo um elenco de competências foi atribuído ao novo o Ministério Público, no âmbito da perseguição do ilícito civil". Não há uma palavra em da possibilidade do Ministério Público proceder a investigação direta.

As regras constantes do acordo vieram a integrar o Projeto de Constituição "B" (junho 988), submetido ao Plenário, em segundo turno, sendo assim aprovado, constituindo o *to de Constituição "C"*(setembro de 1988), destinado à redação final, mantido tal qual no *to de Constituição "D"* (20.9.1988), com a transposição do conteúdo do §4º do então art. ara o inc. VIII do mesmo artigo. Assim, com outros ajustes de redação, os arts. 156 a 159 ojeto aprovado em primeiro turno vieram a constituir os arts. 127 a 130 da Constituição.

5. Essas observações históricas sobre a formação constitucional da instituição não dem perqüirir a intenção do legislador constituinte para dela extrair o sentido das s. Não, esse originalismo não se compadece com os processos modernos de etação constitucional. O que vale não é a intenção do legislador, mas a intencionalidade rmas constitucionais, o que significa que o sentido de cada norma ou de cada conjunto mas se extrai do plexo de valores que foram incorporados na Constituição. Essa oração se deu por ação dos Constituintes, não pela intenção de cada um, mas pela ação da vontade constituinte, não da vontade psicologicamente identificada, mas pela e culturalmente constituída, porque vontades que agiam em função de valores, por isso acolhendo uns e recusando outros. Por isso é que a Constituição é um sistema de . Por isso também é que processos de formação constitucional tem interesse, não para retação das normas acolhidas, mas para conhecer os valores que não foram acolhidos, am rejeitados, e que, por essa razão mesma, não podem ser invocados para a ição de direitos, menos ainda de competências, tanto mais quando a competência da tenha sido outorgada a outro órgão ou instituição como é o caso, já que a ição conferiu à polícia civil estadual e federal a função de polícia judiciária e a de o das infrações penais (art. 144, §1º e 4º).

927

6. Percorram-se os incisos em que o art. 129 define as funções institucionais do Ministério Público e lá não se encontra nada que autorize os membros da instituição a proceder a investigação criminal diretamente. O que havia sobre isso foi rejeitado, como ficou demonstrado na construção da instituição durante o processo constituinte e não há como restabelecer por via de interpretação o que foi rejeitado. Se a Constituição tivesse silenciado sobre o tema, ainda se poderia discutir sobre a possibilidade de se ser a matéria conferida ao Ministério Público, por via de lei, como se fez na Itália, onde se retirou o poder investigatório do juiz de instrução, passando, por lei, para os Procuradores da República que funcionam junto dos Tribunais. Mesmo assim o Ministério Público na Itália não tem esse poder autonomamente, porque a polícia judiciária não depende dele integralmente, mas da autoridade judiciária (Constituição italiana, art. 109), pois a Constituição italiana só tem um dispositivo sobre o Ministério Público para impor-lhe o dever de exercer a ação penal (art. 112). A Constituição portuguesa tem dois artigos sobre o Ministério Público, mas não dispõe sobre sua competência, deixando para a lei (arts. 221 e 222), por isso a lei pôde integrar a polícia judiciária na organização do Ministério Público com competência exclusiva para a instrução preparatória das infrações penais.[2] Na Espanha, não é ao Ministério Público que cabe a função investigatória, só por si diretamente. Lá a função de averiguação dos delitos cabe à polícia judiciária que, no entanto, no exercício dessa função, depende do juiz, dos Tribunais e também do Ministério Público (Constituição, art. 126). Na Colômbia, sim, a Constituição dá competência direta à Procuradoria Geral da Nação (*Fiscalía General de la Nación*) para investigar os delitos e acusar os presumidos infratores ante os juízos e tribunais competentes (art. 250).

7. Essas indicações do direito estrangeiro só têm a utilidade de mostrar que o regime da matéria no Brasil é próprio, peculiar e único, porque define os campos de atuação do Ministério Público e da Polícia Judiciária com precisão, e sem dependência recíproca, de sorte que a invocação de doutrina estrangeira sobre o assunto não trás a menor contribuição ao seu esclarecimento. Nem é necessário recorrer a grandes indagações doutrinárias, diante do que está estabelecido nas normas constitucionais.

3. A doutrina dos poderes implícitos

8. No material que me foi apresentado para a elaboração deste parecer consta que o Ministério Público argumenta que, ainda que se entenda que a Constituição não lhe tenha

[2] Cf. Bismael B. Moraes, Direito e Polícia, uma introdução à polícia judiciária, São Paulo, Revista dos Tribunais.

conferido expressamente os poderes investigatórios, na esfera pena, é de ser aplicada a doutrina dos poderes implícitos, pois se a Constituição lhe assegura a competência privativa para promover a ação penal pública, deve ter-lhe também assegurado os meios para alcançar esse fim.

9. Essa concepção da doutrina dos poderes implícitos, com a devida vênia, não é correta. Primeiro, é preciso indagar se entre a investigação penal e a ação penal ocorre uma relação entre meio e fim. O meio para o exercício da ação penal consiste no aparato institucional com a habilitação, competência adequada e condições materiais, para fazê-lo.

O fim (finalidade, objetivo) da investigação penal não é a ação penal, mas a apuração da autoria do delito, de suas causas, de suas circunstâncias. O resultado dessa apuração constituirá a instrução documental - o inquérito - (daí, tecnicamente, *instrução penal preliminar*) para fundamentar a ação penal e serve de base para a instrução penal definitiva. Segundo, poderes implícitos só existem no silêncio da Constituição, ou seja, quando ela não tenha conferido os meios expressamente em favor do titular ou em favor de outra autoridade, órgão ou instituição. Se ela outorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio para atingir o fim previsto, não há falar em poderes explícitos.[3] Como falar em poder implícito onde ele foi explicitado, expressamente estabelecido, ainda que em favor de outra instituição?

10. O exemplo do constitucionalismo brasileiro se verificou no regime da Constituição de 1891, relativamente à figura do interventor, porque ela disciplinava a intervenção federal nos Estados (art. 6º), mas não previa essa entidade. Reconheceu-se, em face disso, que era legítima a nomeação de um interventor no caso de intervenção com o afastamento do Governador. O Presidente da República reivindicou essa competência. Ruy Barbosa, no entanto, argumentou em contrário, pois nem a Constituição lhe dava esse direito nem lho dava nenhuma lei do País, porque esse poder cabia ao Congresso Nacional.

"Desta arte [disse Ruy], reconhecendo que a Constituição se não ocupava com a entidade do interventor, reconhecia eu ao legislador nacional o direito de, no uso da faculdade a ele conferida pelo art. 6º, n. 2, criar por lei a intervenção e confiá-la a um interventor".[4]

Nesse texto temos duas lições importantes para a conclusão deste assunto. Primeiro, o poder implícito só ocorre quando a Constituição não se ocupa da matéria; segundo, não cabe a determinado órgão a competência que está prevista para outro.

1986, p. 75.
[3] Cf. a doutrina de Marshall e de outros constitucionalistas em Ruy Barbosa e deste mesmo, *Comentários à Constituição Federal Brasileira*, Vol. 1, São Paulo, Saraiva, 1932, pp. 190 e ss.
[4] Ob. cit., p. 195.

No caso sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema, conferindo a investigação na esfera penal à polícia judiciária, logo, ela não cabe a nenhum outro órgão ou instituição, nem, portanto, ao Ministério Público.

4. O mais e o menos em direito. Investigação seletiva?

11. Outro argumento que consta em favor da competência investigatória direta do Ministério Pública é a de que, sendo ele titular da ação penal pública, também há de ter o poder de investigação criminal, sob o argumento de que "quem pode o mais pode o menos". Se esse prolóquio tem algum valor no campo de direito privado, não sei, mas no campo do direito público, especialmente no direito constitucional, não tem nenhum valor. Não é uma parêmia a que se dá valor de regra interpretativa. O que é mais e o que é menos no campo da distribuição das competências constitucionais? Como se efetua essa medição, como fazer uma tal ponderação? Como quantificá-las? Não há sistema que o confirme. As competências são outorgadas expressamente aos diversos poderes, instituições e órgãos constitucionais. Nenhuma é mais, nenhuma é menos. São o que são, porque as regras de competência são regras de procedimento ou regras técnicas, havendo eventualmente regras subentendidas (não poderes implícitos) às regras enumeradas, porque submetidas a essas e, por conseguinte, pertinente ao mesmo titular. Não é o caso em exame, porque as regras enumeradas, explicitadas, sobre investigação na esfera penal, conferem esta à polícia judiciária, e são regras de eficácia plena, como costumam ser as regras técnicas.

12. Assim mesmo se pode discutir sobre o que é mais e o que é menos entre a *investigação* e a *ação judicial penal*. A investigação é um procedimento de instrução criminal (preliminar, preparatória) em busca da verdade e da formação dos meios de prová-la em juízo. A ação é um ato pelo qual se invoca a jurisdição penal. Procedimento da instrução penal preliminar, como qualquer procedimento, é uma sucessão de atos concatenados que se registram e se documentam no *inquérito policial*, que vai servir de base para a propositura da ação penal ou não, conforme esteja ou não configurada a prática do crime, sua autoria e demais elementos necessários à instrução penal definitiva. O resultado positivo da investigação do crime é que constituirá pressuposto da ação penal viável. Sem a investigação prévia da verdade e dos meios de prová-la em juízo é impossível a ação penal, diz bem Canuto Mendes de Almeida.[5] Pode-se estabelecer uma relação de mais e de menos entre esses elementos?

---

[5] Cf. *Princípio fundamentais do processo penal*, São Paulo, RT, 1973, p. 61. Outras partes do livro são bastante instrutiva a respeito da investigação na esfera penal, do inquérito policial e de sua função.

13. Demais, se o argumento do "quem pode o mais pode o menos", assim como o argumento, muito parecido, dos poderes implícitos, fossem procedentes, a coerência exigiria que o Ministério Público assumisse inteiramente as função investigativa. Mas não é isso que ele pretende, como mostra esta passagem de memorial apresentado a Ministros do Supremo Tribunal Federal:

> "Frise-se que o Ministério Público não pretende substituir-se, indistintamente, à Polícia Judiciária na investigação das infrações penais, mas dispor de meios para obter diretamente, de modo mais célere e eficaz, em determinadas situações e quando o interesse público o exige, as provas e informações que necessita para a formação de seu convencimento sobre a viabilidade da ação penal" (p. 24).

Esse texto é exemplar. Ele reconhece que a competência é da Polícia Judiciária. Implicitamente denuncia que o Ministério Público não tem o poder de investigação na esfera penal, senão não reivindicaria exercê-la apenas em determinadas situações. De fato, aí só se pleiteia substituir-se a Polícia Judiciária "em determinadas situações e quando o interesse público o exige". Quem decide quais são essas "determinadas situações", quem decide "quando o interesse público o exige"? O próprio Ministério Público a seu alvedrio? Isso só cria incertezas e confusão. Ora, toda investigação criminal é de interesse público. Este a exige em todos os casos em que um delito se manifesta. Qual o critério de seleção, o de maior repercussão na mídia? É certo que um dispositivo do Ato 98/96 do Ilustre Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, o mesmo que subscreve o memorial apresentado aos Eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, pretendeu estabelecer casos em que isso pudesse ocorrer. Sobre esse dispositivo, falarei mais adiante (item 20).

5. Uma competência exclusiva

14. De passagem, já me manifestei sobre o tema, nos termos seguintes: "o art. 144, § 4º, estatui que *às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, e a apuração de infrações penais, exceto as militares.* Isso quer dizer que a Constituição reservou à polícia civil estadual um campo de atividade exclusiva que não pode ser invadido por norma infraconstitucional e, menos ainda, por disposições de ato administrativo. Uma delas é a realização do inquérito policial, que constitui o cerne da atividade de polícia judiciária, que não comporta o controle do Ministério Público. ... A outra é que também à polícia civil, polícia judiciária, se reservou a função de apuração das infrações penais, o que vale dizer o

231

poder investigatório, sendo, pois, de nitido desrespeito à Constituição normas que atribuam a órgão do Ministério Público a faculdade de promover diretamente investigações como o fez o art. 26 do ato 98/96".[6]

15. Argumenta-se que a Constituição não deferiu à Polícia Judiciária o monopólio da investigação criminal. É verdade, mas as exceções estão expressas na própria Constituição e nenhuma delas contempla o Ministério Público. O próprio §4º do art. 144 ressalva a competência da União em contemplação da Polícia Judiciária Federal (art. 144, §1º) e exclui da competência da Polícia Judiciária a apuração das infrações penais militares, em harmonia com o art. 124, com base no qual cabe a polícia judiciária militar, exercida por autoridades das corporações militares, a função de apuração dos crimes militares no âmbito de cada qual, por meio de inquérito policial militar.[7]

16. Outra exceção que se costuma lembrar é a do poder investigatório das comissões parlamentares de inquérito, que também é expressa na Constituição (art. 58, §3º), mas o inquérito parlamentar não é um típico inquérito criminal, porque visa apurar fato determinado de qualquer natureza: político, administrativo, responsabilidade civil e também criminal, como se nota do final do §3º do art. 58, tanto que suas conclusões, nem sempre dispensam investigações policiais, como a experiência tem mostrado, porque, no fundo do inquérito parlamentar, se movem interesses e métodos políticos, nem sempre compatíveis com uma instrução penal preliminar, que, como nota Canuto Mendes de Almeida, invocando a lição dos grandes processualistas e da legislação, tem por finalidade preservar a inocência contra as acusações infundadas e o organismo judiciário contra o custo e a inutilidade em que estas redundariam.[8] É certo que as comissões parlamentares de inquérito realizam também atividade de investigação, e essa é a sua única função que ressalta dos seu próprio nome, investigação não tipicamente criminal, mas também criminal, e, nesse aspecto particular, pode-se ter essa investigação como exceção ao disposto no art. 144, §§1º e 4º, mas exceção expressa.

17. Num texto da lavra do ilustre processualista Antônio Scarance Fernandes, transcrito na já referida peça do Ministério Público de São Paulo, menciona-se também que "é muito comum a apuração indireta de crimes através de sindicâncias e processos administrativos". Essa idéia está conectada com a outra segundo a qual o inquérito policial é facultativo, citando-se a propósito o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal que diz que a

---

[6] Cf. Jose Afonso da Silva, "Parecer: Controle externo da atividade policial como uma das funções institucionais do Ministerio Público - Entendimento do art. 129, VII, da Constituição Federal - Conteúdo da lei complementar e seus limites constitucionais - Competências exclusivas das policias", em *Revista ADPESP*, ano 17 - n. 22 - dezembro 1998, pp. 19 e ss.
[7] Cf. *Código de Processo Penal Militar*, arts. 7º, 8º e 9º
[8] Ob. cit., p. 17

atribuição, no *caput*, da função de polícia judiciaria não exclui a de autoridade administrativa, a quem por lei seja cometida a mesma função. A questão hoje consiste em saber se uma tal *lei* se sustenta em face do art. 144, §§1° e 4°, da Constituição. Será nitidamente inconstitucional, como qualquer lei ordinária ou complementar que atribua a função de polícia judiciária, vale dizer, de investigação na esfera penal, a qualquer outra autoridade, órgão ou instituição. Ora, para membros do Ministério Público, normalmente profundos conhecedores do direito, inclusive do direito constitucional, não é sequer necessário insistir nisso.

18. A tese de que o inquérito policial é facultativo não é bem correta. O que é certo é que ele é dispensável, quando a *notitia criminis* consta de algum procedimento ou documentos com elementos suficientes para a propositura da ação penal. Os exemplos podem ser as conclusões de comissão parlamentar de inquérito e os procedimentos administrativos, ou, se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem o Ministério Público a promover a ação penal (CPP, art. 39, §5°). É nesse caso que o Dr. Scarance Fernandes disse que "e muito comum a apuração *indireta* [itálico meu] de crimes através de sindicância e processos administrativos". É *indireta*, porque não se trata de investigação criminal, mas de apuração de ilícito administrativo durante a qual se comprovou infrações penais.

19. O certo é que as exceções apresentadas estão consignadas na Constituição. Se existe lei que atribua a função de polícia judiciária a outro órgão ou instituição, ela contraria o disposto no art. 144, §§1° e 4°, da Constituição, e é inconstitucional. Em todo caso, nenhuma das exceções mencionadas, quer as consignadas na Constituição, quer as referidas em lei, beneficiam o Ministério Público. Note-se, enfim, que nem mesmo a tese de que o inquérito é "facultativo" lhe abre a possibilidade do exercício direto do poder de investigação na esfera penal, porque só o é quando existe outro meio já constituído (procedimento, documento) que, por já conter a definição da infração, de seu autor etc., o dispensa. Veja-se bem, a sua dispensa nos casos previstos não defere ao Ministério Público o poder de investigação direta.

20. Volto à questão da *investigação seletiva* n. 13 supra, para reafirmar a competência exclusiva da polícia judiciária estadual e federal, cada qual no âmbito de sua competência, para a investigação na esfera penal comum; as exceções do inquérito policial militar e de comissões de inquérito não infirmam aquela exclusividade em relação às infrações penais comuns. Não há na Constituição nada que autorize o Ministério Público a instaurar e presidir inquérito criminal. Ele o tem feito por via do inquérito civil previsto no inc. III do art. 129, com notório desvio de finalidade, já que o inquérito civil é peça de instrução preparatória da ação civil pública consignada a ele no mesmo dispositivo e não evidentemente de instrução criminal. Ou tem pretendido usar de procedimento administrativo próprio, como o art. 26 do

233

Ato 98/96 do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo definiu, com desvio ainda mais sério, porque, a toda evidência, procedimento administrativo não é meio idôneo para proceder investigações criminais diretas. O fato mesmo de se recorrer a tais expedientes demonstra, à saciedade, que o Ministério Público não recebeu da Constituição o poder para promover investigações diretas na área penal.

A propósito dessas questões, permito-me transcrever texto do meu parecer já citado antes:

"Mais contundentemente inconstitucional é o disposto no art. 26 do Ato 98/96, quando atribui ao órgão do Ministério Público a função investigatória direta. Eis o texto:

"Art 26. O órgão do Ministério Público poderá promover diretamente investigações, por meio de procedimento administrativo próprio a ser definido em Ato do procurador-geral de Justiça, ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça:

"I - se houver necessidade de providência cautelar;

"II - quando as peculiaridades do caso concreto exijam em prol da eficácia da persecução penal"

"Em essência", como lembrei naquele parecer referido, com esse dispositivo institui o Ministério Público, *sponte propria*, particular forma de inquérito, extrapolando, por certo, sua competência institucional constitucionalmente estabelecida. Acrescentei, *ipsis litteris*: "O procedimento administrativo, referido no dispositivo, é uma contrafação do inquérito civil previsto no inc. III do art. 129, da Constituição, que não pode ser transmudado em mal disfarçada forma de inquérito penal, porque tem destinação própria qual seja servir de peça informativa prévia à propositura da ação civil pública para os fins ali previstos.[9] A apuração das infrações penais é uma das atribuições exclusivas da polícia civil, que se encontra expressamente prevista no art. 144, §4º, da Constituição Federal. Não há como legitimamente passar essa atribuição para o Ministério Público por meio de ato administrativo ou de qualquer medida legislativa infraconstitucional, sem grave afronta a noras e princípios constitucionais. Vale dizer, pois, que o tal '*procedimento administrativo próprio*' é, na verdade, um expediente de invasão de competência, desprovido de base legal".[10]

21. O *Ato Normativo n. 314-PGJ/CPJ, de 27 de junho de 2003*, regulamentou o procedimento administrativo referido no citado art. 26 do Ato Normativo 98/1996. Sua ementa procura amparar sua legitimidade declarando que regulamenta, na área criminal, o procedimento administrativo previsto no art. 26, I, da Lei Federal n.8.625/1993 repetido no

[9] Nesse sentido, a Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo (Lei complementar n. 734/1993), art. 109.
[10] Cf. José Afonso da Silva, *parecer citado*, n. 21.

234

art. 104, I, da Lei Complementar Estadual n. 734/1993. Esses dispositivos, por seu turno, regulamentam o art. 129, VI, da Constituição Federal, que inclui entre as funções institucionais do Ministério Público "expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva". Nem esse dispositivo nem os daquelas leis autorizam "procedimento administrativo criminal" de que fala o art. 2º do citado Ato 314/2003. O art. 26, I, da Lei 8.625/1993 estabelece o seguinte:

"Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

"I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

"a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;

"b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

"c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos entidades a que se refere a alínea anterior".

Como se vê, esse dispositivo, repetido *ipsis litteis* no art. 104, I, da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo (Lei Complementar 104/1993), não contém nada que autorize a instauração de procedimento de investigação criminal. Ele autoriza o Ministério público, *no exercício de suas funções*, a instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, e todo o conteúdo de suas alíneas são tipicamente administrativas, ou referem-se a procedimentos tais como a sindicância administrativa, o inquérito administrativo e o processo administrativo e se destinam a apurar infrações disciplinares e eventual aplicação de sanções administrativas (Lei do Ministério Público da União, arts. 246-261, Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, art. 251), pois, procedimento administrativo não é procedimento idôneo para investigação na esfera penal, de sorte que, também nesse particular, o referido dispositivo extrapola as balizas constitucionais das funções institucionais do Ministério Público, até porque se são procedimentos, *no exercício de suas funções*, e se em suas funções não entra a investigação criminal direta, o procedimento administrativo não poderia converter-se em inquérito criminal, sob a presidência de um membro do Ministério Público como pretende o Ato 314/2003, que assim contraria regras e

235

princípios constitucionais. O art. 2º desse Ato estatui que *o membro do Ministério Público, no exercício de suas funções na área criminal, poderá, de ofício ou em face de representação ou outra peça de informação, instaurar procedimento administrativo criminal quando, para a formação de seu convencimento, entender necessários maiores esclarecimentos sobre o caso ou o aprofundamento da investigação criminal produzida.* Ora, se o membro do Ministério Público tem conhecimento de crime e não tem os elementos suficientes para a propositura da ação penal competente, o que lhe compete, de acordo com a Constituição (art. 129, VIII), é requisitar a instauração do inquérito policial, não lhe cabendo promovê-lo, por si mesmo, de ofício, ou em face de representação ou outra peça de informação. Por outro lado, se necessita maiores esclarecimentos sobre o caso ou o aprofundamento da investigação criminal produzida, não pode ele substituir a autoridade competente para efetivar a investigação (a polícia judiciária). O que lhe cabe, em tal circunstância, é também, nos termos do mesmo dispositivo constitucional, "requisitar diligências investigatórias" à autoridade competente, o presidente do inquérito policial.

Claro está que, se esse chamado "procedimento administrativa criminal" (o nome é uma contradição em termos, pois, se é administrativo não é criminal, se é criminal não é administrativo), se esse procedimento se limitasse ao "aperfeiçoamento, celeridade, finalidade e indisponibilidade da ação penal" (Ato 314/2003, art. 2º, §1º, II), ou à "prevenção e correção de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder relacionado com a atividade de investigação" (art. 2º, §1º, III) ou à "fiscalização da execução de pena e medida de segurança" (art. 2º, §1º, V), nada haveria a objetar, porque são atribuições que estão dentro das funções do Ministério Público. O que se reputa transgressor da Constituição é pretendida investigação criminal direta, naquele Ato 314/2003 encapuçada sob o manto do "aperfeiçoamento da investigação, visando à preservação ou obtenção da prova, inclusive técnica, bem como a validade da prova produzida, para fins de persecução penal" (art. 2º, §1º, IV), mas que está definido na letra "b" do art. 26 do Ato 98/96 que confere aos membros do Ministério Público (de São Paulo) o poder de estabelecer procedimentos administrativos para promover diretamente investigações criminais [ou seja, "promover diretamente investigações, por meio de procedimento administrativo próprio ... b) - quando as peculiaridades do caso concreto exijam em prol da eficácia da persecução penal"]. E isso é o que tem ocorrido na prática: órgãos do Ministério Público instauram um procedimento administrativo com o fim precípuo, não de apurar ilícitos administrativos, mas de apurar ilícito criminal, convocando supostos infratores, testemunhas etc., etc. Não se trata daquele argumento, que, às vezes, se ouve de que lhe é lícito concluir as investigações para apurar infrações penais e, sendo o caso, intentar a ação penal competente,

236

quando ele instaura um inquérito civil ou um procedimento administrativo, e, no seu desenvolvimento, encontra indício de tais infrações. Na verdade, na prática, serve-se o Ministério Público, ou do inquérito civil ou de procedimento administrativo, diretamente, como meio de proceder a investigações na esfera criminal. Como se disse antes, isso constitui um desvio de finalidade, uma fraude à Constituição que não lhe confere tal poder.

22. Há, de fato, quem sustente que, quando o Ministério Público instaura o inquérito civil como instrução prévia da ação civil pública e, no seu curso do procedimento, descobre infrações penais, estará ele autorizado a prosseguir nas investigações criminais para apurar as infrações penais possíveis. "Autorizado" por que norma constitucional? O inquérito civil é "uma investigação administrativa prévia, presidida pelo Ministério Público, que se destina basicamente a colher elementos de convicção para que o próprio órgão ministerial possa identificar se ocorre circunstância que enseje eventual propositura de ação civil pública". Esse conceito é de um ilustre jurista membro do Ministério Público, Hugo Nigro Mazzilli.[11] Em essência, é essa também a concepção do Min. Celso de Mello, emitida quando assessor do Gabinete Civil da Presidência da República. Disse ele: "O inquérito civil, em suma, configura um procedimento preparatório, destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública".[12] Se é assim, e é, não há como distorcer esse importante instrumento, para transformá-lo num inquérito policial.

A ação civil pública se destina a apurar responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros interesses difusos e coletivos, e também à proteção do patrimônio público e social (Lei 7.347/1985, art., 1°, e CF, art. 129, III). Tem como objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Lei.7.347/1985, art. 3°). Para tanto é que a lei e também a Constituição prevê o inquérito civil que não pode ser convertido (ou distorcido), nem direta nem indiretamente, em procedimento de apuração de infração penal. Se, no curso do inquérito civil ou de procedimento administrativo, se deparar com possível infração penal, seu presidente tem que remeter as peças pertinentes à polícia judiciária, nos termos do art. 129, VIII, para a instauração do competente inquérito policial, pois, repita-se, membro do Ministério Público não tem legitimidade constitucional para presidir a inquérito com o objetivo direto ou indireto de apuração de infração penal, pois a apuração de infração

---

[11] Cf. *O inquérito civil*, p. 54, apud Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, *A ação civil pública como instrumento de defesa da ordem urbanística*, Belo Horizonte, Del Rey, 2003, p. 151.

[12] Cf. em Hely Lopes Meirelles, *Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, "Habeas-data"*, São Paulo, RT, 1989, nota 2 à p. 122. Também em Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, ob. cit., p. 159.

penal, exceto as militares, é função da polícia judiciária, sob a presidência de delegado de polícia (CF, art. 144, §4º).

6. Resposta à consulta

23. Enfim, à vista do exposto, posso responder sinteticamente à consulta, nos seguintes termos:

Não. Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público não pode realizar nem presidir investigação criminal.

É o meu parecer.

São Paulo, 29 de março de 2004.

OAB/SP 13.417
RG 1.410.813-6
CPF 032 588 748-91

MIGUEL REALE JÚNIOR
Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

EDUARDO REALE FERRARI
Professor Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

238

Doc nº 14

CONSULTA

O ilustre Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Roberto Siquetto, encaminha consulta visando nossa apreciação jurídica em face dos Atos Normativos nº 314-PGJ/CPJ, de 27 de junho de 2003, e 324-PGJ/CGMP/CPJ, de 29 de agosto de 2003, editados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Afirma que, no entender daquele órgão de classe, tais atos afrontam violentamente os preceitos insculpidos no ordenamento jurídico pátrio, consultando-nos acerca da legalidade dos Atos Normativos.

Examinados os referidos Atos Normativos, passamos a dar nosso parecer:

Av. Nove de Julho, 3147 – 6º andar – Jardim Paulista – Cep. 01407-000 São Paulo – SP
Fone: (11) 3885-0822, Fax: (11) 3885-9397 reale@realeadvogados.com.br

MIGUEL REALE JÚNIOR
Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

EDUARDO REALE FERRARI
Professor Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

2
239

PARECER

I

DA MATÉRIA TRATADA PELOS ATOS NORMATIVOS Nº 314-PGJ/CPJ E 324-PGJ/CGMP/CPJ

O Ato Normativo nº 314-PGJ/CPJ, de 27 de junho de 2003, delimita as regras para instauração, realização e conclusão do denominado "procedimento administrativo criminal".

Trata-se de instituto criado nos moldes do Inquérito Policial, previsto no nosso Código de Processo Penal, permitindo ao Ministério Público do Estado de São Paulo realizar os mesmos atos da Polícia Judiciária, autorizando aos Promotores de Justiça a realização de

Av. Nove de Julho, 3147 – 6º andar – Jardim Paulista – Cep. 01407-000 São Paulo – SP
Fone: (11) 3885-0822, Fax: (11) 3885-9397 reale@realeadvogados.com.br

diligências com o objetivo de colher indícios para instruir futura ação penal.

A legalidade desse "procedimento administrativo criminal", contudo, fica sujeita a sua adequação às disposições da Constituição Federal, que contém importantes dispositivos quanto à competência dos órgãos públicos que atuam na persecução penal, à Constituição do Estado de São Paulo, que estabelece regras no tocante ao *Parquet* paulista, e ao Código de Processo Penal, que define os preceitos do Inquérito Policial em seu artigo 4°. e seguintes.

O Ato Normativo n° 324-PGJ/CGMP/CPJ, de 29 de agosto de 2003, por sua vez, institui, no âmbito das Promotorias de Justiça Criminal da Comarca da Capital, o Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GECEP. Seu objetivo é atuar nos casos de irregularidades ou infrações penais praticadas no exercício da atividade de polícia judiciária, sendo voltadas suas atividades tanto para a fase de ação penal quanto para a fase pré-processual, incluindo o acompanhamento de inquéritos policiais, procedimentos instaurados perante a Corregedoria da Polícia Civil e possíveis "procedimentos administrativos criminais" iniciados no âmbito do próprio Ministério Público.

Inquestionável o papel do Ministério Público no que tange ao controle externo da atividade

241

policial, não significando, entretanto, que se legitime o ilegal procedimento administrativo criminal, devendo o Promotor, em caso de irregularidades praticadas por policiais, tomar imediatas providências, vez que como titular da futura ação penal poderá requisitar perante a Corregedoria de Polícia o pertinente procedimento investigatório, cabendo-lhe inclusive acompanhar os atos do Corregedor Geral de Polícia, caso assim entenda pertinente, não lhe atribuindo, todavia, o poder de investigar mas sim controlar o mister policial.

II

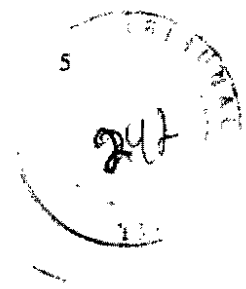
A COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA PERSECUÇÃO PENAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal de 1988 fortaleceu o Ministério Público ampliando sobremaneira suas atribuições e poderes para exercer seu papel de defensor da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

O legislador constituinte, por outro lado, também se preocupou em proteger os direitos dos indivíduos durante o processo penal estabelecendo garantias e definindo competências que, se não observadas, implicam em inconstitucionalidade do ato ou decisão.

MIGUEL REALE JÚNIOR
Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

EDUARDO REALE FERRARI
Professor Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo



Consoante o teor dos incisos VI e VIII do artigo 129 da Carta Maior:

> "*Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:*
> *(...)*
> *VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los,* ***na forma de lei complementar respectiva;***
> *(...)*
> *VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;"*

A simples leitura desses dispositivos constata que foram expressamente distinguidos os poderes do *Parquet* quando de sua atuação em procedimentos administrativos de sua competência e nos inquéritos policiais.

O inciso VI do artigo 129 da Constituição Federal de 1988 se refere expressamente a procedimentos administrativos conduzidos pelo Ministério Público, como o inquérito civil. Nessa hipótese, caso um

Promotor de Justiça necessite de elementos de prova a instruir uma ação civil pública deverá fazer uso de seus poderes a fim de lograr obter informações e documentos.

Diverso constitui o papel do Ministério Público nos casos de investigação por meio de inquérito policial.

A lei, de fato, não contém palavras inúteis. Se assim não fosse, não teriam sido diferenciados os poderes dos órgãos Ministeriais em incisos diferentes para situações diferentes.

O inciso VIII do artigo 129 da Constituição Federal trata especificamente da atuação do Ministério Público no inquérito policial e, mais ainda, a limita à requisição de diligências investigatórias e instauração de inquérito.

Tal distinção é reproduzida expressamente na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, em seu artigo 26, inciso IV - a atuação do Ministério Público no inquérito policial foi tratada em dispositivo legal específico onde fica autorizado ao *Parquet* ***somente requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar,*** *observado o disposto no artigo 129, VIII, da Constituição Federal, podendo acompanha-los.* A expedição de notificações

MIGUEL REALE JÚNIOR
Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

EDUARDO REALE FERRARI
Professor Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

7
244

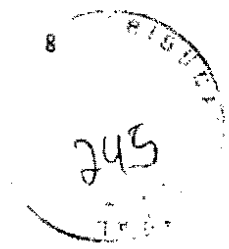
para oitiva de testemunhas e a requisição de documentos fica limitada ao inquérito civil, conforme dispõe o inciso I do mesmo artigo.

A Constituição do Estado de São Paulo, ao tratar do Ministério Público, repete em seu texto tais delimitações, sendo até mesmo mais restritiva, pois não faz referência alguma ao inquérito policial e, em relação estritamente aos procedimentos administrativos, determina em seu artigo 97, parágrafo único:

> *"Para promover o inquérito civil e os procedimentos administrativos de sua competência, o Ministério Público poderá, nos termos de sua lei complementar:*
> *1- requisitar dos órgãos da administração direta ou indireta, os meios necessários a sua conclusão;*
> *2- propor à autoridade administrativa competente a instauração de sindicância para a apuração de falta disciplinar ou ilícito administrativo."*

A criação de um denominado "procedimento administrativo criminal", nos termos do artigo 2°. do Ato Normativo 314/03, implica em violação patente à Constituição Federal vez que resulta em uma atuação do Ministério Público fora dos limites

Av. Nove de Julho, 3147 – 6° andar – Jardim Paulista – Cep. 01407-000 São Paulo – SP
Fone: (11) 3885-0822, Fax: (11) 3885-9397 reale@realeadvogados.com.br



constitucionais, o que caracteriza uma afronta à Constituição Federal de 1988.

Sobre a matéria já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça[1]:

> *"A requisição de diligências investigatórias de que cuida o art. 129, VIII, CF, deve dirigir-se à autoridade policial, não se compreendendo o poder de investigação do Ministério Público fora da excepcional previsão da ação civil pública (art. 129, III, CF).* ***De outro modo, haveria uma Polícia Judiciária paralela, o que não combina com a regra do art. 129, VII, CF,*** *segundo a qual o MP deve exercer, conforme lei complementar, o* ***controle externo*** da atividade policial."

Tal entendimento foi integralmente ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, conforma se verifica no voto do Ministro relator **CARLOS VELLOSO** no Recurso Extraordinário n° 205.473-9-AL, em acórdão publicado no DJ de 19 de março de 1999:

> *"Pode o Ministério Público, portanto, presentes as normas do inc. VIII, do art. 129, da C.F., requisitar diligências*

246

> *investigatórias e requisitar a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. As diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial deverão ser requisitadas, obviamente, à autoridade policial."*

No mesmo diapasão já decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal:

> *"Recurso Extraordinário. Ministério Público. Inquérito Administrativo. Inquérito Penal. Legitimidade. **O Ministério Público** (1) não tem competência para promover inquérito administrativo em relação à conduta de servidores públicos; (2) **nem competência para produzir inquérito penal sob o argumento de que tem possibilidade de expedir notificações nos procedimentos administrativos**; (3) pode propor ação penal sem inquérito policial desde que disponha de elementos suficientes."*[2]

---

[1] RE 76.171-AL, relator o eminente Ministro WILLIAM PATTERSON, acórdão publicado no DJ de 13 de fevereiro de 1996.
[2] Recusro Especial nº 233.072-4-RJ, relator Ministro NELSON JOBIM, decisão publicada no DJ de 03 de maio de 2002.

> *"O Ministério Público não tem competência para promover inquérito administrativo para apurar condutas tipificáveis como crimes de servidores públicos. No caso, não há dúvida de que o pedido de indiciamento do senhor Deputado Federal José Dirceu está assentado em Procedimento Investigativo com nítidas características de Inquérito Policial.*
> *O Ministério Público se substituiu à Polícia Judiciária. Essa substituição é repelida pelo STF."*[3]

Há uma estrita discriminação de funções, respeitando-se o que é peculiar da Polícia e o que incumbe ao Ministério Público no campo da persecução penal.

A persecução penal implica em constrangimentos ao indivíduo e possível restrição à sua liberdade não sendo possível se admitir uma interpretação extensiva da Constituição sob o fundamento de que *"o que não está proibido está permitido"*. O fato de o § 4° do artigo 129 não determinar expressamente que a apuração de infrações penais compete exclusivamente às polícias civis, ressalvada a competência da União, não permite que o Ministério Público se sobreponha à autoridade policial.

Destarte, a expedição de notificações e requisição de informações fica submetida pela Constituição

[3] Inquérito Policial n° 1.828-7, decisão de 01 de julho de 2002.

248

Federal a ser disciplinada por lei complementar[4], requisito formal do qual padece de forma inegável o Ato Normativo nº 314, de 27 de junho de 2003, editado pela Procuradoria Geral de Justiça e pelo Colégio de Procuradores de Justiça, jamais podendo se sobrepor à Constituição Federal e às Leis Complementares do próprio Ministério Público[5].

O que a Constituição prevê, assinala ANTONIO SCARANCE FERNANDES, constitui o acompanhamento do inquérito policial pelo Ministério Público e não a função de investigar as infrações penais, pois esta foi atribuída pela Constituição à Polícia Judiciária, sem que se estabeleça qualquer exceção a este ditame[6].

Destaque-se que em 1996 já tentou o Ministério Público por em prática tal expediente, oportunidade na qual **JOSÉ AFONSO DA SILVA considerou constituir o procedimento administrativo criminal uma contrafação do inquérito civil "*que não pode ser transmutado em disfarçada forma de inquérito policial*",**

---

[4] A Constituição Estadual de São Paulo também prevê em seu artigo 94, inciso V, que Lei Complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, disporá sobre procedimentos administrativos de competência do Ministério Público.

[5] Cf. trabalho do segundo subscritor, *Código de Processo Penal: comentários ao projeto de reforma legislativa*, Campinas: Millenium, 2003, p. 40.

[6] *Processo Penal Constitucional*, 2ª. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 243 e ss. Para o autor, no Brasil o avanço do Ministério Público em direção à investigação depende de previsão específica no ordenamento jurídico.

249

sendo a apuração das infrações penais, conforme a Constituição, uma exclusividade da polícia civil[7].

Nesse sentido já se manifestou LUIZ VICENTE CERNICCHIARO:

> *"Além disso, é tradicional, não se confundem três agentes: investigador do fato (materialidade e autoria), órgão da imputação e agente do julgamento"*[8].

A indevida realização de investigação pelo Ministério Público refoge ao âmbito da atuação interna da instituição, e termina por ferir o devido processo legal[9], ao desrespeitar a regra constitucional delimitadora das funções da Polícia e do Ministério Público, mesmo porque não deve suceder uma superposição de atribuições: se assim não fosse, as atribuições seriam conflitantes, havendo de prevalecer, pois claro o mandamento constitucional.

Consoante já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

---

[7] Parecer emitido em 16 de outubro sobre o controle externo da atividade policial, então no cargo de Secretário da Segurança Pública de São Paulo, não publicado, p. 13 e seguintes.
[8] HC 4.769-PR, acórdão publicado no DJ de 06 de maio de 1996
[9] TAVARES, Juarez. *Parecer* oferecido no Hábeas Corpus nº 001137/RJ do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, o qual foi adotado, no caso, como razão de decidir pelo relator des. SILVÉRIO CABRAL.

"A função de polícia judiciária não condiz com a titularidade da ação penal pública, que o MP bem e ciosamente resguarda.

O Ministério Público só pode, no seu âmbito, promover inspeções e diligências investigatórias, se destinadas à formação de inquéritos civis e outras medidas procedimentais (grife-se pertinentes ao inquérito civil).

As diligências investigatórias, destinadas ao inquérito policial, refogem ao âmbito de atuação interna do Ministério Público, exatamente porque devem ficar afetas a quem tenha a titularidade de instaurar esse tipo de procedimento, isto é, a polícia civil.

Assim não podia ser instaurado, no âmbito ministerial, o procedimento investigatório previsto no art. 26, inc. I da Lei 8.625 de 12/02/93, porque não se destinava ã instauração de inquérito civil".

O Ato Normativo nº 324/03, por sua vez, não só implica uma sobreposição do Ministério Público às Polícias Judiciárias como também interfere nas regras de competência interna das polícias civis, atribuindo aos Promotores de Justiça funções que não lhe são previstas

constitucionalmente vez que a investigação criminal concernente aos ilícitos praticados por policiais deve ser feita pela Corregedoria de Polícia Civil, cabendo ao Ministério Público acompanhar e requisitar a produção de prova para posterior formulação de opinião e eventual acusação.

Mesmo não sendo o inquérito policial imprescindível à propositura da ação penal, caso o Ministério Público receba peças de informação originadas em Comissão Parlamentar de Inquérito, procedimentos administrativos diversos, ou mesmo em outras ações penais, e não forem suficientes a embasar uma denúncia, as diligências necessárias deverão ser requisitadas ao Delegado de Polícia, não podendo haver sobreposição de competências legais.

Como titular da ação penal o Ministério Público pode requisitar diligências investigatórias, acompanhar o inquérito policial, exercer o controle externo da Polícia Judiciária, mas jamais realizar, sob outra e eufemística designação, o inquérito policial.

Ao nosso ver, eivados de inconstitucionalidade estão todos os pretensos poderes auto-atribuídos pelo Ministério Público e consubstanciados no artigo 7° do Ato Normativo n° 314/03 que autoriza o presidente do "procedimento administrativo criminal" a "*I - expedir notificações para colher depoimento ou*

esclarecimento e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; III - requisitar informações e documentos a entidades privadas; IV - promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere o inciso II deste artigo".

Os Atos Normativos n° 314/03 e 324/03 padecem de antinomia em seus dispositivos ao autorizarem o membro do Ministério Público, pessoalmente ou em equipe, a realizar procedimento investigatório criminal próprio, com inquirições pessoais de investigados e testemunhas, requisições de documentos, e informações e perícias, não sendo o exercício da titularidade plena da ação penal pública pelo *Parquet* fundamento suficiente a sanar tal vício.

III

DA EXIGÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

253

Os moldes dados ao Ministério Público pela Constituição Brasileira de 1988 o definiram como um órgão de amplas funções ao qual cabe principalmente a defesa do Estado Democrático de Direito.

Não constitui, portanto, o Ministério Público mero órgão acusatório, mas sim Instituição que tem entre suas diversas funções de alta relevância a titularidade da ação penal, onde sua atuação deve se dar não só com o fito de alcançar uma condenação por si só, mas também de se apurar a verdade real e a aplicação da justiça dentro da estrita legalidade[10].

A fim de exercer esse papel, devem os representantes do *Parquet* atuarem de forma imparcial, isto é, além de não terem nenhum interesse pessoal no resultado da demanda, **devem ainda estar desvinculados de quaisquer atos pré-processuais que possam influenciar seu convencimento**, garantindo-se dessa forma a igualdade das partes e o devido processo legal - princípios constitucionais invioláveis do direto processual penal.

A questão foi tratada minuciosamente por JOSÉ CARLOS FRAGOSO:

> *"Se o Procurador de Justiça se traveste de policial, pode ele adotar, desde logo, no início das investigações, um determinado*

> *ponto de vista, que tenderá a manter ao longo de todo o procedimento, tornando-se indiferente a qualquer outra alternativa probatória"*[11]

Esta pretensão ministerial de ser o dono da investigação e dono da ação penal conduz a um possível arbítrio e a busca não da prova de um fato a respeito do qual se tenha fundada probabilidade de ter ocorrido, mas sim à busca do encontro de um fato delituoso, por via do qual se possa processar alguém[12].

A predisposição conduzirá, muitas vezes, a investigação. O procedimento investigatório deve ser dirigido apenas em busca da verdade real, com vistas à colheita de elementos que permitam o exercício da ação penal da qual o Ministério Público não é investigador mas o titular da ação, não ficando isento ao se confundir quem investiga com o acusador.

Percebe-se, portanto, o quanto de razão tinha o saudoso ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO que, em

---

[10] DIAS, Jorge de Figueiredo. *Sobre os sujeitos processuais no novo Código de Processo Penal*. Coimbra: Almedina, 1992, p. 125.
[11] *São ilegais os "Procedimentos Investigatórios" realizados pelo Ministério Público Federal*, in. Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 37, ano 10, jan/mar 2002, Revista dos Tribunais.
[12] Cf. trabalho do primeiro subscritor, *O Crime de desobediência e os processos investigatórios do Ministério Público*, in. Boletim do Instituto Manoel Pedro Pimentel, nº 18, out-nov-dez/2001, p. 09-12.

255

conferência da Escola Superior do Ministério Público da Bahia[13], em 1996 assim se expressou:

> *"Em nossos dias, como se disse, pode-se constatar, através das decisões da Corte Européia dos direitos do Homem, que há uma grande preocupação em se preservar o respeito ao procés équitable e à egalité des armes, garantias que ficam seriamente ameaçadas se for permitido a uma das partes - o Ministério Público - o exercício de múltiplas funções, como a de colher, diretamente e sem controle, as provas da fase preliminar e, depois, a de emitir a opinio delicti, desencadeando a ação penal, com fulcro nas provas por ela produzidas, ao seu talante."*

Desse modo, a liberdade de defesa e igualdade de posição de partes que caracteriza o sistema acusatório[14] se fragiliza e uma das partes, o Ministério Público, assegura-se de provas de forma ilícita, na

---

[13] Conferência proferida em 26 de novembro de 1996, sob o título "*O Ministério Público e o inquérito policial*", in. Revista Brasileira de Ciência Criminais, ano 5, nº 19, jul/set 1997.

[14] MARQUES, José Frederico. *Estudos de Direito Processual Penal*. Campinas: Millenium, 2001, p. 19. O sistema acusatório exige uma paridade entre as partes sem o que, como destaca MACHADO, Nélio, não se alcança o justo processo (Notas sobre a investigação criminal, diante da estrutura do processo criminal no estado democrático, in. *Discursos Sediciosos, Crime, Direito e Sociedade*, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1988, p. 153).

colheita solitária e revestida de autoridade, sem o crivo do contraditório.

A tripartição de atribuições pela qual a Polícia investiga, o Ministério Público denuncia e o juiz julga deve ser harmônica, como se lê em acórdão[15] do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, de modo a "*nunca permitir-se que a atuação mais alargada de um implique em toldar-se a de outro, sob pena de pôr-se em risco os propósitos do equilíbrio e da gestão democrática do direito*".

Duas hipóteses indicativas da dificuldade do órgão da acusação não se transformar em órgão da condenação revelam, também, a desestabilização da relação de igualdade que deve haver entre a acusação e defesa.

A primeira deflui da credibilidade que a prova colhida fora do contraditório conduzida pelo membro do *Parquet*, pode vir a possuir, "*em homenagem à credibilidade da fonte de que emanou*"[16] sem que, no entanto, deixe de se correr o grande risco de estar viciada pela predisposição do investigador-acusador, que produz a prova solitariamente, sem o crivo do juiz e a garantia e contrariedade decorrentes da presença e participação da defesa.

---

[15] Habeas corpus nº 07.02.093315-5, relator des. Federal NEY FONSECA.

Agrava-se a situação se considerada a disposição do artigo 15, do Ato Normativo 314/03, onde se constata a ilegal possibilidade de ser decretado inclusive o sigilo do procedimento administrativo criminal, o que se repete no artigo 5°, do Ato Normativo 324/03.

A segunda situação que obstaculiza a necessária isenção e o equilíbrio entre as partes decorre da coleta de provas na fase preliminar ter se dado pelo próprio titular da ação penal, o que compromete o pedido de justo arquivamento[17] a ser requerido pela ausência de elementos colhidos nesta fase inquisitorial. Esta circunstância dificulta até mesmo a futura isenção para um pedido de absolvição, pois a presidência da investigação inicial por parte do Ministério Público contamina a imparcialidade na apreciação das provas e a busca da verdade real.

É por estas razões que o Superior Tribunal de Justiça destacou, em voto[18] da lavra do Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO que o Ministério

---

[16] MORAIS, Antonio Evaristo de. *Op. Cit.* p 108.

[17] Exemplo dessa hipótese colhe-se no fato julgado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, Habeas corpus nº 001137/RJ, no qual o segundo juiz, des. CASTRO AGUIAR, após manifestar que refoge ao âmbito do Ministério Público realizar diligências destinadas a inquérito policial ou ação penal, aborda a circunstância de o Procurador da República ter intimado o paciente para depor, sob pena de condução coercitiva. Não tendo se realizado o interrogatório, antes considerado necessário, e essencial à pesquisa da verdade, acabou-se por oferecer a denúncia sem esta prova. Diz o des. Federal CASTRO AGUIAR: "*sacrificando-se o processo pelo capricho de efetuar-se uma denúncia pelo próprio desejo da denúncia em si, sem substância alguma*".

[18] Habeas corpus n°4.769-PR, 6ª. Turma, em 03 de outubro de 1995, acórdão publicado no DJ de 06 de maio de 1996.

258

Público, como instituição, não é acusador, no sentido vulgar do termo. Se faz a imputação no entanto *"juridicamente não está contra o réu. Ao contrário, confluem interesses, a fim de evitar o erro judiciário. Busca a verdade real, a decisão justa. Em conseqüência, evidencia-se a legitimidade para recorrer em favor do réu. (...) Ministério Público e magistratura não podem estar comprometidos com o caso sub judice (...). Se um, ou outro atua na coleta de prova que, por sua vez mais tarde, será a base do recebimento da denúncia, ou do sustentáculo da sentença, ambos perdem a imparcialidade, no sentido jurídico do termo"*.

O próprio Ministério Público Federal reconhece, em parecer[19] lavrado pelo Subprocurador-Geral da República, JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA, que a impessoalidade da acusação esgarça-se quando o Ministério Público extrapola de suas funções e substitui-se à Polícia Judiciária, formulando a investigação e a denúncia, em acusações próprias dos Tribunais de Exceção.

O perigo de uma possível predisposição acusatória da qual pode vir a sofrer o representante do Ministério Público é intensificado pela própria redação dos atos normativos. O artigo 2º enunciado no Ato Normativo 324/03 estabelece que caberá aos Promotores de Justiça integrantes do GECEP atuar *"nos procedimentos administrativos criminais que iniciarem e, mediante*

259

assentimento ou solicitação do Promotor de Justiça com atribuição genérica para o feito, nas ações penais resultantes destes procedimentos". A norma em questão confunde totalmente aquele que investiga com quem acusa, desrespeitando-se princípios constitucionais.

O acúmulo das funções de investigador isento de qualquer controle e de promotor da ação penal é ressaltado por JOSÉ CARLOS FRAGOSO[20].

> *"Não é possível, porém, permitir que o Ministério Público possa acumular as funções de investigador (que a ninguém presta contas), e de instituição encarregada de promover a persecução criminal. Trata-se de um acúmulo perigoso de atribuições, que, sobre ser ilegal e inconstitucional, é absolutamente inconveniente, pelo excesso de poder, a abusos intoleráveis."*

Nesse contexto, apresenta o Ato Normativo nº 314/03 postulados totalmente em desacordo com nossa Constituição Federal e com o sistema processual penal.

---

[19] Parecer ofertado no Recurso de Habeas corpus nº 8106-DF, em 26 de novembro 1998.
[20] Op. cit., p. 244.

Arvorar-se o Ministério Público, com afronta ao texto constitucional, em inquisidor e também titular da ação penal, sem qualquer controle externo, significa ficar-se à mercê de um mesmo órgão que decide o que deve ser investigado, investiga ao seu talante, escolhe depois a provas que interessam ao embasamento da propositura da denúncia que oferece. Assim estará o Promotor ou Procurador da República comprometido, antes de mais nada, consigo mesmo[21], em vista das decisões que tomou desde a formulação inicial das investigações, distante, portanto, da exigência de impessoalidade e imparcialidade que deve, por estatuição constitucional, dirigir sua atuação.

IV

CONSEQÜÊNCIAS DA ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CRIMINAL

Verifica-se, assim, que o denominado "procedimento administrativo criminal" constitui um arremedo de inquérito policial promovido pelo próprio Ministério Público, afrontando a Constituição Federal, a

---

[21] Bem ressalva MACHADO, Nélio, que ao investigar e formular depois a *opinio delicti*, o Ministério Público estaria avaliando a própria perquirição, sua própria conduta, com envolvimento psicológico pleno e indisfarçável, assumido o papel de parte privilegiada. (in. *Notas sobre a investigação criminal, diante da estrutura do processo criminal no estado de direito democrático*, cit. p. 153)

Constituição Estadual de São Paulo, o Código de Processo Penal e a Lei nº 8.655/93, inferindo-se que as ordens emanadas pelo Ministério Público no exercício indevido das atribuições de Polícia Judiciária são inconstitucionais e ilegais, não tendo validade suas requisições, intimações ou determinações de perícia.

Nesta perspectiva, os elementos coligidos no "procedimento administrativo criminal" são efetivamente imprestáveis, pois seria, efetivamente, uma *contradictio in terminis* que um meio inconstitucional e ilícito de produção de provas pudesse gerar provas válidas a serem impostas contra um imputado.

Por outro lado, não só provas coletadas de forma ilícita, por meio de procedimento ilegal são imprestáveis, mas também outras provas delas derivadas acabam por ser contaminadas de ilegalidade, cabendo razão a LUIS ALBERTO MACHADO[22] ao considerar que se aplica à hipótese a "doutrina da árvore envenenada", visto dever-se estender o vício também aos frutos da árvore. No caso, o inconstitucional "procedimento administrativo criminal" realizado pelo Ministério Público contamina não só as provas nele coletadas, mas também informações eventualmente decorrentes do teor destas provas, como assinala o Supremo Tribunal Federal[23].

---

[22] MACHADO, Luis Alberto. In. *Parecer* ofertado à Associação dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Paraná, em 09 de setembro de 1996.

Preleciona com acuidade ADA PELLEGRINI GRINOVER acerca do repúdio do ato inconstitucional em todos os seus resultados, ainda que indiretos[24]. O Supremo Tribunal Federal tem entendido ser inadmissível até mesmo a prova ilícita por derivação.

ADA PELLEGRINI GRINOVER afirma a inadmissibilidade de provas obtidas contra a Constituição Federal, o que diz respeito não só a violação de uma norma constitucional expressa, mas também, de um princípio geral acolhido pela Constituição[25]. Ora, a colheita de provas pelo Ministério Público afronta dispositivos da Carta Maior e o princípio do devido processo legal, com a obtenção enquanto parte, de prova sem o contraditório, revestido o "investigador" de imensa autoridade e poder coercitivo.

Por estas razões, a inconstitucionalidade e ilegalidade das provas obtidas diretamente pelo Ministério Público fazem-nas imprestáveis, conduzindo a não poder ter validade qualquer ato no bojo do "procedimento administrativo criminal".

V

CONCLUSÃO

---

[23] Habeas corpus nº 69.912-RS, relator SEPÚLVEDA PERTENCE.
[24] GRINOVER, Ada P.. *Liberdades públicas e processo penal*. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 163.

Após a análise dos Atos Normativos nº 314/03 e 324/03 e sua oposição frente à Constituição Federal, à Constituição Paulista, ao Código de Processo Penal e à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, outra conclusão não há senão a de que tais Atos são inconstitucionais e ilegais no que tange ao "procedimento administrativo criminal".

Ao se atribuir poderes aos Promotores de Justiça para que realizem procedimento nos moldes do inquérito policial, diferenciando-se somente sua nomenclatura, está-se violando as rígidas disposições da Carta Maior que definem as competências e atribuições dos órgãos estatais que atuam na persecução penal, desestabilizando-se, também, toda a estrutura processual penal que busca conciliar a repressão penal do Estado à observância dos direitos e garantias individuais inerentes ao Estado Democrático de Direito.

A existência do "procedimento administrativo criminal" conduz, assim, ao comprometimento do próprio papel do Ministério Público na sociedade brasileira ao tentar justificar pelos seus fins um procedimento ilegal e abusivo cuja recepção é impossível pelo ordenamento jurídico pátrio.

---

[25] Op. cit. p. 189.

Inadmissível, por outro lado, que a Polícia Judiciária seja ilegalmente afastada de seu papel de órgão estatal que realiza com exclusividade investigações criminais por uma norma que contém tanto graves vícios, quer formais, pois a matéria deveria ser regulada por lei complementar, quer materiais, vez que contraria frontalmente normas hierárquicas superiores.

Indubitavelmente, as medidas penais investigatórias previstas na Constituição Federal são de exclusiva pertinência da Polícia Judiciária, figurando ilícitas as provas obtidas por meio desses "procedimentos administrativos criminais", cuja recusa pelo Judiciário é de rigor, em razão de sua flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade.

Em face dos argumentos apresentados, plenamente legítima a propositura de mandado de segurança coletivo por parte do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, contra os atos do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Paulista, nos termos dos artigos do artigo 5°, incisos LXIX e LXX, aliena "b", da Constituição Federal.

A simples edição dos Atos Normativos n° 314/03 e 324/02 implica em abuso de poder a causar dano imediato e concreto ao interesse global de toda uma categoria, vez que diretamente violado o direito exclusivo dos Delegados de Polícia de presidirem procedimentos

265

investigatório criminais. A existência de violação a direito líquido e certo é inquestionável, mostrando-se o mandado de segurança coletivo como via adequada para fazer cessar os efeitos dos Atos Normativos nº 314/03 e 324/03.

A fim de não restar qualquer dúvida quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade, tanto no âmbito federal quanto estadual, dos Atos Normativos ora discutidos, indicativa também é a propositura de ação direta de inconstitucionalidade contra os referidos Atos do Ministério Público, a ser proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no artigo 667, inciso V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, e no artigo 90 da Constituição do Estado de São Paulo, estando o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo devidamente legitimado, formal e substancialmente, para propor a ação constitucional com o objetivo de excluir em caráter definitivos tais normas do ordenamento jurídico.

Este é o nosso parecer.

São Paulo, 21 de outubro de 2003.

MIGUEL REALE JÚNIOR

EDUARDO REALE FERRARI

Av. Nove de Julho, 3147 – 6º andar – Jardim Paulista – Cep. 01407-000 São Paulo – SP
Fone: (11) 3885-0822, Fax: (11) 3885-9397 reale@realeadvogados.com.br

AS FUNÇÕES DO MP E O INQUÉRITO POLICIAL*

"Na VIII Conferência Estadual apresentei moção no painel *Poder Judiciário, Advocacia e Ministério Público – A Reforma*, proclamando a ilegitimidade de verdadeiros *inquéritos policiais* instaurados e dirigidos, diretamente, pelo Ministério Público, inclusive com a colheita de depoimentos de testemunhas e interrogatórios de suspeitos da prática de infrações penais.

Esta moção visou a despertar a consciência jurídica para os riscos, à luz do sistema processual brasileiro, de um insustentável alargamento das atribuições do *parquet* no campo da investigação criminal. Recentemente, em caso rumoroso, o Ministério Público Federal intimou um cidadão, para ouvi-lo na sede da Procuradoria da República, a respeito de fatos que já eram objeto de inquérito na Polícia Federal, onde o mesmo figurava como indiciado. Seguindo orientação de seu patrono, ele negou-se a atender à inusitada intimação, esclarecendo, através de petição, cuja cópia remeteu à Justiça Federal, os motivos legais de sua recusa. Apesar disto, um dos fundamentos do pedido de prisão preventiva, formulado depois do não comparecimento do indiciado para depor na Procuradoria da República, foi exatamente esta pretensa rebeldia, que, também, se erigiu como uma das bases do decreto que impôs a custódia provisória, mais tarde desconstituído por *habeas corpus*, precedido da concessão de medida liminar pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De qualquer forma, este cidadão ficou preso durante cerca de uma semana porque, entre outras razões, teria se negado a cooperar para o esclarecimento dos fatos, ao deixar de atender à intimação que lhe fora dirigida pelo Ministério Público.

Este é um pálido exemplo da importância, no campo das liberdades públicas, da matéria apresentada na VIII Conferência, ainda mais porque, também, o Ministério Público Estadual, invocando a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625/93, art. 26, I), vem pretendendo instaurar o que denomina, eufemisticamente, *procedimentos investigatórios* (leia-se inquéritos policiais), objetivando instruir futuras ações penais, ou lastrear pedidos de prisão preventiva, ou de busca e apreensão, ou outras medidas preliminares excepcionais, que atingem garantias asseguradas na Constituição Federal (v.g., sigilos bancário e das comunicações telefônicas).

No texto supra noção procurou-se demonstrar que o art. 26 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, por este invocada para embasar sua atuação investigatória direta, não confere ao *parquet* tal atribuição, reservada pela Carta de 88 às polícias civis, estaduais e federais, a quem conferiu a incumbência de cumprir o papel da polícia judiciária (CF, art. 144 e parágrafos).

Com efeito a Constituição, no art. 129, III, arrola entre as "funções institucionais do Ministério Público", a de "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público, etc." E no item VI do mesmo artigo faculta ao Ministério Público a expedição de "notificações nos procedimentos administrativos **de sua competência**". Já no item VIII, ao cuidar da matéria penal, fala do poder de "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial".

Por seu turno, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625, cit.), quando regulamenta estes dispositivos, reitera, no art. 26, I, a faculdade de "instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos **pertinentes**, admitindo que, "**para instruí-los**", se possa "expedir notificações para colher depoimentos, e em caso de não comparecimento injustificado requisitar condução coercitiva, etc." (art. 26, I, "a").

Assim, uma das funções do Ministério Público é promover o inquérito civil que se destina a colher elementos que permitam instruir a ulterior ação civil pública, a qual tem por objeto a "proteção, prevenção e reparação de danos" causados a determinados bens e interesses (v.g. meio ambiente, bens e direitos de valor artístico, etc.), e também visa obter a anulação de atos lesivos ao patrimônio público (art. 25, IV, "a" e "b", L. 8.625).

Somente em outro item, de número IV, o art. 26, trata da matéria penal, quando permite ao Ministério Público "requisitar à autoridade diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, e de inquérito policial militar (...), podendo acompanhá-los". Também no direito anterior (Lei Complementar nº 40/81), a única hipótese em que era cometida ao Ministério Público a incumbência de promover, diretamente, os atos do inquérito, ocorria quando o Procurador Geral avocava "excepcionalmente e fundamentadamente, inquéritos policiais em andamento", **onde não houvesse delegado de carreira** (art. 7º, VII).

O relevante é que, em face do texto constitucional vigente e o da Lei Orgânica que o regulamentou, parece claro que se adotou um critério diferenciado em matéria de investigações preparatórias: no campo civil, cabe ao Ministério Público instaurar o **inquérito civil** ou outros procedimentos administrativos pertinentes, no curso dos quais permite-se que realize diretamente diligências, inclusive a colheita de depoimentos (item I e alíneas do art. 26, cit.); já em sede penal, matéria prevista em item diverso (IV) do mesmo art. 26, é-lhe facultado meramente **requisitar** diligências ou a abertura de inquéritos, "podendo acompanhá-los". Aliás, é atribuição do Procurador-Geral de Justiça designar Membros do Ministério Público para "acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória" (art. 10, IX, "e", da Lei nº 8.625, cit.).

Entretanto, apesar desta diferenciação fixada nos textos ora invocados, o Ministério Público, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, nas esferas federal e estadual, está querendo adquirir o vezo de promover, **diretamente**, investigações preliminares, expedindo notificações e

Doc nº 12

tomando depoimentos, numa verdadeira usurpação das atribuições da autoridade policial, a quem a Constituição, como se viu, comete as funções de polícia judiciária (art. 144, § 1º, IV e § 4º).

Seria sem dúvida de extrema valia que o Ministério Público acompanhasse as diligências investigatórias e os inquéritos realizados pelas autoridades policiais, ainda mais porque isto traduziria, de alguma forma, o exercício do controle externo da atividade policial. Porém, a faculdade de o Ministério Público produzir, direta e pessoalmente, sem qualquer controle, as peças de informação que virão a servir, no futuro, de base para o oferecimento de denúncia, ou para o pedido de arquivamento, conferiria a este órgão um arbítrio incontrastável, no exercício da função de promover a ação penal, que lhe é privativa.

Em linhas gerais, à luz do direito comparado, coexistem dois sistemas no tocante às atribuições da Polícia e do Ministério Público, na fase das investigações preliminares, correspondente ao nosso inquérito policial. De um lado, há o sistema inglês, pelo qual a colheita preparatória de provas é confiada tão só à polícia. De outro, na maioria dos países da Europa continental, cabe ao Ministério Público dirigir e até efetuar, diretamente, as investigações.

Entre os dois sistemas – o inglês e o continental – o legislador brasileiro optou por aquele que estabelece uma diferenciação de tarefas, incumbindo à polícia a realização do inquérito, ainda que admitida certa vigilância por parte do Ministério Público, a quem ficou atribuída a função de promover a ação pública, em regra com assento nos elementos coligidos pela polícia judiciária.

Assinala o emérito Tourinho Filho, citando o saudoso mestre Frederico Marques, "que a *persecutio criminis* apresenta dois momentos distintos: o da investigação e o da ação penal", cabendo ao Ministério Público "ajuizar a ação penal" ("Processo Penal", Vol. 1, 11ª ed., 1989, p. 167). Pondera, a seguir, Tourinho que "*para o órgão do Ministério Público poder levar ao conhecimento do Juiz a notícia sobre um fato infringente da norma, apontando-lhe o autor é intuitivo tenha em mãos os elementos comprobatórios do fato e da respectiva autoria. E como consegui-los? Para isto, o* ***Estado criou outro órgão****, incumbido dessa missão. É a Polícia Judiciária, cuja finalidade é a de investigar (...). Feita essa investigação, as informações que a compõem são levadas ao Ministério Público, a fim de que este, se for o caso, promova a competente ação penal*".

Em diversas passagens subseqüentes de sua obra, o celebrado processualista enfatiza ser da polícia judiciária a atribuição de desenvolver o primeiro momento da atividade repressiva do Estado, desempenhando "uma fase primária da administração penal" (p. 169), oportunidade em que realiza "uma série de diligências, tais como: (...) interrogatórios, depoimentos, acareações, reconhecimentos que, reduzidos a escrito ou datilografados, constituem os autos do inquérito policial", que são encaminhados a juízo, "a fim de que o Estado, por meio de outro órgão próprio, que é o Ministério Público, sobre eles se manifeste, ou iniciando a ação penal com o oferecimento da denúncia, ou requerendo o arquivamento, etc." (pgs. 170/1).

Este critério de atribuir, na *persecutio criminis*, funções diferenciadas a dois órgãos distintos é o que melhor se coaduna com o **sistema acusatório**, que os estudiosos, de uma forma geral, consideram mais eficaz do que o **sistema inquisitório**, no tocante ao resguardo das garantias do cidadão em face do poder persecutório do Estado.

Em nossos dias, como se pode constatar, através das decisões da Corte Européia dos Direitos do Homem, há uma grande preocupação em preservar-se o respeito pelo *procès équitable* e pela *egalité des armes*, garantias que ficam seriamente ameaçadas se for permitido a uma das partes – o Ministério Público – o exercício das múltiplas funções, como as de colher, diretamente e sem qualquer controle, as provas da fase preliminar, e de emitir, depois, a *opinio delicti*, desencadeando a ação penal, com fulcro nas provas por ela própria produzidas, ao seu puro arbítrio.

Ademais, sob o aspecto **institucional** esta faculdade de o Ministério Público produzir, diretamente, a prova da fase preliminar da *persecutio* implicaria outorgar-se a este órgão um poder incontrolável em matéria de arquivamento das peças de informação. Com efeito, basta imaginar-se que, num determinado caso, o Ministério Público efetuasse, na fase preliminar, toda colheita da prova, dando-lhe, intencionalmente, ou não, um direcionamento favorável ao indiciado. Logo a seguir, na etapa processual subseqüente, em face da fragilidade ou insuficiência dos elementos que ele próprio coligira, pediria o arquivamento das peças, arquivamento que se tornaria **obrigatório**, mesmo em face da eventual discordância do juiz, caso o Procurador Geral ratificasse a *opinio* de seu subordinado (art. 28, CPP). Assim, em questão de arquivamento, estaria instalada uma verdadeira ditadura do Ministério Público, com sério comprometimento do princípio da obrigatoriedade da ação penal.

Aliás, recentemente, e sob os mesmos fundamentos adotados na moção, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deste Estado, em decisão relatada pelo ilustre magistrado Sílvio Teixeira, concedeu *habeas corpus* impetrado pelos advogados Wilson Lopes dos Santos e Nélio Machado, que tem a seguinte ementa:

"A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, são privativas das polícias civis. Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua atribuição não passa do poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar. Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e de outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, aqui incluídas as diligências investigatórias".

Contra esta decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial, restando-nos aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça."

* Dr. Antônio Evaristo de Moraes Filho – Tribuna do Advogado – OAB-RJ – Edição de nov/96.

368

O Ministério Público e a Investigação Criminal

Luís Guilherme Vieira



OABRJ
2004

APRESENTAÇÃO

369

O legislador constituinte de 1988 elevou o Ministério Público, de simples fiscal da lei e titular exclusivo das ações penais públicas, a verdadeiro representante da sociedade civil, outorgando-lhe outros poderes, tais como os elencados no art. 129 da Carta Magna. Ampliou-se seu campo de atuação, atribuindo-lhe zelar pelo efetivo respeito pelos Poderes Públicos aos direitos assegurados na Constituição, dando-lhe competência para promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, para promover a ação de inconstitucionalidade, ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, a defesa das populações indígenas, a expedição de notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, bem como a requisição de informações e documentos para instruí-los. No que tange à atividade policial, converteu a Constituição o Ministério Público em órgão de seu controle externo.

A competência para apuração das infrações penais, instauração e processamento dos inquéritos policiais continuou como atribuição exclusiva dos organismos da Polícia Federal e das Polícias Civis Estaduais, nos termos do art. 144 da Constituição Federal.

Concernentemente aos inquéritos policiais, atribuiu a Constituição ao Ministério Público, apenas, o poder de requisitar diligências investigatórias, bem como requerer sua instauração. Não quis o legislador constituinte, com a minudência como a matéria foi tratada, conceder ao Ministério Público poderes concorrentes com os organismos policiais para a instauração e processamento dos inquéritos policiais.

Não obstante a clareza do texto constitucional, pretenderam alguns segmentos do Ministério Público que tais atribuições, privativas da polícia, também lhes estivessem delegadas, emprestando interpretação extensiva ao disposto no art. 129, VIII, do texto maior.

Desde o surgimento de tal interpretação, levantaram-se várias vozes dos operadores de direito denunciando a irregularidade, uma vez que, se consumada, colocaria a parte integrante do pólo ativo da ação penal em posição de supremacia em relação à defesa, já que, comandando a investigação, moldaria, a seu talante, a denúncia, peça de impulso da ação penal, da qual o órgão ministerial é titular exclusivo.

De se lembrar a pioneira manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 1997, na VIII Conferência Estadual, que aprovou

célebre tese capitaneada pelo inesquecível Professor Antonio Evaristo de Moraes Filho, no sentido de que:

"Por força do sistema adotado pelo Direito brasileiro, o Ministério Público não pode substituir-se à Polícia Judiciária e promover, ele próprio, o inquérito policial, ou procedimento equivalente, para com base no mesmo, formar sua opinio delicti. No máximo, é facultado ao Ministério Público dispensar o inquérito e embasar a denúncia em peças de informação, que não tenham sido produzidas por ele, eis que nem a parquet a de instaurar inquérito para efeitos penais. Para lastrear a expedição de notificações, visando a colher depoimentos de testemunhas e de suspeitos da prática de infrações penais, vem sendo invocado pelo Ministério Público o art.26, I da Lei Orgânica. Este dispositivo, no entanto, diz respeito à instalação e atos probatórios do inquérito civil, sendo o inquérito de natureza criminal previsto em outro item, em que se faculta ao Ministério Público requisitar a sua instauração e acompanhar as diligências (item IV, art. 26). Assim, nesta VIII Conferência Estadual da OAB-RJ, é de proclamar-se a absoluta falta de base legal dos procedimentos investigatórios que o Ministério Público vem pretendendo realizar diretamente, para efeitos penais, em substituição ao inquérito policial."

A matéria, já deslindada pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal em prol da escorreita interpretação dos dispositivos constitucionais, está em vias de por termo a controvérsia, mas o debate continuará aceso.

Esta publicação que a Ordem dos Advogados do Brasil-Seção do Estado do Rio de Janeiro traz a lume tem o objetivo de realçar as posições assumidas pelos advogados em prol da estrita observância do texto constitucional, sobretudo sabendo-se do trâmite de emenda constitucional que pretende dar ao Ministério Público o que não lhe quis dar o legislador constituinte originário.

Espera a Ordem dos Advogados do Brasil-Seção do Estado do Rio de Janeiro contribuir para o debate e compreensão da temática em discussão, sem paixões, mas firme na defesa dos princípios internacionalmente aceitos de igualdade das partes no processo, o que estaria violado se fosse permitido ao Ministério Público o poder de instaurar as investigações criminais.

OCTAVIO AUGUSTO BRANDÃO GOMES
Presidente da OAB-RJ

270

Luís Guilherme Vieira,
advogado criminal. Coordenador-Executivo e
Professor do Curso de Especialização
em Advocacia Criminal
da Universidade Candido Mendes (RJ e PR).
Ex-Secretário-Geral do Instituto
dos Advogados Brasileiros.
Membro da Associação Internacional
de Direito Penal. Fundador e
Conselheiro do Instituto
de Defesa do Direito de Defesa.

O Ministério Público e a Investigação Criminal*

Vieira, Luís Guilherme

O Ministério Público e a Investigação Criminal / Luís Guilherme Vieira -

Rio de Janeiro: Editora Rabaço Ltda., Ano 2004. 68p.

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro.

SUMÁRIO

1. Introdução 1

2. O STF: *O leading case* 2

3. Breve esforço histórico 4

4. Ministério Público investigante: vedação constitucional e infraconstitucional 9

5. A palavra do Ministério Público ainda vale? 13

6. Afinal de contas, quem pode o mais, pode o menos? 16

7. Só a polícia judiciária investiga crime? 19

8. Dos (legítimos) poderes institucioanais do Ministério Público 26

9. Dos (inconstitucioanais e abusivos) poderes institucionais do Ministério Público 29

10. Membros do *Paquet* chancelam: Ministério Público não tem competência para investigar crimes 37

11. A jurisprudência. A (futura) decisão do Pleno do STF 39

12. O sistema processual penal do século XXI: o que se pretende? 43

13. Uma (posssível) conclusão: mas será permitido concluir? 51

O Ministério Público e a investigação criminal*

272

"(...) a repressão à criminalidade é uma necessidade imperativa de qualquer sociedade. Deve ser efetivada com presteza, seriedade e rigor. Mas há limites muito nítidos. (...) Qualquer transigência, aqui, é o sacrifício do Direito no altar das circunstâncias."[1]

1. Introdução

A partir da promulgação da Carta da República de 1988, o Ministério Público, lastreado em fundamento que dizem lhe dar supedâneo legal, vem, amiúde, realizando diretamente investigações criminais (principalmente, como se vê no cotidiano forense, naqueles emblemáticos casos midiáticos ou

* Este artigo, aprofundado a partir de versão apresentada, na 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, realizada em Brasília, em 19.11.2003, é dedicado à memória de José Carlos Fragoso que nos deixou, em 21.11.2003, com apenas 49 anos de vida. Zeca foi um dos mais notáveis advogados criminais de minha geração. Por certo, de onde estiver, continuará a combater as grandes causas públicas.

Agradecemos ao Prof. Dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho que, ao rever o presente ensaio em sua forma original, procedeu acurada revisão e nos trouxe importantes contribuições.

Este artigo foi publicado na RIBCCrim nº 46, janeiro-fevereiro de 2004, Ano 12, pp. 307-370.

[1] BARROSO, Luís Roberto. "O país das provas ilícitas". *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro.

naqueloutros em que a opinião pública, que difere da opinião publicada, rotula como gravoso), sem requisitar, à autoridade policial, a instauração de inquérito. Sustentam, em síntese apertada, que, sendo os titulares da ação penal pública, não podem ser – aliás, nunca foram – um mero convidado de pedra durante a realização do procedimento adminicular, motivo pelo qual podem, não só requisitar diligências ao delegado de polícia, mas realizá-las diretamente, se for necessário e conveniente (quem pode o mais, pode o menos, alegam). Tudo sumariam, em nome da segurança pública que está a impor a todos uma adequação à realidade moderna, ditada pela criminalidade dita organizada e/ou violenta.

Para corporificar, ainda mais, esse pseudopoder investigador, aduzem que a codificação processual penal vigente é inadequada para que o *Parquet* possa, com a presteza que a repressão criminal está a exigir das autoridades em tempos atuais, agir de modo eficaz, porque "o sistema [hoje] adotado deixa a desejar quanto à eficácia e agilidade das investigações. Embora protagonistas da mesma atividade de persecução penal, a interdependência entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público é muito deficitária, quando não rejeitada completamente".[2]

Porém, não custa rememorar, tudo isso foi muito bem sopesado pelo constituinte de 1988, que optou, apesar de opiniões em contrário, por manter o sistema vigente, que dá, à autoridade policial, atribuição exclusiva para presidir inquéritos criminais, salvo raríssimas exceções legais.

Adequações hão de vir para aprimorar o sistema processual patrício, ninguém ousa contestar, mas desde que não vilipendiem a Carta Política.

---

[2] "Palavra final: STF decide se MP pode conduzir investigações criminais". Disponível em: <htpp//www.conjur.com.br>. Acesso em: 14 nov. 2003.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 273

2. O STF: o *leading case*

O Ministério Público não possui atribuições para realizar, diretamente, investigação de caráter criminal – essa foi a decisão, prolatada em maio do ano passado, no RO em HC 81.326-7,[3] pela 2ª T. do STF, unanimemente, sob o voto condutor do Min. Nelson Jobim. Esse julgamento erige-se num corolário de diversas outras decisões de tribunais de todo o país que, antes com algumas hesitações, hodiernamente têm consagrado o mesmo entendimento.

A divulgação de tal *decisum* constituiu-se num forte sopro sobre as brasas da polêmica que vem, há mais de dez anos, sendo alimentada, no mundo jurídico, pela instauração e funcionamento dos chamados "procedimentos investigatórios criminais" (no Rio de Janeiro) ou "procedimentos administrativos criminais" (em São Paulo e alhures). Por certo, o assunto é dos mais ardentes, dos mais palpitantes, porque está a envolver acirrados debates Brasil afora, quer nas academias quer nos tribunais, posto que a decisão pretoriana põe por terra toda uma novel ideologia ministerial, que pretendia – e ainda pretende, como veremos posteriormente – inovar, destituída de respaldo constitucional ou legal, o destino da investigação criminal.

Em seu voto, o Min. Jobim demonstra que, historicamente, no direito processual penal brasileiro, as atribuições para realizar as investigações preparatórias da ação penal têm sido da polícia, pelas mais diversas razões (que explicitaremos adiante), as quais têm prevalecido a ponto de todas as iniciativas no sentido de mudar as regras nessa matéria terem sido repelidas, desde a proposta de instituir Juizados de Instrução feita pelo então Ministro da Justiça, Dr. Vicente Ráo, em 1935, passando pela elaboração da Constituição de 1988, pela feitura da lei complementar relativa ao Ministério Público, em 1993, até propostas de emendas constitucionais em 1995 e 1999, com o objetivo de dar atribuições investigatórias ao *Parquet*.

---

[3] Brasil, STF, 2.ª T. RO em HC 81.326-7-DF, rel. Min. Nelson Jobim. *DJU* 1.º.08.2003.

Os legisladores constituintes e ordinários sempre rejeitaram a idéia de transformar o Ministério Público em "Grande Inquisidor", reservando a ele o papel superior de controlador/fiscalizador das atividades policiais. Destarte, o Min. Jobim, que foi parlamentar constituinte, afirma, com a autoridade e a segurança de quem faz a interpretação autêntica, que a *mens legis* das normas em vigor é, seguramente, na direção de manter as investigações criminais como atribuição exclusiva da polícia judiciária.

3. Breve escorço histórico

Mantendo uma perspectiva histórica da discussão, devemos mencionar que, da parte dos advogados, foi A. Evaristo de Moraes Filho[4] um dos que mais cedo manifestou sua preocupação diante do inconstitucional fenômeno investigatório do Ministério Público. E ousou fazê-lo em palestra proferida na Escola Superior do Ministério Público da Bahia, em fins de novembro de 1996.

Em setembro daquele mesmo ano, o Prof. Luiz Alberto Machado,[5] titular da UFPR, instado a se manifestar sobre a matéria a pedido da Associação dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Paraná, agindo, por certo, em "prévio conluio espiritual" com Evaristo, também concluiu que "as polícias civis estaduais e a polícia federal detêm o monopólio constitucional da investigação criminal e, conseqüentemente, do inquérito policial", por conseguinte, "ao Ministério Público é constitucionalmente defeso investigar e coletar informações, indícios e provas para o processo-crime".

Naquele trabalho, Evaristo deita por terra o mito criado a respeito da legislação européia, cujo exemplo se quis, canhestramente, seguir, demonstrando que, ressalvando-se a Inglaterra, onde o Ministério Público não investiga diretamente, deixando tal mister à polícia, no continente, prevalece sistema oposto, figurando essa instituição como condutora das

[4] MORAES FILHO, Antonio Evaristo de. "Ministério Público e o inquérito policial". *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, vol. 5, n. 19, p. 105-110, São Paulo, jul.-set. 1997.

[5] MACHADO, Luiz Alberto. Parecer exarado a pedido da Associação dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Paraná. Curitiba, 09.09.2003. Não publicado.

274

investigações preliminares. Porém, não são lá as coisas como atualmente se quer fazer – reproduzimos as palavras de Evaristo:

"Há de ressalvar, porém, que o novo Código italiano preocupou-se em estabelecer uma diversificação de funções, ainda na fase preliminar, instituindo a figura do *giudice per le indagini preliminari* (art. 328), incumbido de manifestar-se sobre certas questões de natureza probatória, e competente para examinar o pedido de arquivamento, e, sobretudo, para decidir sobre a abertura da ação penal, após uma audiência de caráter contraditório, com possibilidade de colheita de novas provas. A presença deste juiz é a forma de controlar, indiretamente, a atuação do Ministério Público, como que em resposta à famosa indagação de Juvenal: *Quis coustodiet ipsos Custodes?*

Por fim, ratificando a tendência do *séparatisme* destacada por Pradel, o diploma peninsular não permite ao juiz que prolatou decisão na fase da audiência preliminar prosseguir funcionando nas etapas ulteriores do processo (art. 342)".[6]

Como se vê, ainda que inquisidor no Velho Mundo,[7] não resta o *pubblico ministero* senhor absoluto do procedimento; as provas que colhe na sua atividade investigatória são submetidas a juiz e se estabelece contraditório antes mesmo da instauração do processo, ao contrário do que se vem fazendo em terras patrícias, onde a promotoria instaura procedimento, decide que diligências e inquirições realizar (e as realiza ao

[6] MORAES FILHO, Antonio Evaristo de. Op. cit., p. 107.

[7] Brasil, STJ, 2.ª T. RO em MS 12.516-PR, rela. Ministra Eliana Calmon, j. 28.08.2003, pendente de publicação. Sobre os sistemas adotados na Alemanha, Itália, França, Espanha, leia-se: MENDRONI, Marcelo Batlouni. *Curso de investigação criminal*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002; e, sobre estes países e mais sobre os sistemas adotados na Inglaterra e Países de Gales, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e México, leia-se: BASTOS, Marcelo Lessa. *A investigação nos crimes de ação penal de iniciativa pública:* papel do Ministério Público. Uma abordagem à luz do sistema acusatório e do garantismo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

seu talante), mantém a defesa técnica ao largo da investigação[8] e, ao fim e ao cabo, oferece denúncia com base unicamente nesse inquérito ministerial secreto (por eles batizado de procedimento investigatório ou administrativo criminal, como se o eufemismo fosse capaz de suavizar o escopo precípuo, que é a promoção, às avessas, do inquérito policial), com cores da Inquisição e de Kafka, temperado à moda de ditadura militar nacional, do qual, durante o andamento, a ninguém dá satisfações.

Em ressunta: registram, investigam e denunciam, quando, não raro, antecipam, pela imprensa, "sentença penal irrecorrível" proferida em desfavor de quem há de ter preservada a presunção de inocência, como determina a Constituição da República. Neste passo, principalmente no atinente às inescrupulosas, às antiéticas e às sensacionalistas revelações midiatizadas, por vezes fornecidas à sorrelfa (os veículos de comunicação, sempre ávidos por furos de reportagem, são testemunhas vivas do que afirmamos, sendo as recentes declarações do Min. José Dirceu, Chefe da Casa Civil da Presidência da República, acerca do vazamento clandestino de notícias provenientes de processos sigilosos, um exemplo clássico), devemos salientar, em honra à importante instituição e à maioria de seus integrantes, que este procedimento não é por todos adotado, mas, como lembra o ex-Procurador-Geral da República Aristides Junqueira,[9] "eles aparecem mais", talvez porque, como lança Eduardo Carnelós,[10] "a turba gosta".

Aliás, Carnelós, ex-Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, questiona, acicatando o debate e contrapondo argumentos sofistas no sentido de se admitir até, pasmem, ser o Ministério Público investigador criminal uma "verdadeira parte-imparcial, tanto na atividade pré-processual como no plano do trâmite do processo criminal",[11] remata:

[8] Brasil, STF, 2.ª T. Liminar em HC 82.354, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 14.10.2002.

[9] JUNQUEIRA, Aristides. Apud DINIZ, Laura. "MP aborrecente: novo MP faz 15 anos, com problemas na fase de crescimento". Disponível em: <http://www.conjur.com.br>. Acesso em: 21 nov. 2003.

[10] CARNELÓS, Eduardo. Apud DINIZ, Laura. "MP aborrecente...", cit.

[11] MENDRONI, Marcelo Batlouni. *Curso de investigação criminal.* São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 275.

"Se os membros do Ministério Público se auto-intitulam defensores do povo, acabam com o devido processo legal, com o contraditório. Afinal, quem é que vai estar contra o povo? Quem vai negar o que é do povo? Como posso eu, como advogado, pretender contrariar o que está sendo dito pelo defensor do povo? Como pode o juiz não atender a pretensão do defensor do povo?"

Segundo ele, "quando se confere poder de proteção do povo a uma simples instituição, chega-se ao totalitarismo. É preciso repensar os poderes do Ministério Público. Hoje, o cidadão não tem proteção diante do poder do Ministério Público. Estamos assistindo à disseminação do abuso e o cidadão está perdendo a possibilidade de invocar a seu favor as garantias constitucionais", disparou.

Com efeito, a forma de investigação recém-repelida pela Corte Suprema milita em direção frontalmente oposta à tendência mundial em se preservar, ainda nas palavras de Evaristo de Moraes, o respeito à paridade de armas, o que, por si só, já seria razão suficiente para não se admiti-la. Nesse sentido, Nélio Machado[12] destaca que a referida tendência ao equilíbrio de forças se manifesta na Carta Política, a qual estabelece "uma verdadeira simetria, uma absoluta paridade entre as funções da acusação pública e da defesa". E nos chama a atenção para o fato de os doutrinadores afirmarem, em uníssono, que deve haver igualdade entre as partes – a chamada paridade de armas, repita-se, sempre e sempre –, equilíbrio que se esvairá se uma delas, a acusação, açambarcar atividade investigatória, com poderes inauditos, em desfavor da defesa.

Entretanto, além do nefasto desequilíbrio entre as partes, a arranhar o devido processo legal, há razão outra, das melhores, para que não se admita arremedo de inquérito policial pelo *Parquet.* Ainda Evaristo quem a ressalta.[13] Trata-se do risco da parcialidade. Diríamos, não há risco; há, sim, parcialidade, aventurando-nos a acrescentar algo ao entendimento do mestre que tanta falta nos faz.

[12] MACHADO, Nélio Roberto Seidl. "Notas sobre a investigação criminal, diante da estrutura do processo criminal no eEstado de dDireito dDemocrático. *Discursos sediciosos:* crime, direito e sociedade. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998. vol. 3, n. 5-6, p. 151-159.

[13] MORAES FILHO, Antonio Evaristo de. Op. cit., p. 106.

Quem investiga adota, logo no início de seus trabalhos, um determinado ponto de vista (independentemente de qual seja a autoridade investigante),[14] uma hipótese provisória (no dizer de Altavilla, *apud* Evaristo), uma premissa maior, sem a qual nenhuma conclusão advirá. Tal hipótese pode seduzir – e como seduz! – o investigador, de tal forma, que o torne indiferente (cego, seria a expressão propícia) a qualquer outra possibilidade, o que seria extremamente danoso se ocorresse com um Promotor de Justiça inquisidor e se torna minimizado com a separação de funções preconizada nas normas vigentes.

Aliás, não venham argumentar que isto estaria sepultado com o advento da Súm. 234[15] do STJ, porque esta, embora indesejada – ideal seria adotarmos o sistema processual que, instituindo o Juiz das Garantias, vedasse, conseqüentemente, tal possibilidade, pois é natural que o Promotor que funcionou na fase pré-processual esteja embevecido por suas "verdades", ou seja, que a exordial só fosse deduzida, e recebida, depois que houvesse ampla oportunidade para a defesa técnica contraditá-la –, não tem qualquer relação com a figura do Promotor-investigante. A súmula faz menção ao representante do Ministério Público que oficia, no exercício do controle externo das atividades policiais, na fase inquisitorial, não sendo defeso ofertar denúncia sobre aquilo que foi colhido no caderno policial.

[14] Só para se ter uma simples noção do quão perigoso é o promotor-investigador, Marcelo Batlouni Mendroni (op. cit., p. 191-192), em seu verdadeiro manual de investigação criminal do Ministério Público, sugere que seu colega promotor "deve dizer o '*o que*' necessita, enquanto que o Delegado de Polícia deve comandar o *'como'* obter", como se esse fosse mero bedel daqueleo Ministério Público, porque, em seu entender, só o pPromotor de Justiça sabe dizer "'o que' especificamente deve obter para a futura propositura da ação penal e mais que isso, para a confirmação em Juízo", pois "o Delegado *[que é bacharel em direito, ver, adiante, agudas observações de Jacinto Coutinho]* não tem precisão no que diz respeito a 'o que' especificamente deve obter para a futura propositura da ação penal e mais que isso, para a confirmação em Juízo". Razão porque, conclui Mendroni, "cada um dos órgãos de persecução tem, portanto, a sua importância peculiar e o seu preparo específico [e desde quando promotor de Justiça sabe investigar!?], devendo haver entre eles, não o conflito de atribuições *[aliás, os que pensam, como Mendroni, poder o Ministério Público investigar diretamente crimes, nada mais fazem do que estabelecer o tal conflito, em face do sistema processual pátrio]*, mas sim a união e cooperação de atuações para a finalidade comum do combate à criminalidade e defesa da sociedade". Faltou Mendroni dizer, apenas, que o Ministério Público – e como fica!? sociedade civil – não precisa da polícia judiciária, porque o MPele é auto-suficiente.

[15] "A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento de denúncia".

4. Ministério Público investigante: vedação constitucional e infraconstitucional

Pois bem, sem embargo dos bons motivos já elencados para não se acatar a figura do Promotor de Justiça investigador, a maior das razões é que, simplesmente, a Constituição da República, tanto como as demais leis, não o permitem. A interpretação dada pelos que afirmam poder o Ministério Público investigar crimes é equivocada, de leitura distorcida. Dizemos isso com apreço aos que não comungam desta hóstia, como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Prof. Cláudio Fonteles, os representantes do Ministério Público gaúcho, federal e estadual, respectivamente, Professores Luciano Feldens e Lenio Streck,[16] e os Professores e membros do órgão ministerial no Rio de Janeiro Sérgio Demoro Hamilton,[17] José Muiños Piñeiro[18] e Paulo Rangel.[19] Isso porque não é possível emprestar interpretação outra que não a sistemática e garantista dos incisos de um artigo de legislação em pleno compasso à sua *mens legis*.

Forçoso rememorar, neste instante, parte do voto do Min. Jobim,[20] o qual, então parlamentar constituinte, bem se recorda dos bastidores do Congresso Nacional, podendo, quinze anos após a promulgação da Carta de 1988, trazer seu testemunho no sentido de que:

"Na Assembléia Constituinte (1988), quando se tratou de *controle externo da polícia civil*, o processo de instrução presidido pelo *Ministério Público voltou a ser debatido.*

[16] STRECK, Lenio Luiz; FELDENS, Luciano. *Crime e Constituição:* a legitimidade da função investigatória do Ministério Público. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

[17] HAMILTON, Sérgio Demoro. "A amplitude das atribuições do Ministério Público na investigação penal". *Discursos sediciosos...*, cit., p. 137-150.

[18] Apontamentos do autor feitos enquanto o professor discursava na 149.ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, contrapondo nossos argumentos.

[19] RANGEL, Paulo. *Investigação direta pelo Ministério Público:* visão crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

[20] Brasil, STF, 2.ª T., RO em HC 81.326-7-DF, rel. Min. Nelson Jobim. *DJU* 1.º.08.2003.

Ao final, manteve-se a tradição.

O Constituinte rejeitou as Emendas 424, 945, 1.025, 2.905, 20.524, 24.266 e 30.513, que, de um modo geral, davam ao Ministério Público a supervisão, avocação e o acompanhamento da investigação criminal.

A Constituição Federal assegurou as funções de Polícia Judiciária e apuração de infrações penais à Polícia Civil (CF, art. 144, § 4°).

O texto constitucional em tela, por conseguinte, restou assim promulgado, *in verbis*:

"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

(...)

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;

(...)

VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; (...)."

É impossível ter outra exegese – o *Parquet* promoverá, além da ação penal pública, o inquérito civil e a ação civil pública, podendo expedir notificações para requisitar documentos, no âmbito dos procedimentos administrativos de sua competência, quais sejam, os inquéritos civis públicos e outros (os tais

277

"correlatos", art. 38, I, da Lei Orgânica 75/1993, como, por exemplo, os preparatórios de ação de inconstitucionalidade ou de representação por intervenção). Não há como se concluir de maneira diferente, a não ser sofismando. Não pode o *Parquet*, por falta de competência legal, realizar investigação criminal.

Diriam, com paralogismo, principalmente os que não concordam com o nosso pensar, em especial destaque, aqueles que conosco debateram na 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana,[21] os representantes do *Parquet* Cláudio Fonteles (Procurador-Geral da República), José Muiños Piñeiro Filho (ex-Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro) e Luiz Antonio Guimarães Marrey (então Procurador-Geral de Justiça de São Paulo), que o órgão ministerial não pretende, jamais, usurpar as funções da polícia judiciária, a quem compete presidir, com exclusividade, admitem, os inquéritos policiais (art. 144, IV, da CR). Não pretendem, de maneira alguma, gizam, transformar seus gabinetes em burocráticos cartórios policiais, em palavras curtas.

Porém, pretendem, sim, investigar, legitimados por uma tal "pseudo-atribuição concorrente/supletiva" à polícia judiciária que supõem ter, como assinalou o Prof. Fonteles,[22] fundamentando sua reflexão, dentre outros argumentos (vamos relembra-los adiante), com o conhecido adágio popular "de quem pode o mais pode o menos" –, argumento falacioso, porque, como curial entre os hermeneutas, não tem efetividade contra norma expressa na Constituição; logo, inaplicável ao tema testilhado.[23] Dizia

[21] Realizada em Brasília, em 19.11.2003.

[22] Apontamentos do autor feitos enquanto o professor discursava, na 149.ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, contrapondo nossos argumentos.

[23] Nesta abordagem, o melhor princípio a dar substrato a uma interpretação segundo a Constituição da República é o da conformidade ao texto constitucional, que implica, quando levado a efeito, na consideração de algumas proposições, segundo doutrina Luís Roberto Barroso, dentre as quais, destacamos: "eleição de uma linha de interpretação para exclusão expressa de outras interpretações possíveis, que conduziriam o resultado contrastante com a Constituição e, por via de conseqüência, a interpretação conforme a Constituição não ser considerada mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se *declara ilegítima uma determinada leitura da norma legal*" (BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição:* fundamentos de uma dogmática transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 175, destaque do articulista).

Fonteles, a título demonstrativo, que, em tais ou quais crimes[24] (como os de corrupção de policiais e de outras autoridades hierarquicamente superiores, derivados de organização criminosa etc.),[25] a polícia não possui a independência suficiente para investigar, trazendo à balha, para clarificar, a investigação que desencadeou na apelidada "Operação Anaconda",[26] a qual arrastou às agruras do processo criminal juízes, policiais, advogados, auditores da Receita Federal etc., todos, atestam os noticiários, suspeitos de praticarem crimes contra a Administração Pública etc.

Ademais, explicitou o referido professor,[27] com o brilhantismo que lhe é peculiar, o fato de o art. 38, I, da LC 75/1993, dispor ser função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos correlatos, não lhes retira a atribuição/competência de promover, estribados na tal "pseudo-atribuição/competência concorrente/supletiva", investigação de índole criminal. Isto não é verossímil: diferentemente do particular (a quem tudo é permitido, desde que não lhe seja proibido), aos órgãos públicos a competência há de estar prevista em lei.[28] Se não estiver, como não está, é porque ele não a possui. *Tout court.*

[24] Como não há balizamento legal, porque o Ministério Público não têm competência para investigar crimes, os interesses do órgão acusador variam (ou podem variar) de acordo com as vontades (ou caprichos) de seus integrantes, o que, só por si, está a revelar o abismo a que os cidadãos estão submetidos.

[25] Apontamentos do autor feitos enquanto o emérito professor discursava, na 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, contrapondo nossos argumentos.

[26] A ofídica operação foi, ao que se tem notícia, desde seu nascedouro, conduzida pela polícia judiciária. Nesse caso, o Parquet exerceu, tão-só, sua missão constitucional de efetivo controle externo das atividades investigatórias. Ou seja: trabalharam em harmonia, em parceria, e um não se imiscuiu nas funções dos outros.

[27] Apontamentos do autor feitos enquanto o professor discursava, na 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, contrapondo nossos argumentos.

[28] No verbo de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Edward Rocha de Carvalho, a "atribuição é *exclusiva de quem a detém e excludente dos demais*, porque sua fonte, única e exclusiva *é a lei*, no caso a CR, a qual não vai – e não pode ir – manipulada, em nome de nada, mormente se contra ela vá. Não cabe, ademais, (por evidente que feriria a lógica!) uma solução de compromisso; não se conserta para além do limite fixado em lei e, no caso, a *exclusividade* não está a permitir sequer a dúvida" (excerto colhido em inicial de *habeas corpus* impetrado no TAPR, dez. 2003).

278

5. A palavra do Ministério Público ainda vale?

Como o debate ali travado era de tempo restrito, não nos foi possível revelar que, por intermédio de Wladimir Sérgio Reale, Delegado de Polícia fluminense aposentado e presidente da ADEPOL/RJ, havíamos tido acesso à cópia reprográfica do esclarecedor *Ofício PRESI nº 31/1992, de Brasília e datado de 6.5.1992, da lavra do então presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Dr. Francisco José Teixeira de Oliveira, dirigido ao também então Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, o qual, em linhas gerais, informava, ao último, "o resultado das conversações que* [havia mantido], *acompanhado pelo colega Dr. Amir José Finocchiaro Sarti, com representantes dos Delegados de Polícia Federal, a propósito de Lei Orgânica do Ministério Público da União", salientando o Procurador Oliveira que, porventura merecedor da homologação de Junqueira, a conciliação das posições assumidas permitiriam "o prosseguimento dos trâmites legislativos, afastados, pelo menos, os embargos opostos pelos policiais".*

Sabemos que, durante a tramitação de leis pelo parlamento, os segmentos representativos da sociedade civil, no exercício salutar da democracia, fazem, de forma legítima, o seu *lobby*, e, no particular, classistas do Ministério Público e da Polícia Federal (antes, com a participação dos da Polícia Civil) nunca deixaram de fazê-lo, cada um defendendo, dentro do espírito público que os norteia, os pontos de vista das instituições que integram e representam. Travavam-se, naquela ocasião, discussões sobre o projeto de lei que desaguaria, como desaguou, na Lei Orgânica do Ministério Público da União 75/1993 e os policiais temiam, não sem razão, atestamos hoje, que a argumentação do órgão ministerial fosse suficientemente capaz de lhes retirar os exclusivos poderes que lhes foram cometidos pela Carta Cidadã, em relevo, o de presidir o inquérito policial.

É mais uma vez o Min. Nelson Jobim[29] quem nos faz rememorar tais conversações:

[29] Brasil, STF, 2.ª T., RO em HC 81.326-7-DF, rel. Min. Nelson Jobim, *DJU* 1.º.08.2003.

"(...) o tema voltou a ser discutido quando, em 1993, votava-se no Congresso Nacional a lei complementar relativa ao Ministério Público da União e ao Ministério Público dos Estados, em que havia essa discussão do chamado processo de instrução que pudesse ser gerido pelo Ministério Público.

Há longa disputa entre o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Federal em relação a essa competência exclusiva da polícia de realizar os inquéritos.

Lembro-me que toda essa matéria foi rejeitada, naquele momento, no Legislativo (...)".

Diante desse impasse, a *Associação Nacional dos Procuradores da República*, contando com o concurso de "representantes dos delegados de Polícia Federal", e *com o fito de pôr cobro aos conflitos de interesses que vinham "obstaculizando a tramitação da nossa lei* [a do MP] *no Congresso Nacional, em razão de discordância quanto a diversos dispositivos do projeto, supostamente lesivos aos interesses corporativos da classe policial", celebrou, com aqueles, um ajustamento, que, na parte que nos aproveita, guarda relação, tão-só, com o acréscimo, no art. 38, I, daquele projeto legislativo (com o advento da lei, o texto não restou alterado, prevalecendo o acordado), do "termo correlatos (o que limita o alcance do dispositivo ao campo da ação civil pública, como parece ser o alcance real do dispositivo)". "Correlatos", então, à ação civil pública, confessam.* Portanto, este é, e sempre foi, o espírito da lei, sem tirar nem pôr. Melhor, posto e interpretado, por ser a única exegese possível, pelo então Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, em documento oficial, enviado a seu chefe institucional.

Demais isto, também municiados pelo Delegado Reale, *podemos anotar que o citado ajustamento já havia sido celebrado, em 25/11/1992 e entre as mesmas partes* – sendo que, desta feita, com a participação expressa de dirigentes de órgãos das polícias estaduais (*o termo de acordo*, que Wladimir Reale nos encaminhou por cópia, é *firmado, sem qualquer ressalva*, pelos Presidentes da ANPR, da CONDEPOL-Brasil e ADEPOL-DF, da ANDPF, da ADEPOL-RJ – assistida pela autoridade policial aposentada e já referida –, do SINDPESP, da ADPESP, e por membros da SPF/MJ e da *PGR, a qual, não é desimportante bradar, ao revés, no ato se fazia representar, nada mais, nada menos do que pelo atual Procurador-Geral da República, Prof. Cláudio Fonteles) –, e estava*

379

vinculado "tanto à aprovação do texto legal no Senado da República, quanto na Câmara Federal, no que pertine às relações entre o Ministério Público da União e a atividade policial, ficando desde logo desautorizada pelas entidades que subscrevem o presente termo qualquer nova alteração do texto proposto pelo Relator Sen. Amir Lando, no particular". É o que se lê do documento, sem rebuços e sem ambages, celebrado quando ainda tramitava o Projeto de Lei 11/1991, que disporia, como ao final dispôs, sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, assegurando, no inc. I do art. 7°, ser função do Ministério Público, *in verbis*: "instaurar o inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos".

Conseqüentemente, a Casa do Povo legitimou, privativamente, o que as partes interessadas (Ministério Público Federal e Polícias Federal e Estadual) haviam pactuado, restando a redação final do indigitado art. 38, I, da LC 75/1993, de maneira idêntica àquela relatada no ofício da lavra do então Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Senão, vejamos:

"Art. 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, incumbindo-lhe, especialmente:

I – instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos".

Não custa dizer, só para que não reste "pedra sobre pedra", que nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, da LC 75/1993, não encontramos (porque inexistentes) as tais "pseudo-atribuições/competência concorrentes/supletivas" e que estariam, no entendimento de Fonteles, Piñeiro e Marrey a dar abrigo ao Ministério Público para realizar, diretamente, investigações de índole criminal. Ao contrário, no art. 3° do Capítulo I, Título I, da lei em tela, vamos encontrar, somente, o relevantíssimo, nobilíssimo e indisputável papel de poder-dever o Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial.

Portanto, para os que fazem uma interpretação elástica e oblíqua da

Constituição e da LC 75/1993, como, citando mais um nome, o Prof. Aury Lopes Jr.,[30] sobrou patenteado que a Carta de 1988, por não consagrar qualquer comando expresso, vedou ao Ministério Público investigar crime (a exceção será adiante enfrentada). Em sede constitucional, excetuando-se as garantias individuais, interpretação só restritiva, é cediço.

De outro lado, sabemos que, embora outras entidades, públicas e privadas, também tenham legitimidade para ajuizar ação civil pública, somente ao Ministério Público foi cometido o poder-dever de instaurar inquérito civil preparatório daquela, e, para a consecução de tal mister (inclusive nos feitos correlatos, correlatos ao inquérito civil público, perdoem-nos a crônica repetição), pode-deve o *Parquet*, sim, se for o caso, ouvir testemunhas, requisitar documentos não acobertados pelo manto da reserva de jurisdição, determinar a realização de perícias etc. Realizar, diretamente, investigação de caráter criminal, não, porque não possui a tal "pseudo-atribuição/competência concorrente/supletiva" dada, apenas, à polícia judiciária.

6. Afinal de contas, quem pode o mais, pode o menos?

É inequívoco reconhecer que pode-deve o Ministério Público, sim, desde que disponha dos elementos suficientes, ofertar denúncia de plano, posto ser o inquérito policial, nestas hipóteses, facultativo e dispensável. Porém, tal circunstância, que é inerente ao regular exercício da titularidade da ação penal pública (art. 129, I, da CR), não está a autorizar que, à mingua daqueles indisputáveis elementos necessários ao oferecimento da preambular, possa o órgão acusador prescindir do inquérito policial, o qual é de presidência exclusiva da autoridade policial (art. 144, IV, da CR).

Como já se sublinhou, para os entes públicos,[31] não há como se ver aplicado aquele dito popular aclamado por Fonteles. Não é pelo fato de o

[30] LOPES JR., Aury. *Sistemas de investigação preliminar no processo penal*. 2. ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 156.

[31] Para o particular, sim, vale o adágio: o que não é proibido é permitido.

Ministério Público poder o mais (controle externo das atividades da polícia judiciária e legitimidade ativa exclusiva para promover os processos de natureza penal pública) que o legislador, implicitamente ("teoria dos poderes implícitos"),[32] lhes conferiu poder o menos (investigar crimes), em virtude de limitações legais (explícita limitação àqueles argumentos sofistas). São singelas regras, demarcadas por claras linhas divisórias, que hão de ser respeitadas em uma República que se pretende oxigenada. Nos países democráticos, cada cidadão exerce sua missão na sociedade, com independência funcional, mas dentro dos hígidos parâmetros constitucionais e legais, não se permitindo que um invada as funções do outro. Devem, todos, sim, trabalhar como num time, com vista a atingir o fim almejado: salvaguardar o Estado de Direito Democrático.

Com efeito, a teoria dos poderes implícitos, interpretada à luz do Direito Constitucional, é desenvolvida a partir de doutrina norte-americana, a qual teve seu marco histórico no julgamento Mc. Cullough vs. Maryland, realizado em fevereiro de 1819 (BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora*. São Paulo: Saraiva, 1996, pp. 120 e 122).Porém, sabe-se que "as palavras empregadas na Constituição devem ser entendidas em seu sentido geral e comum, *a menos que resulte claramente de seu texto ao seu sentido técnico jurídico*" (QUINTANA, Segundo V. Linares. *Reglas para la interpretación constitucional*. Buenos Aires, Ed. Plus Ultra, 1987, p. 65 APUD, BARROSO, Luís Roberto. Op cit, p 121. Grifos nossos), e, no caso em estudo, a Carta da República não deixou qualquer fenda, a mais mínima brecha, a autorizar o intérprete, com fundamento na lição alienígena, a ter qualquer outra interpretação, a não ser a que restou promulgada. Isso é fato incontroverso.

"As palavras tem sentidos mínimos que devem ser respeitados, sob risco de se perverter o seu papel de transmissoras de idéias e significados. É a interpretação gramatical ou literal que delimita o espaço dentro do qual o intérprete vai operar, embora isso possa significar zonas hermenêuticas muito extensas. A esse propósito, já decidiu o Tribunal Federal alemão: 'Através

[32] "Palavra final: STF decide se MP pode conduzir investigações criminais", cit.

da interpretação não se pode dar a uma lei inequívoca em seu texto e em seu sentido, um sentido oposto; não se pode determinar de novo, no fundamental, o conteúdo normativo da norma que há de ser interpretada; não se pode faltar ao objetivo do legislador em um ponto essencial'" (BARROSO, Luís Roberto. Op cit., pp 122 e 123).

Em texto constitucional não existem palavras supérfluas, "nem se deve partir do pressuposto que o constituinte incorreu em contradição ou obrou com má-fé" (BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p 123.); é de se concluir que a teoria dos poderes implícitos, muito derramada pelo Ministério Público para lhe dar pseudosupedâneo constitucional/legal de diretamente conduzir investigações criminais, não tem a menor aplicabilidade à espécie, porque, repise-se, não há lacuna na Constituição da República, ao revés, há norma expressa, motivo pelo qual, aqui, não há espaço para se importar a teoria estrangeira.

Ademais, nem de longe ousaríamos sustentar que, assim, o representante do Ministério Público ficaria, na fase adminicular, restrito aos desconfortáveis limites impostos a um convidado de pedra, que nada poderia fazer para que esta ou aquela prova, por ele tida como indispensável à formação de sua *opinio delicti*, fosse produzida pela autoridade policial. Pode-deve o Promotor de Justiça ter ciência, no prazo de lei, de todos os feitos que foram registrados em sede policial.[33] Se houver inércia da autoridade processante, que se lance mão dos meios coercitivos disponíveis.

[33] No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, há anos existem as Centrais de Inquérito do Ministério Público, tendo os Promotores atribuição para atuar diretamente nos feitos decorrentes desta ou daquela delegacia de polícia. Portanto, para a delegacia X, existe o Promotor natural Y. Assim, nada impede (aliás, seria de todo recomendável) que este determine àquele que todo e qualquer registro/boletim de ocorrência viesse a seu conhecimento no tempo de lei (art. 10 do CPP, para não falarmos nas legislações especiais), para que, analisado pormenorizadamente, pudesse o Promotor de Justiça, no exercício da fiscalização direta dos atos da autoridade policial, determinar à realização desta ou daquela diligência (perícia, inquirição de testemunha, requisição de documento etc.) que poderia, inclusive, ser produzida em sua presença (em sua presença, não por ele diretamente).
Para tanto, há de haver vontade (e vontade política também) da Promotoria de Justiça de querer

7. Só a polícia judiciária investiga crime?

É incontroverso, também, que a Constituição conferiu, em certas e raríssimas circunstâncias, a outras autoridades, que não a policial, o poder de investigar, mas não crimes (as exceções ainda virão adiante).

cumprir o efetivo controle externo das atividades policiais, recusando-se esta a trabalhar como uma desimportante peça deste cenário chamado inquérito policial, porque o eficaz andamento deste só se dá por meio de estudo detalhado, onde são traçadas metas investigativas com fito de se apurar os indícios da infração penal e de sua autoria, e, não, por meio dos burocráticos e reprováveis carimbos (em tempos de informatização, estes foram substituídos por folhas contendo cota-padrão) que, simplesmente, simulam controlar/fiscalizar o andamento das investigações.

Com freqüência indesejável, vemos inquéritos e mais inquéritos com a conhecida cota-padrão: "baixem, por X dias, para ultimar as investigações" e, de lá, da polícia, voltam para o Ministério Público, com o também burocrático e abominável despacho-padrão: "em razão do acúmulo de serviços, não nos foi possível dar andamento à determinação ministerial. Subam, requerendo novo prazo para ultimar o inquérito". "Baixam". "Sobem". Caminham, sim, mas de prateleiras em prateleiras, acumulando poeira e colacionando folhas inúteis. A investigação que seria indispensável, não é levada a efeito com a presteza e seriedade desejáveis. No fim deste cavernoso calvário, o arquivamento e/ou a prescrição da pretensão punitiva estatal advém e o cidadão (vítima ou investigado) é o grande prejudicado, pois não vê seus direitos respeitados. É o descrédito do Poder Público.
Não por outra razão (em verdade, com outra razão, como veremos ao fim) que a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, em nota oficial assinada em 9.10.2003 (disponível em: <htpp// www.conjur.com.br>, acesso em: 29 nov. 2003), delatou o caos fluminense (antes, o próprio Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Miguel Pachá, já o havia feito), alertando a população que o tribunal "está fechando Varas Criminais, pois as estatísticas revelam que o número de processos vem diminuindo, passando de 23.433 processos em 2000, para 15.473 em 2001 e 18.011 em 2002. A distorção provocada também pode ser traduzida em números: enquanto uma Vara Criminal recebe em média 22 processos por mês, as Varas Cíveis recebem cerca de 110 processos". Mas, ao mesmo tempo em que divulgam esta estatística alarmante, caminham na contramão da história mundial, pois pretendem alterações legislativas para que possam ser instaurados os odiados, detestados e temerosos Juizados de Instrução, aqueles que dariam ao juiz (que sempre há de estar longe das fogueiras provocadas pelo calor dos debates, para que possa, com isenção, exercer a difícil tarefa de julgar seus semelhantes) poderes para participar do processo de investigação criminal, porque pensam (ou sonham!) que, assim, a impunidade diminuiria. Não por receio, mas por fugir ao tema foco deste ensaio, vamos nos limitar a fazer este registro, deixando, aos doutos, analisar os malefícios dos Juizados de Instrução.

Assim, a título de exemplificação, é que o Congresso Nacional investiga, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (art. 71 da CR), ao exercer o controle externo sobre "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas", todavia, esta investigação/controle externo não ilidirá o "sistema de controle interno de cada Poder". A mesma investigação/controle será exercida em face das pessoas referidas no parágrafo único, do art. 71 da Carta Política. Porém, é indisputável que essas investigações não são de caráter criminal. Competindo, como compete, ao Congresso Nacional e/ou Tribunal de Contas da União "representar ao Poder competente sobre irregularidades" [se criminais, pode se dirigir diretamente ao Ministério Público ou Polícia]. Por conseguinte, não investigam crimes, por não terem competência para tanto.

Doutra vertente, sempre ilustrando, vamos encontrar as comissões parlamentares de inquérito,[34] as quais, sabemos, não têm o escopo de apurar

[34] Deve-se registrar, por ser por demais importante, que os Procuradores-Gerais de Justiça, quando citam o Prof. Antonio Scarance Fernandes, Procurador de Justiça aposentado, no memorial que apresentaram a Ministros do STF ("Palavra final: STF decide se MP pode conduzir investigações criminais", cit.), não constataram que o notável jurista da USP, na mesma obra, páginas à frente, , prelecionou acerca dos tais (inexistentes) poderes, ao contrário do que aqueles dão a entender no paper endereçado à Corte Constitucional. Vejamos:

"(...) a Constituição atribuiu à polícia a função de investigar as infrações penais, mas, na linha da tendência universal, previu o seu controle pelo Ministério Público e, por outro lado, restringiu, em parte, seus poderes de polícia em prol de maior garantia às pessoas presas ou submetidas a inquérito.

crimes. Sua função cinge-se – como bem leciona o Prof. Luís Roberto Barroso,[35] membro titular do Conselho de Defesa dos Diretos da Pessoa Humana e designado, pelo Min. Nilmário Miranda, para proferir parecer, ao colegiado, acerca da matéria título deste trabalho – a apurar fatos determinados (§ 3.º do art. 58 da CR), "(...) de competência do Congresso Nacional, sem invadir atribuições de outros poderes, não podendo legitimamente imiscuir-se em fatos da vida privada *nem se investir no papel de polícia ou de persecutor criminal*" (destacamos).

Pontificando a parte final do texto constitucional relativo às CPIs, que, "suas conclusões, se for o caso, [poderão ser] encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores". Nesta hora, mais uma vez antevendo opiniões apressadas, é revelar que o fato de as conclusões das comissões poderem ser encaminhadas, "se for o caso", ao *Parquet*, a fim de que este "promova a responsabilidade (...) criminal dos infratores", deve ser entendido, basicamente, na hipótese de o relatório conclusivo do inquérito parlamentar, recebido pelo órgão acusador como peças de informação, dispor daqueles mínimos elementos que o autorizam a oferecer, de imediato, denúncia, porque, nesta conjectura, como se sabe e já se disse, o

(...) Não se trata, contudo, de atividade que substituiria integralmente a atividade de polícia judiciária, exercida pela autoridade policial, prescindindo-se do inquérito policial. Pela própria Constituição Federal, sem exclusividade, incumbiu-se aos delegados de carreira exercer a função de polícia judiciária (art. 144, § 4.º). Não foi a norma excepcionada por outro preceito constitucional. O que permitiu o art. 129, inc. VII, é o acompanhamento do inquérito policial pelo promotor.

O avanço do Ministério Público em direção à investigação representa caminho que está em consonância com a tendência mundial de atribuir ao Ministério Público, como sucede em Portugal e Itália, a atividade de supervisão da investigação policial. Entre nós, contudo, depende-se ainda de previsões específicas no ordenamento jurídico positivo, evitando-se incerteza a respeito dos poderes do promotor durante a investigação" (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2000, p. 243-244, destaque nosso).

Como se viu, o que Scarance doutrina é que, em certas investigações, como as comissões parlamentares de inquérito, sindicâncias, processos administrativos penais etc,. é comum haver o que chama "apuração indireta de crime", o que - nem é preciso avançar muito - é totalmente diferente daquilo que deram a entender todos os Procuradores-Gerais de Justiça subscritores do documento retro.

[35] Apud VIEIRA, Luis Guilherme. Casos penais. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 152.

caderno policial é despiciendo. Do contrário, não há outra solução: o Ministério Público requisitará à autoridade policial a instauração do competente procedimento policial, passando a exercer o controle externo da atividade policial, como bem avaliou Scarance.[36]

Abra-se, por imprescindível, um parêntese.

Olhos açodados hão de dizer que o constituinte de 1988, inovando os poderes das tão em voga CPIs[37] – que mais parecem devassas, dos tempos das Ordenações Filipinas, salvo raríssimas exceções –, deu a elas "poderes de investigação próprios das autoridades judiciais" (§ 3º do art. 58 da CR), motivo pelo qual podem, os parlamentares integrantes desta célula do Legislativo, investigar do mesmo modo que os juízes.

De imediato, é bom gizar, e com giz bem luminoso, que magistrado não investiga coisíssima nenhuma. Uma das regras de exceção, por todos aceita sem qualquer discórdia, porque constitucional, é encontrada no art. 33 da LC 33/1979. Das outras, por mais ímpares ainda, cuidaremos mais tarde.

Como nesta seara todo cuidado é pouco, vamos nos apressar e tomar, logo, e por empréstimo, as lúcidas aulas dos Professores Luís Roberto Barroso e Ada Pellegrini Grinover, os quais, do alto de suas cátedras, ensinam:

"Na Itália, leciona Fulvio Fenucci, em estudo monográfico sobre o tema, a despeito de tal cláusula, os limites da investigação parlamentar, sob a luz do art. 82 da Constituição, são os limites de competência próprios do Poder Legislativo. As comissões, assim, hão de ter por limite material (*limiti materiali*) a autonomia dos indivíduos, não podendo afetar a independência dos outros órgãos constitucionais. A idéia de poderes de investigação judicial vem associada à aptidão para a produção de provas, com tomada de depoimentos, realização de perícia e mesmo requisição de documentos. Nunca, porém, violando 'il diritti

[36] Idem, ibidem.

[37] BARANDIER, Antonio Carlos (Org.). CPI: os novos comitês de salvação pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2002.

precostituiti e constituzionalmente garantiti dai privati, sai che si tratti de persone fisiche che di persone giuridiche"[38]; [e, por tal motivo], (...) numa visão que procure atribuir algum sentido à precisão constitucional, o que se pode inferir é que o constituinte pretendeu, ao outorgar às CPIs os poderes de investigação referidos pelo art. 58, § 3º, atribuir-lhes na verdade *poderes instrutórios* idênticos aos reservados aos membros do Judiciário, ou seja, as mesmas prerrogativas que têm os juízes e tribunais na pesquisa probatória: convocação e inquirição de testemunhas, determinação de perícias, requisições de documentos etc., que eram bastante limitadas anteriormente, especialmente em face do art. 3º, parágrafo único, da Lei 1.579, que fazia depender a convocação de testemunhas de *solicitação* da CPI ao juiz original".[39]

Em ressunta, conclui Barroso:

"o sentido da expressão poderes próprios de investigação de autoridades judiciais é o de criar para a comissão parlamentar de inquérito o direito, ou, antes, o poder de dar às suas determinações o caráter de imperatividade. Suas intimações, requisições e outros atos pertinentes às investigações devem ser cumpridos e, em caso de violação, ensejam o acionamento de meios coercitivos. Tais medidas, todavia, não são auto-executáveis pela comissão. Como qualquer ato de intervenção na esfera individual, resguardada constitucionalmente, deverá ser precedida de determinação judicial".[40]

Teorizar diferente é ir de encontro à antiga e profícua assertiva de Francisco Campos,[41] no sentido de que "os poderes delegados às comissões de inquérito o devem ser de modo expresso, definido e específico, outros não podendo ser deduzidos por analogia ou sob a alegação de que estão implícitos nos poderes expressamente enunciados, dado que, ainda na esteira doutrinária do ex-Ministro da Justiça, 'uma cláusula constitucional não é uma caixinha de segredos, de que os prestidigitadores extraem os mais heterogêneos objetos'".

[38] Apud VIEIRA, Luis Guilherme. Op. cit., p. 81.

[39] Idem, ibidem, p.82.

[40] Idem, p. 82.

[41] Idem, p. 84.

Feche-se, por não mais imprescindível, o parêntese.

Poderíamos, aqui, ficar comentando sobre outras hipóteses, todas de natureza não criminal, saliente-se, previstas em legislações ordinárias, como os inquéritos realizados pelo Banco Central em casos de liquidação extrajudicial, os realizados contra funcionários públicos em virtude de falta funcional, os relativos aos assuntos administrativo-tributários etc. Mas nenhum deles investiga crimes. Se, no curso destes, surgirem indícios da existência de crime (a tal "apuração indireta" aludida por Scarance), deverão as autoridades investigantes extrair peças e encaminhá-las ao Ministério Público, que, reitera-se, diante da escassez de elementos suficientes à propositura da ação penal, deverá requisitar, por imperativo legal, à autoridade policial, a instauração do procedimento adminicular. Do contrário, a ação pode-deve ser ajuizada incontinenti.

Já desta feita voando em "céu de brigadeiro", força aceitar que, em certas circunstâncias, singulares circunstâncias, diga-se, de soslaio, o legislador constituinte garantiu, a determinadas pessoas, prerrogativa de foro, em razão da função por elas exercida. Nestes casos,[42] ímpares casos, o STF, o STJ, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça dos Estados possuem, por comando constitucional, competência para investigá-las, processá-las e julgá-las criminalmente. Com a derrogação de súmula pretoriana específica, adveio a Lei 10.628/2002, a qual, em seu § 1º, estabelece que "a competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública". Só para ilustrar, os membros do Ministério Público[43] e os do Judiciário[44] não são investigados por autoridade policial, em razão de possuírem investigador e foro privilegiados (Leis Complementares 75/1993 e 37/1979, respectivamente).

[42] Arts. 96, III, 102, I, b e c; art. 105, I, a; art. 108, I, a, todos da CR.

[43] Par. ún. do art. 19 da LC 75/1993.

[44] Par. ún. do art. 33 da LC 37/1979.

TRIBUNAL 284

É adequado sacudir, para que nada seja ocultado, que outras legislações ordinárias, sempre lembradas pelos opositores, permitem à autoridade que não a policial investigar crimes.[45] A primeira delas, por todos os doutrinadores abominada e apontada com a balda da inconstitucionalidade,[46] é a Lei 9.034/1995 – dita do crime organizado –, que instituiu a figura do "juiz-inquisidor" nos parágrafos de seu art. 3º, aniquilando, assim, o primado da imparcialidade do magistrado e ferindo, letalmente, o do devido processo legal. A outra, prevista na Lei de Falências (art. 111),[47] dá ao magistrado o poder de presidir o "inquérito judicial falimentar", mas, neste procedimento, a investigação do juiz não se limita à busca de elementos de prova para a propositura da ação penal. Como adverte Ada Pellegrini Grinover,[48] ela objetiva, também, salvaguardar "repercussões no âmbito civil da falência, como a concessão de concordata suspensiva". Pondere-se que o decreto-lei em testilha pouco difere do Projeto de Lei 4.376/1993, recém-aprovado pela Câmara, razão pela qual a análise de Pellegrini é ainda pertinente.

Arrematando: não pode o Ministério Público, pessoalmente, investigar crimes, por não ter-lhe sido concedida competência/atribuição em lei. Pode-deve, sim, requisitar à autoridade policial a instauração do procedimento instrutório, sendo-lhe vedado utilizar-se da regra estatuída no par. ún. do art. 4º do CPP, recepcionada pela Carta de 1988, para, tomando-a como "pseudo-atribuição concorrente/supletiva" à polícia judiciária, investigar crimes, posto que a ressalva introduzida pelo legislador de 1940 é aplicada, sim, ao órgão ministerial, mas, única e exclusivamente, nos fatos de poder-dever investigar os praticados por seus representantes. O resto é quimérico.

[45] Antes da Constituição da República de 1988, encontrávamos os execráveis procedimentos judicialiformes (Dec.-lei 3.688/1941, art. 17), em bom tempo banidos de nosso sistema.

[46] Por todos, ver: GRINOVER, Ada Pellegrini. "Que juiz inquisidor é esse". Boletim do IBCCrim, n. 30, jun. 1995; e PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 1999. p. 175-176.

[47] Dec.-lei 7.661, de 21.6.1945.

[48] Apud VIEIRA, Luís Guilherme. Casos penais. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 80.

8 – Dos (legítimos) poderes institucionais do Ministério Público

Trazendo a troca de idéias para terras do Estado do Rio de Janeiro, sem qualquer bairrismo – até porque as demais legislações estaduais do Ministério Público, ao que se sabe, não discrepam do que já restou antes consagrado, mas, fundamentalmente, para contrapor, com a seriedade que o assunto está a merecer, a argumentação sacudida, na 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, pelo ex-Procurador-Geral de Justiça José Muiños Piñeiro,[49] o qual conosco ali dialogou –, vale explicitar que a LC 106/2003, promulgada em 3.1.2003, repetindo textos das legislações federais, dispõe, em seu art. 34, VI, ser incumbência do Ministério Público, além das funções previstas nas Constituições da República e estadual e em outras legislações, todas aqui já estudadas amiúde, "promover o inquérito civil e propor a ação civil pública, na forma da lei", estatuindo as alíneas *a* e *b*, da lei, as vertentes em que aquele e aquela devem ser instaurados e propostos.

De se notar, por interessantíssimo, que o legislador fluminense fez questão de estabelecer, no art. 35, que:

"(...) no exercício de suas funções, cabe ao Ministério Público:

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos para a apuração de fatos de natureza civil, sempre que tal se fizer necessário ao exercício de suas atribuições e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, sem prejuízo do processo por crime de desobediência, ressalvadas as prerrogativas em lei;

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades e outros órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim das entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das entidades sem fins lucrativos que recebam verbas públicas ou incentivos fiscais ou creditícios;

[49] Apontamentos do autor feitos enquanto o professor discursava, na 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, contrapondo nossos argumentos.

285

c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;

d) requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processos em que atue;"

e, como soe acontecer, para atingir o alvo, tem ele o poder-dever de:

"(...)

III – requisitar [destacamos, requisitar] diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observando o disposto no art. 129, VIII, da Constituição da República, podendo acompanhá-los; [insistimos, acompanhá-los, não realizá-los]

IV – receber diretamente da Polícia Judiciária o inquérito policial, tratando-se de infrações de ação penal pública;

V – requisitar informações quando o inquérito policial não for encerrado em trinta dias, tratando-se de indiciado solto mediante fiança ou sem ela".

Contudo, se o membro do *Parquet*, no exercício das funções trazidas à colação, detectar indícios da prática de crime, determina o § 7º do art. 35 da LC fluminense 106/2003, ser seu poder-dever: *"Na hipótese do inciso I deste artigo, surgindo no curso dos procedimentos indícios da prática de infração penal, o Promotor de Justiça tomará as providências cabíveis e remeterá peças ao órgão com atribuição".*[50]

Agora, levando a boa contenda para terras paulistas, em respeito ao Ex-Procurador-Geral de Justiça Luiz Antonio Guimarães Marrey , que, de modo igual e representando o Colégio de Procuradores-Gerais de Justiça, também conosco discutiu o tema em causa na reunião realizada pelo Conselho de Defesa

[50] Atribuição para, nunca será cansativo relembrar, cumprir o que determinam os incs. III, IV e V do art. 35 da LC estadual 106/2003, porventura os tais indícios da prática do crime não sejam suficientes para, tomados como peças de informação, instruir, de plano, denúncia, sem necessidade de se requisitar a instauração de inquérito policial, o qual, como se sabe, é dispensável.

dos Direitos da Pessoa Humana,[51] vamos encontrar a LC daquele Estado 734/1993, que, no Capítulo I, Seção I, em particular, em seu art. 103, dispõe ser função institucional do órgão, afora promover, privativamente, a ação penal pública (inc. VI):

"VIII – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção, a prevenção e a reparação dos danos causados ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos, homogêneos e individuais indisponíveis".

Para tanto, no exercício do "controle externo da atividade policial por meio de medidas administrativas e judiciais, pode [o Ministério Público], dentre outras" (inc. XIII):

"*a)* ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;

b) ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade de polícia judiciária;

c) representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

d) requisitar [não presidir, sublinhemos] à autoridade competente [a policial, repiquemos] a abertura de inquérito sobre a omissão ou fato ilícito ocorridos no exercício da atividade policial;

e) receber, imediatamente, comunicação da prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade policial estadual, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão".

Ademais, a legislação do Estado de São Paulo estabelece, no art. 104, inc. I, alíneas *a*, *b* e *c* c/c os incisos II a VIII, o que poderá-deverá fazer o

[51] 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, realizada em Brasília, em 19.11.2003.

Parquet para instruir os feitos que lhe estão afetos, no regular exercício da presidência de "inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes", ao inquérito civil, está bem óbvio. A Seção II do Capítulo II, por seu turno, nos arts. 105 a 113, disciplina o processo a ser cumprido durante a realização do inquérito civil público. E, por fim, a Seção III do mesmo Capítulo I, para que não paire qualquer má interpretação, disciplina as atribuições concorrentes (entre membros do órgão, apressemo-nos em consignar) e os conflitos de atribuição (substantivo utilizado em sentido estrito, não é inútil comentar).

9. Dos (inconstitucionais e abusivos) poderes institucionais do Ministério Público

A par disto tudo, reconhece-se, não sem enorme tristeza, porque de malefícios incalculáveis, ter surgido nos mais diversos Estados da federação – e é provável que ainda surjam, até que o Pleno do STF e/ou o Congresso Nacional decida, vez por todas (e estão em vias de fazê-lo), sobre a relevante questão –, atos normativos especiais, elaborados pelo Ministério Público, os quais, aqui e acolá, tentaram dar roupagem de legalidade aos procedimentos inquisitoriais, mas sempre ferindo de morte a Lei das Leis e demais legislações aplicáveis à espécie.

Em 1996, só para demonstrar o que se traz à luz, um ato do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça de São Paulo (o de nº 98/1996) pretendeu traçar regras para a realização das investigações criminais. Um parecer, ainda não publicado, de 21.10.1996, do Prof. José Afonso da Silva,[52] no tempo secretário de Segurança Pública daquele ente federado, enviado ao Procurador-Geral de Justiça Luiz Antonio Guimarães Marrey (Of. Sec. Gab. 72/1996, de 16.10.1996), afirmou a inconstitucionalidade gritante

[52] É bom adiantar, , que o catedrático da USP, citadoem memorial assinado por todos os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados-membro (disponível em: <www.conjur.com.br>, acesso em: 14 nov. 2003) e apresentado a Ministros do STF por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.202, 2.613 e 2.703, reconheceu, de fato, que a segurança

do ato, como nos fez saber o já tão saudoso José Carlos Fragoso.[53]

Só para se ter pequeníssima idéia do que José Afonso da Silva consagrou naquele judicioso parecer, e para recolocar o tema no exato entendimento do catedrático das Arcadas, sem abrir cavidade para qualquer exegese outra que não se quede em suas próprias lições, as quais transformaram em pó o ato normativo[54] do *Parquet* paulista, vale a transcrição de seu juízo:

pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CR), motivo pelo qual, prelecionou em sua clássica obra (o trecho adiante transcrito faz parte do paper retro) "a segurança pública não é só repressão e não é problema apenas de polícia, pois a Constituição, ao estabelecer que a segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144), acolheu a concepção do I Ciclo de Estudos sobre Segurança, segundo a qual é preciso que a questão da segurança seja discutida e assumida como tarefa e responsabilidade permanente de todos, Estado e população" (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990. p. 650).

Porém, como se comprova de trabalho específico sub o tema, tal circunstância não representa, pontifica José Afonso da Silva, o poder de o Ministério Público se imiscuir nas atividades que foram deferidas, exclusivamente, à autoridade policial, usurpando de suas relevantes funções públicas(ver, José Carlos Fragoso no verbete abaixo).Não por outro motivo, o mesmo professor, no ano de 2000, então Presidente da Comissão Permanente de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros teve, mais uma vez, no Pleno daquele sodalício, a oportunidade de exteriorizaridêntico pensamento.

[53] FRAGOSO, José Carlos. "São ilegais os 'procedimentos investigatórios' realizados pelo Ministério Público Federal". Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 10, n. 37, p. 241-251, São Paulo: RT, jan.-mar. 2002.

[54] Neste parecer, José Afonso da Silva sublinha, antes de mais nada, sobre a impropriedade de se lançar mão de ato administrativo do Ministério Público para regular o exercício do controle externo da atividade policial, porque, "de duas uma, ou a LC 73/93 regulou adequada e completamente a matéria, e o Ato 98/96, é absolutamente despiciendo, ou deixou lacunas e o questionado Ato não é o meio adequado para supri-las. É que a Constituição outorgou à lei complementar competência para regular a forma de controle externo, nada mais; e não admite delegação nem à lei ordinária e menos ainda ato administrativo para disciplinar a matéria".

Ademais, disse, com sua inquebrantável autoridade, que a expressão "dentre outros", contida na parte final do inc. XIII do art. 129 da LC 743/93, do Estado de São Paulo, não era fundamento para tal, porque "não remete a futuro ato administrativo, porque seria delegação inconstitucional, uma vez que a Constituição reservou a regulamentação da matéria exclusivamente à lei complementar estadual. Referida locução, 'dentre outras', se liga à cláusula, da cabeça do artigo, 'nos termos da legislação aplicável'. Liga-se, por exemplo, a diversas disposições do Código de Processo Penal e da Lei das

287

"(...) o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, previsto no art. 129, VII, está limitado pela natureza da lei que o regulamenta – lei complementar –, mas também por outras normas constitucionais. Assim é que, no que interessa aqui, a Constituição estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a *organização, garantias, direitos e deveres da polícia civil.* Ora, isso quer dizer que cabe à União estabelecer normas gerais sobre essa matéria, e, aos Estados, normas suplementares. Isso significa que não pode a lei estadual, e menos ainda ato administrativo do Ministério Público, atribuir ao controle externo atividades que interfiram com a organização, as garantias, direitos e deveres das policias civis. Mais, ainda o art. 144, § 4º, estatui que *às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.* Isso quer dizer que a Constituição reservou à polícia civil estadual um campo de atividade exclusiva que não pode ser invadido por norma infraconstitucional e, menos ainda, por disposições de ato administrativo. Uma delas é a de realização do inquérito policial, que constitui o cerne da atividade de polícia judiciária, que não comporta o controle externo do Ministério Público, porque tal controle ainda pertence ao Poder Judiciário (...). A outra é que também à polícia civil, polícia judiciária, se reservou a função de *apuração das infrações penais,* o que vale dizer o poder investigatório, sendo, pois, de nítido desrespeito à Constituição normas que atribuam a Órgão do Ministério Público a faculdade de promover diretamente investigações, como fez o art. 26 do Ato 98/96".

Sem tirar, nem pôr, melhor, repondo o verbo de José Afonso da Silva ao lugar de onde nunca deveria ter saído, esta é, queiram ou não, sua única opinião acerca dos (inexistentes) poderes do Ministério Público de investigar diretamente crimes.

Execuções Penais que atribuem faculdade de fiscalização ao Ministério Público. Em conseqüência, a expressão 'dentre outras' não autoriza regular matéria de lei complementar por meio de ato normativo. Aliás, nesse sentido já se pronunciou até mesmo a Dra. Anadyr de Mendonça Rodrigues, com aprovação do não menos insuspeito Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, em parecer exarado na ADIn 638-0/600-RJ. Não é importante, aqui, que essa ação não tenha sido julgada, porque vale a tese. Diz o parecer:

Na mesma direção é o *entendimento do Instituto dos Advogados Brasileiros* – que, nos idos de 2000, por intermédio da Comissão Permanente de Defesa do Estado de Direito Democrático, no tempo por nós presidida, instado a se pronunciar pelo, à época, Presidente Marcello Cerqueira, depois de caloroso debate, que contou com a presença, dentre outros, do Prof. José Afonso da Silva – através do voto médio de Celso Soares, tendo como relator original da indicação de nº 141/2000, José-Ricardo Pereira Lira –, se posicionou no seguinte sentido: *"a Constituição não atribui ao Ministério Público poderes de investigação policial e sim a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis"*.

Com efeito, logo após o STF julgar o *writ* 81.326-7-DF, o Ministério Público paulista editou os Atos Normativos 314-PGJ/CPJ, de 27.6.2003, e 324-PGJ/CGMP/CPJ, de 29.8.2003. Em razão disso, para atender consulta formalizada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, foi elaborado percuciente estudo pelos Professores Miguel Reale Júnior e Eduardo Reale Ferrari, acerca de sua constitucionalidade/legalidade, no qual, sem firulas, consideram os atos hodiernos tão inconstitucionais quanto o de 1996, analisado pelo Prof. José Afonso da Silva.

Para não nos alongarmos muito, tomamos a liberdade de transcrever fragmento da acurada análise realizada pelos Reale, posta em parecer não publicado:

"A simples leitura desses dispositivos constata que foram expressamente distinguidos os poderes do *Parquet* quando de sua atuação em procedimentos administrativos de sua competência e nos inquéritos policiais.

O inciso VI do art. 129 da CF/88 se refere expressamente a procedimentos administrativos conduzidos pelo Ministério Público, como o inquérito civil. Nessa hipótese, caso um Promotor de Justiça necessite de elementos de prova a instruir uma ação civil pública deverá fazer uso de seus poderes a fim de lograr obter informações e documentos.

Diverso constitui o papel do Ministério Público nos casos de investigação por meio de inquérito policial.

A lei, de fato, não contém palavras inúteis. Se assim não fosse, não teriam sido diferenciados os poderes dos órgãos ministeriais em incisos diferentes para situações diferentes.

O inciso VIII do art. 129 da CF trata especificamente da atuação do Ministério Público no inquérito policial e, mais ainda, a limita à requisição de diligências investigatórias e instauração de inquérito".[55]

Noutras épocas não tão remotas assim, em 2.9.1998, "a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (Matéria Criminal e Controle Externo da Atividade Policial) do Ministério Público Federal decidiu, no Processo 08.112.000.502/96-73 (Parecer 169/97), relator o ilustre Vice-Procurador-Geral da República Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega, na parte que interessa":

Desse modo, parece inequívoco que o art. 129, VII, da CF, ao se remeter à Lei Complementar permitida no art. 128, § 5º, caput - para fazer a definição da atividade de controle externo da atividade policial inserida dentre as funções institucionais do Ministério Público -, não estava conferindo, a tal Lei Complementar, para esse fim, o poder de alterar o Código de Processo Penal. Tal art. 129, VII, deve ser entendido, então, tão-somente, no sentido de estar limitado a estabelecer que a 'lei complementar mencionada no artigo anterior' haveria de definir a forma, através da qual os membros da Instituição a desempenhariam, cumulativamente com as demais atribuições institucionais".

Mais incisivo, ainda, é o Acórdão do STF, rel. Min. Ilmar Galvão, exarado na ADIn 1138-RJ, que impugnou a validade de Resolução 447, de 17.6.1994, da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro, que versava sobre a mesma temática do Ato 98/96 da PGJ-SP, in verbis:

"Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Dispositivos da Resolução 447, de 17.6.1994, da Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Alegada incompatibilidade com os arts. 22, I, 61, II, d, 127, § 2º, in fine, 128, incs. VI e VII, e 144, § 4º, da CF.

Impropriedade do meio empregado para regulamentação do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, reservada, pela Constituição, à lei complementar da União e dos Estados (art. 128, § 5º), circunstância que reforça a plausibilidade da tese da argüida inconstitucionalidade formal do referido ato e evidencia a conveniência da pronta suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados, no prol da harmonia funcional dos órgãos envolvidos".

[55] REALE JÚNIOR, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. Parecer elaborado em face dos Atos Normativos 314-PGJ/CPJ, de 27.06.2003, e 324-PGJ/CGMP/CPJ, de 29.08.2003, editados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. São Paulo, 21.10.2003, p. 5.

Ementa: Procedimento administrativo criminal instaurado na Procuradoria da República, com fundamento no art. 129, VIII, da CF.

(...)

Impossibilidade em face dos termos do art. 144, § 1º, IV, da CF/88 – interpretado como garantia constitucional do cidadão de somente ser investigado pela polícia judiciária. Situação diversa do regime anterior".[56]

Meses antes desta decisão colegiada, em 19.3.1998, a Subprocuradora-Geral da República, doutora Delza Curvello Rocha, por se encontrar em descompasso com a Resolução 38/1998,[57] do Conselho Superior do Ministério Público Federal (instituída, exatamente, pelo então Vice-Procurador-Geral da República Haroldo Ferraz da Nóbrega, o mesmo que dera o parecer supra e que se encontrava no exercício da presidência do Conselho), representou,[58] perante a Procuradoria Geral da República, por meio do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade (não intentada, como se constata de pesquisa realizada no *site* do STF), por entender que:

"(...) a realização de diligências investigatórias destinadas ao inquérito policial ou futura ação penal, fogem à atuação direta do Ministério Público porque devem ficar jungidas a quem detenha constitucionalmente a titularidade para instaurar esse tipo de procedimento, por se encontrar submetido ao controle judicial, na forma da lei processual, sob pena de restarem feridos o

[56] Disponível em: <http//:www.stf.gov.br>. Inicial da ADIn 2.943-6-DF, rel. Min. Carlos Velloso.

[57] Disponível em: <http//:www.mpf.gov.br>. Da parte a ser destacada, reproduzimos o resumo levado a efeito pela Subprocuradora-Geral da República Delza Curvello Rocha (citação 24):

"a) instauração de procedimentos administrativos investigatórios (arts. 1º a 4º):

b) que o membro do Ministério Público Federal, realize pessoalmente, ou em equipe, procedimentos investigatórios próprios, praticando entre outros os seguintes atos (arts. 1º, 2º e 3º):

– inquirição pessoal do investigado;

– inquirição de testemunhas;

– requisição de documentos e perícias.

c) acompanhar pessoalmente, ou em equipe, inquéritos e investigações policiais preliminares, instaurados no âmbito da Polícia Federal, nos termos da Resolução 32 do CSMPF (art. 1º);

d) a criação, no âmbito de cada Unidade Administrativa, de estrutura de apoio a essa função investigatória".

[58] Disponível em: <http//www.stf.gov.br>. Acesso em: 22 nov. 2003. Inicial da ADIn 2.493, rel. Min. Carlos Velloso.

inciso LIII do art. 5º – 'ninguém será processado (= investigado) nem sentenciado senão pela autoridade competente', além da afronta ao texto já citado do art. 144, I e IV, todos da CF/88. De outro lado, o disposto no art. 7º da referida Resolução 38 fere a norma constitucional inscrita no § 2º do art. 127, que impõe que a organização e funcionamento da instituição se realizem observado o princípio da legalidade, não se admitindo que mera resolução possa criar função institucional ou estrutura administrativa para dar suporte a qualquer função.

Finalmente, e porque oportuno, convém deixar consignado que a titularidade plena do exercício da ação penal pública há de ser conceituada como a impossibilidade de ser essa ação iniciada *ex officio*, nesse segundo caso admitida apenas se o Ministério Público não intentá-la no prazo legal.

Esses, Excelência, os fundamentos que entende a ora requerente denunciadores da inconstitucionalidade dos dispositivos normativos apontados, que certamente merecerão maiores subsídios com a análise das questões pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (...).

Finalmente, a ora requerente solicita seja o presente pedido apreciado com urgência, visto que a divulgação desse ato normativo, poderá acarretar conseqüências indesejadas – quer em relação ao cidadão, que doravante poderá ser alvo de constrangimento ilegal por parte de atuação de membro do Ministério Público Federal – como também em relação à incolumidade física de algum colega menos ponderado que, sem o devido preparo para o mister investigatório penal, ponha em prática o que a Resolução lhe faculta, colocando inadvertidamente e de alguma forma, sua vida em perigo".

Curioso, mas essencial marcar com sinal reluzente, que *aquela decisão do colegiado do Ministério Público Federal não foi unânime, vencido o atual Procurador-Geral da República, Prof. Cláudio Fonteles* e seus colegas Antonio Fernando, Paulo de Tarso, Roberto Gurgel, Wagner Mathias, Wagner Gonçalves e Helenita Acioli.

Noutro ano, mas sempre com o mesmo fim, o Ministério Público mineiro criou os Centros de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado e de Investigação Criminal, respectivamente,

CAO e Crimo,[59] os quais conferiam ao *Parquet* mineiro a "'competência' para realizar diligências investigatórias e, para tanto, instaurar e presidir procedimentos administrativos de natureza criminal".[60] Irresignado, o Partido Social Liberal (PSL) ajuizou, no STF, a ADIn 2.703, em face do Governo, da Assembléia Legislativa e do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, a qual não chegou a ser julgada, porque, independentemente da petição[61] "do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais requerendo a prejudicialidade da ação por perda de objeto tendo em vista a revogação do texto legal impugnado", o partido político perdeu sua legitimidade para suscitar o controle concentrado de constitucionalidade, motivo pelo qual, em 19.3.2003, o relator determinou o arquivamento da ADIn. Em 12.8.2003, o autor requereu o prosseguimento da ação, por ter readquirido representatividade parlamentar.

Enfim, como registrou, para sempre, José Carlos Fragoso:[62] "Não é possível (...) permitir que o Ministério Público possa acumular as funções de investigador (que a ninguém presta contas), e de instituição encarregada de promover a persecução criminal. Trata-se de um acúmulo perigoso de atribuições, que, sobre ser ilegal e inconstitucional, é absolutamente inconveniente, pois dá lugar, pelo excesso de poder, a abusos intoleráveis".

A Constituição (art. 144, § 1º, inc. IV) é expressa quanto às atribuições exclusivas da polícia judiciária em presidir inquéritos policiais. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de nº 8.625/1993, também não se afasta do balizamento constitucional. Estabelece ela funções no art. 25 e seus incisos, sempre em perfeita sintonia com a Carta Cidadã, não custa falar de novo, e, já agora, também com a LC 75/1993. Estabelece, ainda, ela, no art. 26, I, *a* e *b*, os poderes de instaurar inquéritos civis e procedimentos administrativos pertinentes (aos inquéritos civis, está bem claro) e, nestes, notificar,

[59] "Palavra final: STF decide se MP pode conduzir investigações criminais", cit.

[60] Idem, ibidem, p. 2-13.

[61] Disponível em: <http//www.stf.gov.br>. Acesso em: 22 nov. 2003.

[62] FRAGOSO, José Carlos. Op. cit., p. 244.

colher depoimentos, mandar conduzir, requisitar informações, perícias, documentos etc. No âmbito criminal, reza a lei citada (art. 26, IV): "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los". E isso não é pouco nem de pouca importância, ao contrário, garante o efetivo controle externo das atividades policiais.

Em razão de todo o exposto, vê-se que as normas regedoras da matéria, em qualquer esfera, constitucional ou não, se mostram coerentes em tudo permitir ao Ministério Público, mas em matéria de inquérito e ação civil pública. Isso não se estende, à evidência, à área criminal, restando os chamados procedimentos investigatórios/administrativos criminais completamente ao desamparo da lei. É essa, também, a leitura de Miguel Reale Júnior e Eduardo Reale Ferrari:

"Tal distinção é reproduzida expressamente na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625, de 12.2.1993, em seu art. 26, IV – a atuação do Ministério Público no inquérito policial foi tratada em dispositivo legal específico onde fica autorizado ao *Parquet* somente requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no art. 129, VIII, da CF, podendo acompanhá-los. A expedição de notificações para oitiva de testemunhas e a requisição de documentos fica limitada ao inquérito civil, conforme dispõe o inc. I do mesmo artigo".[63]

10. Membros do *Parquet* chancelam: Ministério Público não tem competência para investigar crimes

Porém não foram apenas advogados e professores os operadores do direito que acorreram a delatar a extravagância e a inconstitucionalidade das investigações criminais diretas do Ministério Público. Interessante apontar, outra vez, que membros do *Parquet*, na condição de fiscais da lei, têm a mesma interpretação, como nos relatam os Professores Reale:

[63] REALE JÚNIOR, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. Op. cit., p. 6.

"O próprio Ministério Público Federal reconhece, em parecer lavrado pelo Subprocurador-Geral da República, Jair Brandão de Souza Meira, que a impessoalidade da acusação esgarça-se quando o Ministério Público extrapola de suas funções e substitui-se à Polícia Judiciária, formulando a investigação e a denúncia, em acusações próprias dos Tribunais de Exceção" (parecer ofertado no RHC 8106-DF, em 26.11.1998).[64]

Dois outros casos são conhecidos: o Prof. Juarez Tavares, Procurador Regional da República no Rio de Janeiro, lavrou parecer, no HC 1.137,[65] da 2ª T. do TRF da 2ª Reg., pela concessão de ordem de *habeas corpus* para trancar ação penal em que a denúncia (considerada abusiva no acórdão) fora ofertada com base em inquérito administrativo instaurado e realizado por membro do Ministério Público:

"Primeiramente cumpre-nos salientar que a ação penal desfechada contra o paciente, lastreada em inquérito penal realizado pelo próprio órgão do Ministério Público, constituiu, realmente, fato inusitado e estranho, em face da falta de atribuição do *Parquet* quanto ao colhimento de provas com a finalidade de instaurar ação penal, eis que cabe ao mesmo, tão-somente, realizar inquéritos civis, conforme reza a nossa Carta Magna, em seu art. 129, quando dispõe a respeito das funções institucionais do Ministério Público".

Outro se deu em 1998, quando a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria Geral da República, sob o voto condutor da já mencionada Subprocuradora-Geral da República, Delza Curvello Rocha, prolatou acórdão de natureza administrativa assim ementado:

"Ementa: Procedimento administrativo criminal instaurado na Procuradoria da República, com fundamento no art. 129, VIII, da CF, em virtude de expediente que relata a ocorrência de conduta, em tese delituosa, praticada por deputado federal. Tramitação de referido expediente em cartório criminal, instituído por portaria da chefia. Instauração de procedimento criminal

[64] Apud REALE JÚNIOR, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. Op.cit., p.21.

[65] Brasil, TRF 2ª Reg., 2ª T., HC 96.02.35446-1 (1137-RJ), rel. Des. Silvério Cabral, DJ 5.8.1997

291

administrativo pelo Ministério Público. Impossibilidade em face dos exatos termos do art. 144, § 1º, IV, da CF/88 – interpretado como garantia constitucional do cidadão de somente ser investigado pela polícia judiciária. (...) Encaminhamento ao Procurador-Geral da República do presente procedimento administrativo, solicitando cancelamento da autuação, bem como revisão do ato administrativo que criou o noticiado 'cartório criminal', em face dos princípios contidos na Constituição Federal".[66]

11. A jurisprudência. A (futura) decisão do Pleno do STF

Os tribunais vêm formando, ao longo dos últimos anos, uma corrente cada vez mais firme e coesa em repudiar os supracitados procedimentos que se pretendem inquéritos criminais, independentemente das alcunhas diferentes que lhes são conferidos.

Como dito no início, o provimento dado ao RHC 81.326, pelo STF, vem consolidar a tendência jurisprudencial, da qual daremos alguns exemplos de negar validade às investigações criminais diretas do Ministério Público. Vem na esteira de inúmeras outras decisões, das mais variadas cortes, ainda que com algumas hesitações, pois há turmas ou câmaras que se deixaram encantar pela argumentação sofista.

Assim é que a concessão do HC 1.137, por maioria, pelo TRF da 2ª Reg., para trancar ação penal proposta com base em inquérito administrativo instaurado e realizado no âmbito do *Parquet*, que mencionamos ao registrar o parecer (favorável à concessão) do consagrado Juarez Tavares, foi enfrentada por recurso extraordinário interposto por outro membro do Ministério Público. Tal recurso tomou o Nº. 233.072-4 [67] e foi denegado, também por maioria (mantido, portanto, o trancamento da ação penal), em 18.5.1999, e extrai-se de sua ementa que o Ministério Público não tem competência "para produzir inquérito penal sob o argumento de que tem possibilidade de expedir notificações nos procedimentos administrativos".

[66] Disponível em: <http//www.stf.gov.br>. Inicial da ADIn 2.943. Acesso em: 22 nov. 2003.

[67] Brasil, STF, 2.ª T., RE 233.072-4-RJ, rel. Min. Néri da Silveira, DJU 3.5.2002, Ementário 2067-2.

Na mesma esteira, trilham decisões prolatadas pelo Tribunal de Justiça de Brasília, nos autos das mandamentais 1999.00.2.002958-2 e 1999.00.2.002413-8, a primeira, sob o voto condutor da Des. Aparecida Fernandes, e a segunda, sob o voto condutor do Des. Joazil M. Gardes, rezando a ementa da última:

"*Habeas corpus*. Controle externo da atividade policial. Polícia Judiciária. Substituição pelo Ministério Público.

Ao Ministério Público, em sua função controladora da atividade policial, não comporta substituir a polícia judiciária na prática de atos de exclusiva competência. Inteligência do art. 144, §§ 1º e 4º, da CF".

Há mais um precedente no STF – onde se abordou o assunto, pela vez primeira e *en passant* – foi o RE 205.473-9,[68] interposto pelo Ministério Público, guerreando concessão de *habeas corpus* pelo TRF da 5ª Reg., que tivera o efeito de trancar ação penal. Já, então, dissera o Juiz Lázaro Guimarães, relator do *writ*, que não se compreendia "o poder de investigação do Ministério Público fora da excepcional previsão da ação civil pública (art. 129, III, da CF). De outro modo, haveria uma polícia judiciária paralela, o que não combina com a regra do art. 129, VIII, da CF". A hipótese era de ação penal por desobediência, a qual foi considerada não ocorrente e o recurso extraordinário não foi conhecido, em julgamento datado de 15.12.1998, com parecer, nesse sentido, do então Subprocurador-Geral Cláudio Fonteles. Todavia, na ementa, o relator do recurso, Min. Carlos Velloso, não deixou de registrar sua desaprovação às investigações criminais realizadas por Procuradores da República: "não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais investigações, mas requisitá-las à autoridade policial".

Do TRF da 2ª Reg., 4ª T., se tem notícia da concessão, com efeito de trancamento de ação penal, em 8.11.2000, do HC 99.02.07263-1,[69] relator para o acórdão o Des. Federal Benedito Gonçalves. Da ementa, vale sublinhar a parte final: "Diante da falta de atribuição legal ao Ministério Público Federal

[68] Brasil, STF, 2ª T., RE 205.473-9-AL, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 19.3.1999, Ementário 1943-2.

[69] Brasil, TRF 2ª Reg., 2ª T., HC 99.02.07263-1-RJ, rel. Des. Benedito Gonçalves, DJ 15.3.2001.

para promover diretamente atos investigatórios, há que ser reconhecida a ilegalidade das provas coligidas, sob pena de violação ao princípio do *due process of law*".

No voto condutor, foram mencionadas outras decisões daquela corte regional, no mesmo sentido, tais como, além da concessão do HC 1.137, que ensejou o RE 233.072-4, outrora comentado, uma decisão da 1ª T., HC 97.02.09315-5,[70] de 19.8.1997:

"I – *Habeas corpus* impetrado objetivando o trancamento da ação penal, defluente de denúncia formulada baseada em subsídios probatórios extraídos de inquérito policial instaurado, processado e presidido por membros do Ministério Público Federal, subscritores da peça vestibular da ação penal.

(...)

IV – Concessão da ordem de *habeas corpus* impetrada em favor dos pacientes para determinar o trancamento da ação penal contra eles instaurada, em curso no Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Unânime".

Uma homenagem há de ser feita, neste passo, para fins de registro histórico. O *leading case* fluminense aconteceu em processo relatado pelo humanista Silvio Teixeira Moreira, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dos mais notáveis que, ao apreciar o *writ* 615/1996,[71] da 1ª Câm. Crim. daquela corte, salientou:

"(...) A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, são privativas das polícias civis.

Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua atribuição não passa do poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar.

Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e de outras medidas e

[70] Brasil, TRF 2ª Reg., 1ª T., HC 97.02.09315-5 (1273-RJ), rel. Des. Ney Fonseca, DJ 9.10.1997.

[71] Brasil, TJRJ, 1ª Câm. Crim., HC 615/1996, rel. Des. Silvio Teixeira, DORJ 18.9.1996 e 23.9.1996.

procedimentos administrativos pertinentes, aqui incluídas as diligências investigatórias".

Garimpando para terçar armas com Lenio Streck no último Congresso Internacional do IBCCrim, Eduardo Carnelós achou e trouxe a lume decisão de fevereiro de 1991, da lavra do Desembargador paulista Weiss de Andrade, proferido no *writ* 99.018-3/2,[72] como ele destacou, não constante de qualquer repositório jurisprudencial ou mencionado em revistas especializadas, que dramaticamente está a revelar os perigos da investigação conduzida diretamente por aquele que tem a missão de, em nome da sociedade, promover processo criminal em desfavor do cidadão.

Neste emblemático caso, o tribunal, após deferir medida liminar para colocar em liberdade o paciente, que tinha prisão preventiva decretada e fora denunciado por triplo homicídio qualificado, concedeu a ordem para trancar a ação penal. Com efeito, à míngua dos elementos indispensáveis à propositura da ação, o Promotor de Justiça, em vez de requisitar novas diligências, chamou aos peitos a investigação, ouviu depoimentos, pediu pareceres de técnicos e, com estes elementos por ele produzidos, ofertou a inicial que, submetida à análise pela angusta via do *habeas corpus*, foi posta por terra.

Após tantas digressões doutrinárias e jurisprudenciais, chegou-se (na realidade, já se chegou antes disso), por meio de pequeníssimo escorço histórico, não teratológico, tampouco teleológico, a um pétreo epílogo: o Ministério Público, cuja inegável importância foi reconhecida na Constituição Cidadã, tem incontáveis poderes, mas, dentre eles, não se encontra o de instaurar e realizar procedimento investigatório com o escopo de colecionar informações que embasem uma preambular. Suas atribuições para investigar diretamente se cingem aos inquéritos civis, salvo a exceção de poder-dever investigar os crimes atribuídos a membros do próprio órgão.

Porém, infelizmente, a contenda ainda não encontrou águas tranqüilas. Neste mar, já dantes navegado, muitas águas vão rolar... e como vão...

[72] Brasil, TJSP, 2ª Câm. Crim., HC 99.018-3/2, rel. Weiss de Andrade, j. 25.2.1991, DOSP 2.3.1993.

293

De relance, comente-se que se encontra em tramitação, no Pleno do STF, o Inquérito 1.968,[73], relator o Min. Marco Aurélio. Iniciado o seu julgamento em 15.10.2003, no qual se pretende o recebimento de denúncia ofertada em face de deputado federal que está sendo acusado de suposta prática de crimes em desfavor do Sistema Único de Saúde, sua defesa técnica sustentou, dentre outros argumentos, a falta de justa causa para a ação penal, porquanto as provas apresentadas e que estão a escorar a exordial foram produzidas diretamente pelo *Parquet*. O Min. Marco Aurélio, já secundado pelo Min. Nelson Jobim, proferiu voto no sentido de rejeitar a inicial, por entender que o Ministério Público, embora titular da ação penal, não possui competência para realizar diretamente investigações na esfera criminal, mas, apenas, para requisitá-las à autoridade policial competente. O julgamento se encontra suspenso em razão do pedido de vista do Min. Joaquim Barbosa.

Demais isto, também em tramitação no STF a ADIn 2.943,[74] relator o Min. Carlos Velloso, na qual o Partido Liberal questiona a matéria sacudida neste ensaio.

12. O sistema processual penal do século XXI: o que se pretende?

Cremos ser fundamental, em questão a ser decidida em "preliminar prejudicial de mérito", que se defina, logo, o que se pretende construir, neste recém-iniciado milênio, a respeito, não só do inquérito policial, mas, sobretudo, de todo o sistema processual penal. Não podemos mais conviver com reformas pontuais, nascidas sob o manto do desespero, do pânico e da irracionalidade.[75]

[73] Brasil, STF, Tribunal Pleno, Inq 1.968, rel. Min. Marco Aurélio.

[74] Brasil, STF, ADIn 2.943, rel. Min. Carlos Velloso.

[75] "(...) a CR de 88 traçou, como se sabe, uma base capaz de, sem muito boa vontade, enterrar grande parte do atual CPP, marcado pela concepção fascista do processo penal e ancorado na tradição inquisitória, inclusive da fase processual da persecução, só não percebida por todos em razão da pouca perquirição que se faz das suas matrizes ideológicas e teóricas, a começar pelo velho Código De Processo Penal italiano e seu inescrupuloso difusor e defensor camicia nera de todos os instantes, Vincenzo Manzini. Que ele foi um vigoroso articulador teórico do processo penal italiano não se pode negar; mas que era um terrível fascista - expressa isso em sua obra - também não. Pior, porém, é o que se passa com a doutrina nacional, alienada em relação a problema do gênero, como sucedeu, por infelicidade - não se pode crer em outro fundamento - com José Frederico Marques, o primeiro grande escritor, no Brasil, de um direito processual penal que queria superar a base praxista da ritualística de

antes da polêmica Windscheid x Muther e, por isso, ajudou a formar toda uma geração de processualistas que, não se dando conta das raízes espúrias raízes do ramo, não poucas vezes pregam uma democracia processual com um discurso fundamentalmente antidemocrático. Assim, não é fácil evoluir; não é fácil avançar na direção da concreção da democracia processual; não é possível proceder ao necessário corte epistemológico e as mudanças - qualquer uma - tendem a manter, como sugeriu Lampedusa, tudo como sempre esteve.

Talvez seja este, afinal, o grande motivo pelo qual vai-se para quarenta anos de tentativas de mudanças (não esquecer que o Anteprojeto Tornaghi era de 1963) e elas não se consumam, dado encontrarem resistências pontuais fundadas em argumentos de tal relevância que se tornam de difícil resposta. Ora, ou se demarca, da melhor maneira possível pela base epistemológica, o campo de incidência da reforma, ou não se retiram as premissas (algumas absolutamente falsas) aos ataques sofridos por ela, a começar daqueles que partem da angústia gerada pelo novo aos castelos da segurança calcada no conforto do velho. De Bachelard a Freud, de Khun a Lacan, de Foucault a Barcellona, de Habermas a Dussel, de Hayek a Hikelammert, de Carnelutti a Cordero, muita gente teria muito a dizer sobre o tema.

Neste diapasão, é necessário discutir imensamente antes de tentar mudar - de verdade! - a estrutura e não há que temer as eventuais deficiências do Parlamento e os jogos políticos, muito menos fazendo de conta que eles não existem ou não têm importância porque junto não dizem respeito à questão. Por esta dimensão é inescurecível discurso político aquele que avança contra uma reforma global com a idéia da dificuldade prática de se conseguir, no Parlamento, uma mudança do gênero, mas nenhum mal há nisso, em se fazer um discurso político; muito pelo contrário. No atual estágio do direito, espaço não há para propostas neutrais e alheias às ideologias. Com isso, todavia, desloca-se o eixo do argumento, passando a ser, antes de tudo, uma opção política o modelo da reforma. E aí é preciso ter confiança na força qualitativa e técnica dos juristas, capazes (por que não?) de armar, desde premissas sólidas, uma estrutura que se não consiga mexer, quanto à substância, por interesses antidemocráticos.

Eis a razão pela qual não se pode deixar de sustentar que um projeto global consistente refletindo seu tempo, há de vingar como, diga-se de passagem, ocorreu na Itália, em que pese os vinte e cinco anos de discussões, com inúmeras atualizações, sem se perder o rumo, justo porque se manteve a unidade. Há de abrir mão (algo não muito fácil em um país como o nosso, sempre marcado pelo imediatismo da glória, mormente em tempos de extremado individualismo narcíseo), por evidente do açodamento, da pressa de se produzir uma reforma para o dia anterior. Pisapia, para infelicidade de todos, não teve tempo para desfrutar o CPP italiano de 89; mas não será menos laureado por isso. Quanto aos guardasigilli, foram tantos no longo período da gestação do Código, mas não importavam realmente enquanto o valor primeiro fosse a nação italiana, sem embargo de que Giuliano Vassali, Ministro da época da promulgação, não só fosse extremamente respeitado por ser um grande político, como, sobretudo, porque era, e é, um penalista de primeira linha, que pode, com toda a tranqüilidade, ser esquecido como ocupante momentâneo do cargo naquele momento. Serve, aqui, como advertência, antológica análise de Cordero sobre as macchine giudiziarie: '... ogni causa é politica, inutile dirlo. Organo e funzione sviluppano delle strutture. Era tutto contenuto nella protocellula. Qui non attecchiscono

394

Discussões apaixonadas e apaixonantes à parte, o cidadão que vier a ser processado criminalmente, pouco importando a gravidade do crime e do clamor público que dele advier (no mais das vezes, esse é decorrente da opinião publicada, que não guarda relação com aquela), o deve ser com base em um processo penal devido, respeitador das garantias fundamentais que estão fincadas na Carta que Ulysses Guimarães, com orgulho, um dia chamou de Cidadã.

Caso os doutos entendam que o Ministério Público deva poder,[76] em tais ou quais condições, dirigir investigação criminal,[77] com a tal competência/atribuição concorrente/supletiva, como queiram batizá-la, passo subseqüente será, em primeiro, suspender o andamento das propostas legislativas que tramitam pelo Congresso Nacional a inovar as regras da investigação criminal, em especial o Projeto de Lei 4.209/2001 (os outros também), elaborado por comissão presidida pela Profª. Ada Pellegrini Grinover, para, em segundo, ouvida a comunidade científica,[78] se produzir emenda constitucional, pois a alteração, porventura pretendida, não poderá vir em leito ordinário[79].

Nesse momento, fazendo eco com Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, em nada adiantam reformas parciais, faz-se, de há muito, imprescindível uma reforma de todo o sistema legal pátrio.[80] Mas, para tanto, é necessário que o Judiciário comece a interpretar o CPP à luz dos princípios fundamentais estatuídos pelo legislador constituinte de 1988. Sem a efetividade dessa leitura, serão produzidas leis, leis e mais leis que não solucionam e nem solucionarão os problemas sociais, embora estas sejam vendidas, pelos oportunistas de plantão, como remédio salvador. Quem sabe através de Lei Delegada, onde seriam delimitadas as diretrizes comuns – epistêmica e constitucional – fixaríamos as regras a serem observadas na elaboração de anteprojetos, projetos de lei e de emenda constitucional. Sem isto, pensa-se, chegaremos ao caos. Perdão, por já estarmos no caos, a Lei Delegada seria medida de ordem.

---

invenzioni stravaganti: gli istituti distinati a lunga durata nascono organicamente dal metabolismo politico; ogni sistema sottintende uma cultura, buona, scadiziario. Restano fuori le prassi, su cui capiremmo poco se ignorassimo i meccanismi infralegali del potere: l'apparato penale ne cova uno temibile; che sia esercitato in forme più o meno asseticamente disinteressate, dipende dalla qualità delle persone e dall'imprinting corporativo. Naturale che ogni tanto qualche stregone politico tenti interferenze'. Se é

assim com os órgãos jurisdicionais, por que haveria de ser diferente com a elaboração legislativa, onde são chamados diretamente a dizer sobre o assunto? É preciso, então, cautela; muita cautela, ou seja, reduzir os espaços de interferência ao máximo possível, o que só se alcança com uma maior solidez da base epistêmica" (COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. "Efetividade do processo penal e golpe de cena: um problema às reformas processuais". Escritos de direito e processo penal em homenagem ao Prof. Paulo Cláudio Tovo. Alexandre Wunderlich [Org.]. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2002. p. 140-143).

[76] E eles querem -mas quem tem que querer é o povo, representado pelo Congresso Nacional! - pois vemos, nos idos de 2002, expressa manifestação de vontade da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, em documento endereçado ao Presidente da Câmara dos Deputados, o hoje Governador Aécio Neves (<http//:www.conjur.com.br>. Acesso em: 29. nov. 2003) e na Carta de Florianópolis, resultado do XX Encontro Nacional dos Procuradores da República (<http//:www.conjur.com.br>. Acesso em: 29 nov. 2003).

[77] Cláudio Fonteles, antes de ser investido nas funções de Procurador-Geral da República, em artigo escrito recentemente, denominado "Investigação preliminar: significado e implicações" (apud Boletim dos Procuradores da República, ano III, n. 35, p. 18-21, mar. 2001), ao comentar a reforma do Código de Processo Penal que pelo Congresso Nacional tramita, se mostra favorável à manutenção de uma investigação preliminar ("tradicionalmente, essa etapa vem sendo cumprida pelo inquérito policial",afirma), não sob o manto dos Juizados de Instrução (como pensamos também), mas com a atuação decisiva do Ministério Público (desde que, repita-se, se venha criar o Juiz das Garantias, que fiscalizará as atividades do Parquet), e, para tanto, se socorre de escólios do Prof. Aury Lopes Jr., que, neste aspecto, assevera: "A tramitação da investigação preliminar deve acontecer direta e desburocratizadamente entre Ministério Público e Polícia de Investigação.

Com isso, a Polícia de Investigação, no Estado Democrático de Direito, como órgão da Sociedade, e não departamento da estrutura centralizada a Administração Pública, leia-se do Poder Executivo, longe ficará das inevitáveis pressões político-partidárias, e, assim, Polícia e Ministério Público, poderão, juntos, e de forma muito mais célere, efetiva e independente, responder aos anseios de Justiça criminal que não seja seletiva, sempre em detrimento do mais fraco, do excluído, mas contemple a todos, sem injunções preconceituosas.

O Estado Democrático de Direito é o que impõe limites a si próprio, e essencialmente na sua tarefa administrativa - Poder Executivo -, não só para que a pessoa humana dotada de garantias efetivas, até que aconteça o ato final de privação de sua liberdade, se assim concluir judicialmente, mas também para que a sociedade, comprometida com os valores de Justiça e Paz, únicos capazes de a todos propiciar igualdade e as oportunidades, possa voltar-se contra quem quer que seja - ricos e pobres - que, por condutas ofensivas da vida, do patrimônio público e privada da saúde, do meio ambiente etc., comprometam o viver em sociedade".

Ou seja, Fonteles reconhece duas coisas primorosas: uma, admite que o procedimento preliminar criminal vem sendo cumprido pelo inquérito policial (não diz, em momento algum do artigo, que o

Ministério Público, com a tal pseudo-atribuição/competência concorrente/supletiva que hoje ele diz possuir, possa fazer às suas vezes) e, duas, que polícia e Ministério Público devam caminhar juntos (juntos, quer dizer, lado a lado, e não um usurpando as funções do outro), pois não há se admitir "que o titular exclusivo da ação penal pública, quem, portanto, elabora e apresenta a pretensão punitiva ao juiz fique divorciado, alheio, ao trabalho de investigação preliminar". (Nesse particular, forçoso concordar com Fonteles, até porque a Constituição e todas as demais leis assim exigem. Ninguém pretende, tampouco pretendeu um dia, um Ministério Público inerte. A sociedade civil reconhece sua relevância, mas, em contrapartida, exige desse órgão o cumprimento dos princípios que estão a nortear o Estado democrático de direito, destacando-se, por todos, o do devido processo legal, que veda ao Parquet, por falta de competência/atribuição constitucional e legal, investigar crimes, salvo os perpetrados por membros da instituição.

[78] É dizer que, conforme regras que norteiam o Estado Democrático de Direito, não se pode admitir, nem ao longe, que reforma de tamanha envergadura venha a ser realizada de afogadilho, dado que virá alterar, sobremodo, todo o arcabouço processual penal até então vigente em terras brasileiras.

[79] O Prof. René Ariel Dotti (Disponível em http//www.paranaonline.com.br. Acesso em: 1 fev. 2004) revela que, em 18/12/2003, a Dra. Maria Teresa Uile Gomes, que chefia o Parquet no Paraná, lhe apresentou, quando ele esteve palestrando, em Curitiba, a convite do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, sobre a matéria ora enfocada, "um esboço de projeto de lei complementar, regulando o funcionamento dos PAIC [Procedimento Administrativo Investigatório Criminal] e com a previsão de garantias para os investigados[!?] e para o objetivo da verdade material". Nesse passo, indaga-se com muita veemência: projeto de lei complementar a quê!?, já que a Constituição não cometeu tal função ao legislador ordinário!, bastando, para comprovar o que se afirma, mencionar-se a PEC 197/2003, subsscrito por contumaz propagandista dos poderes investigatórios criminais do Parquet, desde os tempos em que chefiou, por duas vezes, a Procuradoria Geral de Justiça e a Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Confia-se que o Prof. Dotti, no auge de sua sapiência, ainda que ferrenho crítico, não só do inquérito policial - O Ministério Público e a Polícia Judiciária: relações formais e desencontros materiais. In Ministério Público, Direito e Sociedade. Porto Alegre. Sérgio Fabris, 1986, pp 121-144 -, como nos induz pensar o memorial apresentado pelos Procuradores-Gerais de Justiça), mas, sobretudo, de todo o sistema penal e processual penal vigente, é patentear), mas um garante por excelência, na análise que pretende realizar, não alterará sua opinião sobre a inconstitucionalidade de tais procedimentos, por ele já esposada quando da decisão do Grupo Diretor da AIDP/BR (ver nota 81), por ele presidida, , pondo no chão discussões inúteis, tudo em respeito ao Estado Democrático de Direito.

[80] COUTINHO, J. N. Miranda. "Efetividade do processo e golpe de cena: um problema às reformas processuais". In: WUNDERLICH, Alexandre. Escritos de direito e processo penal em homenagem ao Prof. Paulo Cláudio Tovo. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2002.

Com efeito, parlamentares do PT, o que lidera a proposta é ex-Procurador-Geral de Justiça, ex-Presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em ambos, tendo exercido dois mandatos, sendo notória sua obstinação pelos poderes de investigação do *Parquet* em setembro de 2003, encabeçaram a PEC 197/2003, que pretende "dar nova redação ao inciso VIII do art. 129 da Constituição da República que dispõe sobre as funções institucionais do Ministério Público", o qual, então, passaria a viger como se segue: "[Cabe ao Ministério Público] *promover investigações* [nasceria, aqui, a competência, depois da tramitação legislativa que está ainda em fase embrionária, porventura a emenda venha a ser promulgada pelo Congresso Nacional], requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais".

À guisa de justificativa, enfatizam que:

"A proposta de Emenda à Constituição em epígrafe, visa a permitir, de forma expressa, que o Ministério Público promova procedimentos investigatórios.

O tema diz respeito a uma das mais importantes atribuições dessa Instituição e de fundamental importância para a persecução penal: a investigação de infrações penais.

Vivemos tempos em que as tendências de criminalidade se definem por um acréscimo de condutas delituosas e por fenômenos de organização e internacionalização que sofisticaram o *modus operandi* dos criminosos obrigando os Estados a aperfeiçoarem as estruturas de resposta.

Acrescente-se a isso, as transformações operadas nas condições tecnológicas e culturais com a velocidade imprimida à circulação da informação, a globalização do conhecimento e o reforço do papel reconhecido à opinião pública, constituindo uma nova realidade para a qual são necessários diferentes instrumentos de diagnóstico e intervenção.

Por esta razão, a Organização das Nações Unidas, o Conselho da Europa e as instituições como a Associação Internacional para o Direito Penal[81] têm

[81] O que não corresponde a realidade, porque, em 2.2.2004, o Presidente do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal, Prof. René Ariel Dotti, atendendo específica solicitação do autor sobre o tema enfocado, registrou que, na última reunião do Conselho Diretor da AIDP,

aprovado princípios ou recomendações que apontam para a necessidade de as polícias realizarem a investigação criminal sob a direção de uma autoridade judiciária ou de um órgão encarregado do exercício da ação penal.

Ressalte-se que a investigação criminal inclui-se nas funções de defesa da legalidade e de garantia da segurança e dos direitos dos cidadãos, não se aplicando à investigação criminal a discricionariedade que caracteriza, em geral, os poderes de polícia, realizando-se sempre de forma vinculada. Isto porque a repressão criminal comporta riscos graves de erosão dos direitos individuais e exige, portanto, instrumentos processuais que não permitam que se converta em arbítrio.

Cumpre mencionar, também, que a Constituição Federal em seu art. 144, § 4º, atribui à Polícia Civil a apuração de infrações penais, exceto de natureza militar, ressalvada a competência da União. Entretanto, tal atribuição não se dá em caráter privativo, sendo esta a correta interpretação deste dispositivo.

A Constituição não deu exclusividade na apuração de infrações penais apenas a uma instituição, basta referir que em outro dispositivo (art. 58, § 3º) dá poderes à Comissão Parlamentar de Inquérito para investigação própria [CPI não investiga crime!, já se disse].

Nesse sentido, como titular do *jus puniendi*, nada deve impedir que o Ministério Público, além de requisitar informações e documentos para instruir procedimentos, promova atos de investigação para a apuração de ilícitos penais.

Assim, a presente proposição tem suporte no reconhecimento de que, nos tempos atuais, a soma de esforços no combate à criminalidade é imprescindível para vencê-la, e a circunstância de a Constituição expressamente prever esta competência atende à necessidade de fortalecimento de papel do

realizada no Rio de Janeiro, em 9.1.2004, aprovou "relatório apresentado pela Dra. Luciana Boitexaux a respeito do tema da Investigação Criminal pelo Ministério Público. Apesar do aludido trabalho estar ainda em fase de discussão no seio do Grupo, já existe consenso no sentido de que o Procedimento Administrativo Investigatório Criminal, no seu modelo atualmente em vigor, ofende o princípio do devido processo legal, além de outros declarados na Constituição. (...) Por outro lado, o Grupo Brasileiro não tem conhecimento de qualquer pronunciamento da AIDP a respeito de competência e atribuição funcionais para a investigação criminal que assume contornos próprios de Direito Processual interno".

296

Estado, ante o enfraquecimento gradual, mas inevitável, do controle social exercido pela família, pelos grupos e pelas instituições".

Pronto, talvez, agora – com o explícito (desculpem-nos, mas já nos parecia tão explícito) reconhecimento de que o *Parquet* não goza de qualquer atribuição/competência concorrente/supletiva para promover diretamente investigações de índole criminal (no particular, explicitado por mega-ideólogo das funções investigativas criminais do Ministério Público) –, tenha o Congresso Nacional dado mais um passo para, depois ouvida a comunidade jurídica, enterrar, mais uma vez, a pretensão ministerial.

O poder exige limites, porque, na falta destes, encontraremos solo fértil para o arbítrio e a prepotência, por todos execrados. Tal freio poderá ser dado, acaso esta seja a opção legislativa, criando-se o chamado "Juiz das Garantias",[82] aquele que exercerá o pleno e efetivo controle externo dos atos ministeriais investigativos, com o fim de ver respeitada a paridade de armas, corolário do devido processo legal, quando, então, e somente então, poder-se-á responder, com a segurança jurídica que deve nortear o Estado Democrático de Direito, que a sociedade, de fato, não tem (mais) medo do Ministério Público.[83]

Enfim, muitas águas revoltas vão rolar... e como vão rolar... enquanto isso...

[82] Aquele que, falando de forma muito singela, exercerá o controle direto dos atos praticados por membros do Ministério Público, com o precípuo fim de coarctar, de plano, abusos que poderão vir a ser praticados pelo promotor investigante, isto sem falar, ser prudente que este magistrado, tenha competência para, entre o oferecimento da denúncia e seu recebimento (vindo ela ou não de investigação ministerial, aqui restando incluídos, também, os chamados "processos de surpresa", quais sejam, aqueles que são inaugurados com base em peças de informações, realizar uma audiência prévia, regida sob a égide do contraditório. Recebida a denúncia, sempre em decisão fundamentada, os autos deveriam ser encaminhados à livre distribuição, respeitando-se, neste passo, o princípio do juiz natural.

[83] O Parquet deve ser respeitado, jamais temido. Seus poderes devem ser amplos, mas não absolutos, como sustenta, com acerto, o jovem criminalista Marcio Palma.

13. Uma (possível) conclusão: mas será permitido concluir?

Enquanto isso, teremos de estar preparados a enfrentar, com todas as forças, colando todos os cacos d'alma ainda existentes, argumentos falaciosos, sensacionalistas, oportunistas, por vezes misturados, subliminarmente ou não, a espúrios e inescrupulosos interesses eleitoreiros ou oligárquicos, sobretudo quando acesos os holofotes da mídia-marrom[84] no sentido de que a segurança pública "faliu", a polícia judiciária "faliu" e é corrupta, não está apta e equipada para apurar, com a velocidade da luz, de preferência, os chamados crimes decorrentes de organização criminosa, de corrupção, evasão de divisas, sonegação fiscal etc. Por estes motivos e tantos outros mais, deve o Ministério Público, dito e/ou pretendido "Quarto Poder", ascender ao patamar mais alto do Poder Público, a todos substituindo, porque seus jovens e idealistas representantes são os únicos incorruptíveis o bastante para, em defesa da sociedade, combater, sem destemor, a criminalidade que, a cada dia, com os nefastos efeitos da globalização, se organiza, se estrutura e cresce, atingindo as pequenas, médias e grandes cidades desta República terceiromundista (mas isso, é bom dizer, não é privilégio nosso). Quem a esse discurso se opuser, é porque tem interesses diversos daqueles que deveriam nortear a mente de um cidadão probo. Isso quando não merece, sem direito a defesa, a pecha de integrar/beneficiar, desta ou daquela forma, os tão temidos grupos criminosos. Esse enredo, de tão velho, é de todos conhecido e utilizado, e como foi, pelos governos ditatoriais que comandaram os destinos brasileiros durante o regime militar. Nesse passo, recomenda-se ler Maria Lúcia Karam.[85]

Porém, há que se reconhecer, com tristeza, que estas mensagens alarmistas não foram extirpadas e ainda são usadas amiúde, principalmente nos momentos em que qualquer voz altiva se levanta para falar, em alto e bom som, que o Ministério Público tem de ter seus atos vigiados e limitados pela lei, como de resto, qualquer ente do Poder Público. O *Parquet*, por mais importante, não está acima das leis.

[84] Por todos, ver BATISTA, Nilo. Mídia e sistema penal no capitalismo tardio. RIBCCrim n. 42. São Paulo: RT, jan. - mar. 2003, pp 242- 263.

[85] KARAM, Maria Lúcia. "A esquerda punitiva". Discurso sediciosos: crime, direito e sociedade. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1996. ano 1, n. 1, 1º semestre de 1996.

Assim aconteceu recentemente com o Min. José Dirceu, Chefe da Casa Civil do Governo Luiz Inácio Lula da Silva, acusado pelo presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Procurador de Justiça fluminense Marfam Martins Vieira, em razão de rumores, posteriormente desmentidos pela assessoria do ministro, de que o governo estaria planejando, na reforma do Judiciário, diminuir os (inexistentes, salvo a exceção à regra) poderes de investigação do *Parquet*. Bastou a fagulha do disse-me-disse para que Vieira lançasse mão do mordaz argumento:

"Se ele [Dirceu] mudou de posição de forma tão radical, certamente fez uma mudança ruim, porque deixou de estar do lado da sociedade para se perfilar ao lado de Fernandinho Beira-Mar, Hildebrando Pascoal, Nicolau dos Santos Neto e outros tantos integrantes do crime organizado. (...) O Ministério Público fraco, que não tenha a seu dispor o arsenal jurídico necessário para defender a sociedade, só interessa aos que estão à margem da lei".[86]

Em monografia que mereceu chancela do IBCCrim, a Profa. Débora Regina Pastana,[87] abordando a denominada cultura do medo, com muita propriedade, a desmistifica, informando-nos que é importante "nos distanciarmos destas fantasias políticas de segurança-total" (e, conseqüentemente, de apuração total das infrações penais)[88], agora partilhadas pela direita e a esquerda. Diz a autora:

"Loic Wacqüant nos remete à reflexão dizendo que 'o que carece está em jogo na escolha entre a edificação, por mais lenta e difícil que seja, de um Estado social e a escalada, sem freios nem limites, uma vez que se auto-alimenta da réplica penal, é simplesmente o tipo de sociedade que o Brasil pretende construir no futuro: uma sociedade aberta e ecumênica, animada por um espírito

[86] FREITAS, Silvana de. "MP x Ministério Público: Ministro estaria articulando para reduzir os poderes dos promotores, o que provocou reação". Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 dez. 2003, Brasil, p. A-5.

[87] A cultura do medo: reflexões sobre violência criminal, controle social e cidadania no Brasil. São Paulo: Método, 2003. p. 89.

[88] Ver, sub o tema,THOMPSON, Augusto. Quem são os criminosos? O crime e o criminoso - entes políticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998.

de igualdade e de concórdia, ou um arquipélago de ilhotas de opulência e de privilégio perdidas no seio de um oceano frio de miséria, medo e desprezo pelo outro (...)'.

Cidadania, democracia e direitos, mesmo quando confrontados com desigualdade, miséria e exclusão social, revelam o caminho possível de luta política e de busca de autonomia. Não há processo de desenvolvimento de direitos sem compromissos democráticos explícitos em torno da redução da iniqüidade social, o que certamente implica o fortalecimento da sociedade civil e não do Estado.

O fortalecimento do Estado não diminui a insegurança social, uma vez que atua diretamente contra os criminosos e não contra as causas do crime. Tal insegurança é também o instrumento de autoritarismo para que sempre a força seja desejada socialmente e prometida politicamente. Toda a ideologia de segurança total, longe de restaurar a tranqüilidade, apenas gera incivilidades, afastando o indivíduo de sua condição de cidadão".

Em relação à parte desse discurso punitivo, que em nada contribui para o aperfeiçoamento do Estado de Direito Democrático, tivemos a oportunidade de reconhecer, noutra ocasião, que:

"O brasileiro não vive em paz. Diariamente se depara com o noticiário que faz da violência a sua razão de ser. Cada crime, uma midiática 'sentença condenatória irrecorrível'. Se ele for cruel ou se a vítima é afortunada, o tom é virulento e a pena sem limite. Paredão é dádiva dos justiceiros. São os juízes paralelos. Eles julgam. Não são julgados. Sobrevivem, sem pudor, da tragédia humana. O 'furo' e o discurso eleitoreiro ganham manchetes à custa das dores dos vitimados.

O tema não varia. Violência pela manhã. Violência à tarde. Violência à noite. Ela dá ibope e todos a temem. Ninguém a quer por perto. Câncer do qual se crêem imunes. Poucos admitem encontrar remédio com especialistas. Preferem, sem base ou com base científica distorcida de países primeiromundistas (Itália não é Brasil e Manhattan não é Rio de Janeiro), vender à população solução milagrosa: o fim da criminalidade com o aumento das penas. Cadeia, sustentam os defensores do rigor penal. Nesta seara não existem

milagres, por fervorosas que sejam as rezas. Criminalidade não se combate com lei. Por ser fenômeno humano, não tem fim, tem controle. Controle depende de política governamental séria e ininterrupta. Esta jamais implementada nos últimos governos, que optaram pelo neoliberalismo, abandonando espaços sociais nos quais a presença do Estado se fazia, e se faz, imprescindível. Depois de José Carlos Dias e Reale Jr., temos, mais uma vez, com o Min. Márcio Thomaz Bastos, a esperança de ver frutificado o sonho de gerações.

Exemplo desta propaganda enganosa são os crimes hediondos (pura criação mental dos legisladores patrícios) que datam dos anos 1990. Há mais de década o seqüestro e o tráfico de entorpecentes passaram a merecer tratamento severo. As penas são graves e o apenado ceifado de benefícios durante sua execução. A incidência destes crimes diminuiu? Não. [Será que, se o Ministério Público for o investigante, serão apurados com maior presteza e eficácia?, indagamos agora e já respondemos negativamente.]

O Brasil é vítima da desigualdade social. Esta é um dos pilares da violência. Há que se diminuir o fosso que separa os que tudo têm dos que nada têm. Mas, de outro lado, urge investir na Polícia, no Judiciário e no Ministério Público. Urge, também, seja instalada, país afora, a Defensoria Pública, única instituição capacitada a franquear aos excluídos o pleno exercício da cidadania, espinha dorsal do Estado Democrático de Direito".[89]

Claro está, e até seria desnecessário qualquer marcação, que aquele não é o enfoque utilizado pelos juristas antes citados, por nós muito admirados, os quais, com a liberdade exigida no debate de idéias, se contrapõem a nós neste tema com muita elegância e ética. Mas não há como deixar de reconhecer que segmento, muito barulhento do Ministério Público e de outros setores representativos da sociedade civil, se utiliza deste artifício – sem pudor e impunemente – porque de forte apelo popular.[90]

Tampouco, é bem dizer, que não estamos nos referindo, nem de passagem, ao então presidente do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais

[89] VIEIRA, Luís Guilherme. "Esperança sem terror". Carta Capital, ano IX, n. 243, p. 71, São Paulo, 4.6.2003.

[90] JUNQUEIRA, Aristides. Apud DINIZ, Laura. Op. cit.

de Justiça (que acumulava a chefia do *Parquet* mineiro) e aos vinte e seis Procuradores-Gerais de Justiça que subscreveram o já referido memorial,[91] embora esses tenham registrado para validar a "investigação parquetária", expressão cunhada, a fórceps, pelo Prof. Alexandre Wunderlich, o seguinte:

"(...) as exigências da segurança pública têm colocado sob constantes críticas e análises as funções da *polícia judiciária e do Ministério Público.* As instâncias formais de controle da criminalidade têm passado por profundas crises com o aumento da delinqüência violenta e, não raramente, com o desgaste dos órgãos encarregados da aplicação da lei penal. A própria legislação e Justiça Criminal exigem reformas para a sua adequação à realidade. O Código de Processo Penal prevê tímidas hipóteses de atuação do Ministério Público na repressão da criminalidade. O nosso procedimento criminal, por exemplo, representa um tortuoso itinerário para a busca de uma justiça rápida e eficiente. O sistema adotado deixa a desejar quanto à eficácia e agilidade das investigações. Embora protagonistas da mesma atividade de persecução penal, a interdependência entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público é muito deficitária, quando não rejeitada completamente.

(...)

Como se vê, mostra-se anacrônico e contraproducente o entendimento de que a atuação do Ministério Público na fase preparatória da ação penal restringe-se a requisitar diligências investigatórias e inquérito policial sempre que necessitar coletar dados para formação de seu convencimento. Por isto, não se pode coarctar as funções do Ministério Público na prevenção da criminalidade, em busca da celeridade, do aperfeiçoamento e da indisponibilidade da persecução penal.

(...)

Por outro lado, é necessário lembrar que diversas situações recomendam a intervenção do Ministério Público, por sua independência em relação aos demais Poderes do Estado, desde a fase preparatória da ação penal, realizando investigações próprias. Não é raro ver-se policiais que são responsáveis pela prevenção e repressão da criminalidade envolvendo-se com o crime organizado e na prática de atos de corrupção com o objetivo de impedir a investigação de

[91] Disponível em: <http//conjur.uol.com.br/textos/14807/>. Acesso em: 14 nov. 2003.

delitos, bem como cometendo atos de violência (por exemplo, tortura) ou abuso de poder. Em outras situações, os próprios chefes dos policiais (por exemplo, Secretário de Segurança, Delegados de Polícia) podem ser os responsáveis pelas ações criminosas. Da mesma forma, não se pode olvidar da criminalidade presente no Poder Público (peculato, desvio de verbas, corrupção etc.). Nestes casos, entre outros, é inegável que a própria atividade de polícia judiciária poderá falhar, quando não for omitida".

Para responder os argumentos, valem muito reproduzir as abalizadas lições de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho,[92] que, já nos idos de 1994, no exercício das funções públicas que desempenha na Procuradoria Geral do Estado do Paraná, provocado por consulta, formalizada pelo à época Delegado-Geral da Polícia Civil daquele Estado, acerca da Resolução 97/1994, da Procuradoria Geral de Justiça também daquela unidade federativa, a qual instituía a Promotoria de Investigação Criminal – que passaria a atuar junto à Central de Inquéritos, esta criada pelo Decreto Judiciário 543/1993 – ao mesmo tempo em que concluía ser referida norma administrativa inconstitucional, assim fundamentava seu sempre lúcido e coerente pensamento:

"Antecedente psicológico, portanto, à análise do tema, é a desmilitarização do pensamento quando do tratamento de questões que envolvam o poder da polícia, mesmo porque, ainda hoje, infelizmente, não são poucos – e normalmente os serviçais do Poder e do *status quo* – que vêem os Delegados de Polícia em nível inferior, partindo de um *a priori* negativo. Esquecem-se, tais desavisados, que os Delegados de Polícia, como estabelecido em lei, são tão bacharéis em Direito quanto os Magistrados e os promotores de Justiça, separando-se, quanto a este aspecto, e tão-só, a realização e aprovação em concursos públicos diversos. No mais, cada carreira tem suas peculiaridades, suas vantagens, seus níveis e extensão do poder e suas desvantagens, típicas do exercício da própria função. Por isso, se ao magistrado

[92] COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. "A inconstitucionalidade de lei que atribua funções administrativas do inquérito policial ao Ministério Público". Revista de Direito Administrativo Aplicado, Curitiba (2), ago. 1994, p. 447-449 e 451.

está delegado o poder jurisdicional e, aí, como função principal, aquela de julgar (sobre relevância que sobressai deste mister frente às demais carreiras (...) às autoridades policiais coube encampar o dever do Estado de oferecer segurança pública, não poucas vezes com a vida, longe dos gabinetes, luxuosos ou paupérrimos, mas distantes dos conflitos letais".

Rematando Jacinto Nelson, com a força e a alma de um garante de estirpe:

"Tem-se, portanto, como fundamental, a conservação da estrutura do Ministério Público na forma como concebida na Constituição Federal de 1988, pelo menos até que a sociedade brasileira, por si só, assuma a sua própria defesa, por suas organizações não-estatais. Há, todavia, até tal ponto, um longo processo, como um percurso sinuoso, não poucas vezes incompreendido, até porque fere privilégios de alguns, em favor dos interesses da maioria. Para tanto, é preciso que se pense sistematicamente: a democracia exige que cada um cumpra o seu papel; mas trate de não avançar naquele demarcado aos outros, sob pena de se consolidar uma sobreposição que só faz prejudicar, até porque não permite que se definam as responsabilidades. O pior, porém, é quando essa tentativa, em verdade inadmissível, decorre da desconfiança, da suposição de que o 'outro' não cumpre, por infindáveis motivos, o seu papel. E tudo, pela outra face da questão, também pela suposição de que quem se sobrepõe assim o faz porque se imagina capaz de fazê-lo. A mudança, em tal situação, não tem qualquer procedência, ou melhor, é prejudicial (...). 'Por isso, se não consigo amarrar o juiz pela lei, se não consigo trancá-lo por um garantismo mentiroso (que no fundo só serve para legitimar o status quo da sociedade, para legitimar as camadas da sociedade, que se digladiam na produção normativa), se não consigo alterar essa forma, não há outra solução a não ser partir para a possibilidade oposta e, por ela, buscar soluções. Os juízes, entretanto, precisam ser acreditáveis: e é preciso acreditar nos juízes, mas também nos promotores de Justiça, delegados de polícia e assim por diante. E a razão é simples: mesmo que se desconfie, não adianta nada. Não adianta, por exemplo, querer bitolar o delegado de polícia porque, se ele entender que o caso noticiado não é crime, não faz inquérito policial; e toda a

estrutura da justiça penal cai de joelhos quando se rasga a papelada da comunicação do crime e se joga no lixo. Não podemos, portanto, fazer de conta que a coisa não existe, porque ela está lá; todos os dias e todas as horas; e está acontecendo agora; e a isso não podemos ficar omissos, divagando tão-só em belos discursos sobre o dever ser.' A sobreposição, destarte, é um ledo engano. No caso em discussão, quem arriscaria dizer que o Ministério Público, deixando de lado, por vários de seus órgãos, as relevantes funções que lhe foram atribuídas pela Constituição Federal, deverá perquirir melhor que as autoridades policiais? Ora, tal pensamento chega até a ser ingênuo. Para tanto, basta ver que a hipótese (por óbvio, dentro da estrutura atual do nosso processo penal), que conduz (ou conduziria) a um Juizado de Instrução, de todo indesejável por isso. Afinal, como demonstrou Franco Cordero, com genialidade que lhe é peculiar, não importa quem faz o papel de inquisidor (a função, epistemicamente, conduz o agente), sendo sempre idêntico o resultado (...). Por outro lado, é preciso também questionar até que ponto o próprio Ministério Público tem cumprido a contento com as funções que o legislador constituinte lhe acometeu, *v.g.*, indagando quantos foram os órgãos que deduziram ações em defesa de interesses difusos ou coletivos; e a resposta não pode ser outra que não aquela que se refere a uma tímida atuação. Se é assim, embora pareça singelo, faz-se mister indagar se não é o caso do Ministério Público tratar de cumprir com total eficácia as suas atribuições, pelo menos antes de se arvorar a querer ocupar espaços legalmente atribuídos a outras instituições.

(...)

Afinal, sabem todos que a apuração de infrações penais é a função mais relevante da Polícia Judiciária, quase sua própria razão de ser e, enfim, imanente a ela. Retire-se, portanto, desta, aquela função e teremos um órgão reduzido a expedientes burocráticos sem escopo. Por todos, veja-se a lição de José Afonso da Silva: 'A polícia civil, dirigida por delegados de carreira, em cada Estado, incumbe as funções de polícia judiciária, nos termos já referidos antes, e a apuração de infrações penais, exceto: a) as de competência da polícia federal no âmbito restrito já assinalado; b) as militares' (...) o qual, como referido anteriormente em seu texto, já havia delimitado o espaço de atuação: '(...) mas apesar de toda vigilância, não é possível evitar o crime, sendo pois necessária

a existência de um sistema que apure fatos delituosos e cuide da perseguição aos seus agentes. Esse sistema envolve as atividades de investigação, de apuração das infrações penais, a indicação de sua autoria, assim como o processo judicial pertinente à punição do agente. É aí que entra a polícia judiciária, que tem por objetivo precisamente aquelas atividades de investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via de ação pública'".

Só para clarificar o que Jacinto Coutinho prelecionou, vamos citar duas ocorrências recentes e que estão a demonstrar, cada uma a seu modo, a difusão do discurso absolutista e totalitário, de que só este ou aquele ente do Poder Público é capaz, por esta ou aquela razão, de combater os crescentes índices das chamadas criminalidades violentas ou sofisticadas. Aliás, este discurso, fora a tangível ameaça ao Estado Democrático de Direito, por infundado, não se sustenta, pois assentado em terreno arenoso, de nenhuma concretude, pois de há tanto sabemos que os problemas maiores não são os das instituições, mas os dos homens, que são suscetíveis, deixando-se, por vezes, seduzir a todos os tipos de influência, principalmente as nefastas influências advindas do efêmero e fugaz poder.

Em ligeira pesquisa realizada,[93] tomamos conhecimento de que, nos idos de 2000, quando em curso uma investigação ministerial que apurava as ilegalidades de máquinas de azar numa das capitais mais importantes do país, foi divulgado, com grande estrépito, o conteúdo de uma fita contendo a conversa de um cidadão, genro e então Chefe-de-Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado membro, com suposto "intermediário" do segmento investigado. O conteúdo dessas conversações revelou o seu possível envolvimento com o grupo criminoso e num esquema de extorsão montado para aliviar a apreensão das máquinas. Nelas, o ex-Chefe-de-Gabinete do Procurador-Geral do Ministério Público negocia o pagamento de propina para que o órgão findasse a perseguição aos empresários investigados, que estavam com suas atividades proibidas no Estado.

[93] Disponível em: <http//:www.estadao.com.br> e <http//:www.oglobo.com.br>. Acessos em: 2 nov. 2003).

O nome do Procurador-Geral – que pediu férias de trinta dias, para que seus colegas da Corregedoria tivessem mais liberdade nas investigações inauguradas para apurar estes graves fatos, e, depois requereu a aposentadoria, pois, segundo comentou na mídia, não mais suportava as pressões que vinha sofrendo – foi citado nas conversações levadas a público e aparece como sendo o nome do "chefe de cima". De se reparar, também, que nesse *affair* foi citado, como integrante do criminoso esquema, o nome de importante político de expressão nacional, ex-Ministro de Estado e, no tempo desses acontecimentos, Secretário de Estado.

De tudo, em honra ao princípio constitucional da presunção de inocência, extrai-se, tão-somente, o delicadíssimo exemplo, porque, embora inaugurado o processo (não se sabe se contra todos) não foi ele ainda julgado .

O outro caso, de viés diferente, mas, de jeito igual, gravíssimo e revelador do abuso que pode acontecer na condução de investigações em desacordo com as leis patrícias, nos chegou ao conhecimento por intermédio de professores do sul do país.

Com efeito, depois de veiculação de matéria jornalística que estava a denunciar eventual prática de crimes de abuso do poder econômico, consistentes na formação de um cartel de empresas, Promotoria de Justiça Especializada Criminal de um dos Estados membros, instaurou um expediente investigativo em 2002. Até novamente aflorar o fato, sempre pela mídia, o Ministério Público inquiriu, por várias vezes, os denunciantes. O próprio órgão acusador-investigador, que nunca dera qualquer ciência de seus atos (nessas investigações ministeriais de índole criminal isto é comum acontecer) e nunca inquiriu qualquer investigado, apesar de alguns destes lá terem comparecido com este fim, postulou, a juízo de plantão daquele Estado, a interceptação telefônica de mais de vinte aparelhos, e outras medidas mais, todas, diga-se de passagem, deferidas e mantidas sob sigilo, até mesmo para os advogados dos investigados, os quais só tiveram acesso aos autos depois de ter-lhes sido concedida medida liminar em mandado de segurança impetrado com este escopo.

Com base nesse arremedo de inquérito policial, a Secretaria de Defesa Econômica, que trabalhou lado a lado com o Ministério Público, determinou a instauração de procedimento em sua instância e celebrou, antes mesmo da inauguração do inquérito policial, termo de leniência.

Por fim, mas não por último, devemos rememorar que pendenga judicial de igual jaez também foi sacudida logo após a promulgação da Constituição da República de 1988. Diziam, alguns, que a Carta vigente havia recepcionado a alínea *e* do inc. II do art. 57 do Código Brasileiro de Telecomunicações, motivo pelo qual não havia necessidade de lei a regulamentar a escuta telefônica (inc. XXII do art. 5.º da CR). Portanto, milhares e milhares de cidadãos tiveram suas vidas bisbilhotadas, apesar das "autorizações" judiciais, até que o Pleno do STF proclamou, determinando o trancamento do processo, nos autos da Mandamental 69.912-0-RS,[94] através do voto do progressista Min. Sepúlveda Pertence, Juiz que serve de exemplo para todos que idealizam seguir – ou exercem – a dificílima missão de julgar seus semelhantes, que a prova produzida em processo gaúcho, o qual redundou em condenação de um traficante de entorpecentes, era ilícita, bem como ilícitas eram as dela decorrentes, pois estribada, tão-somente, em escutas telefônicas "autorizadas" judicialmente.

Pronto. Sinal rubro. Milhares de *writs* a postular tratamento idêntico foram impetrados, pois, como é cediço, as provas ilícitas são inadmissíveis no processo (inc. LVI do art. 5º da CR). Atento à problemática,[95] o então Ministro da Justiça e hoje do STF, Nelson Jobim, encaminhou anteprojeto de lei para o

[94] Cumpre salientar, neste passo, que, levado, pela primeira vez o writ a julgamento, a tese restou vencida por seis a cinco. Detectado, pelo impetrante, que havia o impedimento legal do Min. Néri da Silveira, nova mandamental foi posta, e, aí, houve o empate no julgamento, prevalecendo, então, o regimento interno do STF, que, nesta hipótese, delibera a favor da tese mais benéfica ao paciente. Não fosse esta especificidade, milhões e milhões de cidadãos estariam sujeitos à invasão de suas privacidades, ou seja, a mercê de iniqüidades.

[95] Sub o tema, recomenda-se a leitura da Exposição de Motivos da Lei 9.296/1996.

Congresso Nacional, o qual, em tempo recorde (ou seja, com vontade política), transformou-se na Lei 9.296/1996.[96]

Como se vê, outrora a interceptação telefônica a depender de lei e, hoje, o Ministério Público investigando crimes sem competência para tal, a pôr em risco a segurança jurídica do país, imprescindível ao cotidiano de qualquer povo que se pretende civilizado.

"Navegar é preciso" mas para as águas tranqüilas e límpidas do garantismo penal, porto seguro do Estado Democrático de Direito, mola primaz da Constituição da República Federativa do Brasil.

---

[96] Também sensível aos infindáveis abusos cometidos pelo Judiciário nas autorizações para escutas telefônicas, mormente depois do escandaloso affair baiano, no qual convergiam suspeitas sobre a participação do senador Antonio Carlos Magalhães (denunciado no STF, a preambular não foi recebida), o Ministro da Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bastos, constituiu comissão, presidida por Ada Pellegrini Grinover, que tivemos a honra de integrar, para apresentar anteprojeto de lei com o fim de substituir a lei atual. O anteprojeto já foi encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney.

303